



ANUÁRIO DE DIREITOS HUMANOS

Centro de Investigação em Justiça e Governação
Escola de Direito da Universidade do Minho

2021

Anuário de Direitos Humanos

2020

JUSGOV Centro de Investigação em Justiça e Governação
EDUM Escola de Direito da Universidade do Minho

Dezembro 2021

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Anuário de Direitos Humanos - n.º3

ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO

Centro de Investigação em Justiça e Governação

Universidade do Minho

Campus de Gualtar

4710-057 Braga

(+351) 253 601 841 / (+351) 253 601 810 | jusgov@direito.uminho.pt

DIRETORA

Anabela Susana de Sousa Gonçalves

INTERVENIENTES

Ana Raquel Conceição | Fernando Conde Monteiro | Joana Topa | Joana Torres

Jorge dos Reis Bravo | Luis Felipe Miranda Ramos | Marco Ribeiro Henriques

Pedro Jacob Morais

LOCAL E DATA

Braga, dezembro de 2021

PAGINAÇÃO E DESIGN DE CAPA

Pedro Rito

FOTO DE CAPA

Foto original da capa de Laurenz Kleinheider (Unsplash)

ISSN

2184-1853

ÍNDICE

NOTA PRÉVIA

vii

INTRODUCTORY REMARKS

ix

O branqueamento de capitais e crimes informáticos: uma conexão emergente

Ana Raquel Conceição

1

Algumas reflexões sobre o direito penal como instância de controlo sob o impacto das tecnologias de informação

Fernando Conde Monteiro

21

Direitos Humanos e violência de género: reflexões sobre a situação da Guiné-Bissau

Joana Torres, Joana Topa

37

Tortura: (im)prescritibilidade e reparação

Jorge dos Reis Bravo

59

Benefícios da adoção da convenção do cibercrime para a obtenção de provas digitais pelo ordenamento jurídico brasileiro

Luis Felipe Miranda Ramos

77

Reentry, Human Rights, and subjectivities: descriptive approach to the APAC method

Marco Ribeiro Henriques

93

Estado, não-estado e contra-estado. A(s) arquitectura(s) da exclusão

Pedro Jacob Moraes

111

Nota Prévia

É com enorme satisfação que anunciamos o terceiro número do Anuário de Direitos Humanos que, seguindo a já habitual tradição, é um número temático. Esta terceira edição do Anuário é focada na temática dos Direitos Humanos e Direito Penal.

A primeira palavra de agradecimento dirige-se aos revisores que nos acompanharam nesta edição. O rigoroso processo de double blind peer review, mantido nesta edição, permite-nos obter um elevado padrão científico e publicar um conjunto de artigos inovadores, que alimentam o interesse dos nossos leitores relativamente ao Anuário de Direitos Humanos

Nesta terceira edição, apresentamos um conjunto de trabalhos que analisa as relações entre Direitos Humanos, Direito Penal e Novas Tecnologias, em diversas vertentes. O primeiro versa sobre o branqueamento de capitais e crimes informáticos, analisando o referido crime e a sua relação com a criminalidade informática. Também explorando as ligações do Direito Penal e das novas tecnologias, mas agora na ordem jurídica brasileira, acolhemos um texto sobre a Convenção do Cibercrime para a obtenção de provas digitais, mais especificamente relativa à problemática da obtenção de provas eletrónicas armazenadas em outros países. Ainda sobre a mesma temática da relação entre as Novas Tecnologias, Direitos Humanos e o Direito Penal, encontramos uma reflexão relativa ao Direito Penal como instância de controlo sob o impacto das tecnologias de informação.

Em seguida, encontramos um conjunto de trabalhos, em que que é evidenciada a relação entre a dignidade da pessoa humana, Direitos Humanos e Direito Penal. O primeiro versa sobre Direitos Humanos e violência de género, onde é apresentada uma visão centrada na realidade da sociedade da Guiné-Bissau. O segundo aborda o crime de tortura, mais especificamente a prescrição do procedimento criminal e das penas e as modalidades de reparação das vítimas. O terceiro foca-se na importância de garantir os direitos humanos e manter contextos familiares na ressocialização de pessoas privadas de liberdade.

Terminamos, apresentando um último estudo, que pode servir de reflexão base a todos os artigos que publicamos relativamente às ligações entre Direitos Humanos e Direito Penal, pois nele se pondera e reflete sobre o ténue equilíbrio entre a violência e o *ius puniendi*, sobre a concordância prática entre o direito/poder de punir e as liberdades individuais.

Desta forma, encerramos o terceiro número temático do Anuário de Direitos Humanos, agradecendo aos autores o envio dos trabalhos que agora apresentamos. A investigação no âmbito dos Direitos Humanos tem tido uma longa tradição na Escola de Direito da Universidade do Minho, ao longo dos anos, e mantém a sua força na investigação do Jus-Gov, como demonstra a periodicidade deste Anuário. O cruzamento que o Anuário de Direitos Humanos tem vindo a promover nas últimas três edições com outras áreas do Direito, através dos seus números temáticos, permite também mostrar a diversidade da investigação feita no Jus-Gov. Esperamos que o Anuário continue a trilhar este caminho, sedimentando-se, em cada edição, como um periódico de referência na área dos Direitos Humanos.

A editora,
Anabela Susana de Sousa Gonçalves

Introductory Remarks

It is with great satisfaction that is announced the third issue of the Yearbook of Human Rights which, following the previous ones, is also a thematic issue. This third edition of the Yearbook is focused on the topic of Human Rights and Criminal Law.

The first word of recognition goes to the reviewers. The rigorous process of double blind peer review, maintained in this edition, allows us to obtain a high scientific standard and to publish a set of innovative articles, which feed the interest of Yearbook readers.

This third edition presents a set of articles that analyses the relationships between Human Rights, Criminal Law and New Technologies, in several dimensions. The first deals with money laundering and computer crimes, considering the aforementioned crime and its relationship with computer criminality. Also exploring the links between Criminal Law and New Technologies, but now in the Brazilian legal system, there is a text on the Cybercrime Convention for the acquisition of digital evidence, more specifically on the topic of obtaining electronic evidence stored in other countries. Still on the same theme about the relationship between New Technologies, Human Rights and Criminal Law, there is a study on Criminal Law as an instance of control under the impact of information technologies.

Next, the reader can find a set of articles, in which is evidenced the relationship between the dignity of the human person, Human Rights and Criminal Law. The first deals with Human Rights and gender violence and presents a vision centred on the reality of the society of Guinea-Bissau. The second addresses the crime of torture, more specifically the period of limitation of criminal proceedings and penalties and the modalities of reparation for victims. The third focuses on the importance of guaranteeing human rights and maintaining family contexts in the resocialization of people deprived of their liberty.

The last study published can serve as a basis of thought for all the articles presented, because it regards the links between Human Rights and Criminal Law, as it ponders and debates on the tenuous balance between violence and the ius

puniendi and on the practical conformity between the right/power to punish and individual freedoms.

To close the third thematic issue of the Yearbook of Human Rights, one word of gratefulness to the authors for sending the articles that are now presented. Research in the field of Human Rights has had a long tradition at the School of Law of the University of Minho, over the years, and maintains its strength in Jus-Gov research, as the periodicity of this Yearbook demonstrates. The intersection that the Yearbook of Human Rights has been promoting in the last three editions with other areas of Law, through its thematic issues, also allows showing the diversity of research carried out at the Jus-Gov. In the future, the Yearbook will continue to follow this path, establishing itself, in each edition, as a reference journal in the area of Human Rights.

The editor,
Anabela Susana de Sousa Gonçalves

O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E CRIMES INFORMÁTICOS: UMA CONEXÃO EMERGENTE

Ana Raquel Conceição

Professora Auxiliar Convidada da Escola de Direito da Universidade do Minho

Professora Auxiliar da Universidade da Maia

aconceicao@direito.uminho.pt

Resumo: O presente artigo centra-se na análise do crime de branqueamento de capitais e na sua relação com a criminalidade informática. Iremos aferir a génese histórica do branqueamento e sua justificação criminológica. A especificidade deste tipo de crime, principalmente por pressupor um crime anterior para legitimar a sua punibilidade, determina várias implicações ao nível dogmático, dotando-o de alguma dificuldade material e adjetiva. Acrescidas dificuldades se constatarem face à sua relação com a criminalidade informática, a qual, apesar de poder ser também um crime precedente do branqueamento, muitas vezes serve como instrumento para a sua prática, determinando, por força disso, uma relação muito especial entre estas duas formas de criminalidade. Por fim, face à evolução tecnológica que hoje se vivencia, estas merecem uma atenção e cuidados especiais na sua deteção e, primordialmente, na sua prevenção e combate.

Palavras-chave: Branqueamento – Crimes informáticos – Evolução tecnológica – Prevenção – Combate.

1. As implicações dogmáticas e a justificação criminológica

Do ponto de vista histórico, a doutrina vai divergindo sobre a sua origem, contudo, a expressão branqueamento de capitais, ou melhor, *money laundering*, surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos da América em 1920, em Chicago. Conforme refere Schneider, o crime surge porque o grosso dos crimes precedentes têm como resultado, para o agente, muito dinheiro e, assim, é necessária a sua transformação, de forma a poder introduzi-lo no mercado¹. O autor, também citado por Adriana Sousa, refere existirem três tipos de atividade de branqueamento: *transformation* (transformar o poder de compra potencial em poder de compra real); *pollution* (aumentar a taxa de penetração nos sectores da economia através dos investimentos) e *camouflaging* (camuflar as organizações criminosas e os seus agentes)².

Estas atividades espoletaram com a sociedade aberta, informacional e acessível a todos. Os criminosos organizaram-se mais e melhor e o branqueamento deixou as lavandarias e passou a estar em todos os sistemas: político, económico e financeiro.

Os Estados assistindo a este fenómeno juntaram forças e criaram alguns diplomas internacionais, começando pela Convenção de Viena de 1988 até ao último instrumento internacional, a Convenção de Mérida de 2003.

Na Europa, também bem cedo se fez sentir a necessidade de reprimir e prevenir o branqueamento. Em 1991, é criada a primeira diretiva comunitária que é consequência, no âmbito da legislação europeia, da Convenção de Viena que, *grosso modo*, obriga a uma maior atenção por parte das instituições bancárias, nomeadamente na identificação dos clientes e no controlo das suas transações³. Em 2006 surge o Regulamento relativo às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos⁴, que veio a ser revogado, em 2015, pelo Regulamento também respeitante às transferências de fundos⁵. O primeiro regulamento demonstrava – o que permanece no segundo – uma enorme preocupação com o branqueamento de capitais, entendendo-o como uma forma de financiamento do terrorismo e tendo surgido ainda em consequência dos aten-

¹ F. Schneider, “Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings”, Paper (2019), 19, disponível em: <http://www.xn--geldwschecompliance-kwb.de/media/files/Schneider.pdf>, consultado em 13 de fevereiro de 2019.

² A. Sousa, *Branqueamento de Capitais. Enquadramento Legal e Análise Comparativa*, Dissertação de Mestrado, (2015), 8, disponível em: http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/7876/1/Adriana_Sousa_MCV_2015.pdf, consultado em 14 de fevereiro de 2017.

³ *Idem*, *ibidem*, 28.

⁴ Regulamento (CE) 1781/2006 [2006] JO L345/1.

⁵ Regulamento (UE) 847/2015 [2015] JO L141/1.

tados do 11 de setembro de 2001. Estabelece também a necessidade de haver coordenação entre países no fornecimento de informações bancárias.

Em termos de legislação interna, o primeiro tipo incriminador do branqueamento de capitais surgiu com o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. A preocupação, como é evidente, era criminalizar o branqueamento de capitais quando este era oriundo do tráfico de estupefacientes e de outras substâncias psicotrópicas. Aqui fica definitivamente esclarecido que o crime de branqueamento é um crime autónomo do tráfico de droga, mas que deriva deste necessariamente⁶.

A 8 de novembro de 1990, surge a *Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime* – STE n.º 141, também denominada como Convenção de Estrasburgo, que foi transposta para o direito interno português com a Resolução da Assembleia da República n.º 70/97, de 13 de dezembro, determinando no seu artigo 6.º a obrigação de criminalização de várias modalidades de branqueamento de capitais de *produtos do crime*. E foi só em 2004, com a Lei n.º 11/2004, de 27 de março, resultante da transposição da decisão-quadro do Conselho de 26 de junho de 2001⁷, que se criou na lei substantiva o tipo de ilícito de branqueamento de capitais, onde se incriminam as condutas de converter, transferir, auxiliar ou facilitar operação, ocultar ou dissimular a sua natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade de vantagens obtidas por infrações catalogadas na letra da lei e abrangendo, como cláusula geral, infrações punidas com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses ou duração máxima superior a cinco anos. Descrição típica que foi retificada nesse mesmo ano e, posteriormente, alterada com a Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, que trouxe grandes alterações nos crimes sexuais em geral, alterando-lhes a natureza processual penal, de modo a alargar a sua punibilidade, transformando alguns em crimes públicos, sendo, por isso, desnecessária a sua referência na circunstância dos crimes que dependem de queixa. A mesma descrição do tipo foi alterada com a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, a qual veio acrescentar, ao seu catálogo de crimes precedentes, o crime de venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos constantes do código da propriedade industrial; esclareceu a questão da competência da lei penal portuguesa, no espaço, no que concerne ao branqueamento de capitais e seus crimes precedentes quando praticados fora do território nacional; e alterou, radicalmente, a questão da natureza semipública ou particular dos seus

⁶ Neste sentido, ver J. Godinho, *Do Crime de Branqueamento de Capitais. Estudos de Direito Bancário* (Coimbra Editora, 1990), 76.

⁷ Disponível em: http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/2001-500-jai-decisao/downloadFile/file/DQ_2001.500._JAI_Branqueamento_de_capitais.pdf?noca-che=1199976380.33, consultada em 15 de janeiro 2017.

crimes precedentes, ou seja, mesmo que tenham esta natureza, e a queixa não tenha sido apresentada atempadamente, o branqueamento continua a ser punível.

Os elementos objetivos típicos, que se encontram descritos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 368.º-A do Código Penal (CP), consistem na prática de factos que pressupõem uma atividade criminosa prévia. Ou seja, o branqueamento de capitais surge, necessariamente, após a prática de outro tipo de crime e a sua incriminação serve para prevenir a sua própria prática, mas também a prática dos seus crimes precedentes, reforçando as exigências de prevenção.

Não descuramos, todavia, que este tipo de crime é caracterizado por *crimes sem vítima* ou crimes de *vítima abstrata*⁸. É um crime de direito penal secundário, apesar de sistematicamente inserido no direito penal clássico, onde é prevalente a função de proteger bens de carácter social, ou seja, o homem é visto no seu contexto, inserido na sociedade. A proteção secundária pressupõe assim um carácter protetivo e preventivo, já que os bens por esta protegidos têm uma importância vital para toda a sociedade.

Na atualidade, quanto a nós, a comunidade não recebe a mensagem de proteção dos bens jurídicos. Por força dessa insuficiente transmissão da mensagem da pena, surgiram, principalmente veiculadas pela criminologia, preocupações sobre outras mensagens que a pena tem de ter, desde a importância da vitimologia, a legislação sobre a indemnização a vítimas de crimes violentos e as comissões de proteção às vítimas de crimes⁹, às perspetivas mais radicais, como o abolicionismo penal¹⁰, a justiça restaurativa e a mediação penal nos crimes menos graves e, ainda, a insistência do discurso oficial nas penas *alternativas*¹¹.

Também o tipo de ilícito do branqueamento de capitais não escapa a estas vozes e, nessa medida, no seu n.º 7, determina a atenuação especial da pena quando, até ao início do julgamento em 1.ª instância, tiver lugar a reparação integral dos danos causados ao ofendido pelo crime precedente, quer o ofendido seja o Estado, quer seja um particular. Solução que de facto garante o ressarcimento ao ofendido, mas, muitas vezes, traz consigo uma mensagem perversa. A mensagem de que os abastados não são presos, pois conseguem com o seu dinheiro garantir a liberdade, o que de facto, quanto a nós, não é verdade. A possibilidade

⁸ J. F. Dias e M. C. Andrade, *Criminologia. O Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena* (Coimbra Editora, 2.ª reimpressão, 1997), 448.

⁹ A. Sani, *Temas de Vitimologia* (Almedina, 2011), 78.

¹⁰ M. Foucault, *Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão* (R. Ramalhete, trad., Editora Vozes, 1975), 17, e A. Baratta, *Criminologia Crítica e Crítica Del Diritti Penale: Introduzione Alla Sociologia Giuridico-Penale* (Il Mulino, 1982), 67.

¹¹ C. C. Santos, *A Justiça Restaurativa. Um Modelo de Reacção ao Crime Diferente da Justiça Penal. Porquê, Para Quê e Como?* (Coimbra Editora, 2014), 83.

de atenuação de pena com a reparação é algo que devemos enaltecer e ver aplicado com mais frequência.

No que concerne aos fatores criminológicos que estão na origem da incriminação do branqueamento de capitais, podemos apontar a globalização, a sociedade do risco e o crescimento da criminalidade organizada como fatores exógenos aos agentes do crime; e uma gradual e rápida perda de valores como fatores endógenos.

Os valores de respeito pela dignidade da pessoa humana vão perdendo o seu peso em função de uma conceção de valores cada vez mais ligada ao poder material e ao direito de propriedade sobre as coisas. As pessoas valoram cada vez mais o material em detrimento do que é eticamente acertado e de acordo com valores dos direitos humanos¹².

Conforme já referimos antes, não obstante o crime de branqueamento de capitais não ser novo, a sociedade globalizada, sem fronteiras, possibilitou que este crime passasse a ter uma dimensão global. E o uso de meios, cada vez mais informática e tecnologicamente desenvolvidos, dificulta a perseguição e repressão criminal. Assim, a sociedade criminógena global e do risco levou a um aumento exponencial da prática do crime de branqueamento de capitais e dos seus crimes precedentes, em especial, por um lado, os crimes económico-financeiros e, por outro lado, a perda de valores, o aumento do materialismo e a “sobre-adaptação”, o que criou uma nova senda de agentes do crime¹³.

A referência aos crimes de colarinho branco é feita por Figueiredo Dias e Costa Andrade, que explicam que tais crimes se encontram em múltiplas áreas como a saúde, a segurança social e a economia¹⁴.

Tendencialmente, atribui-se a autoria desta expressão a Edwin Sutherland, no seu discurso de tomada de posse como presidente da *American Sociological Society*, em 1939. Contudo, como bem referem Gilda Santos e José Cruz, este conceito de crimes praticados por ricos e poderosos já vem de Beccaria, em 1764¹⁵.

João Conde Correia, analisando a origem do confisco das vantagens e proveitos com base na ilicitude material das condutas que o legitimem, refere

¹² Sobre o paradigma etiológico-explicativo do crime, *vide*, por todos, a obra base da criminologia portuguesa, da autoria de Figueiredo Dias e Costa Andrade, já por nós citada *supra* n. 8.

¹³ Neste sentido, J. Lourenço, *Branqueamento de Capitais*, Estudo efetuado na qualidade de auditor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Verbo Jurídico, 2002), 40-3, e também A. Sousa, *supra* n. 2, 8.

¹⁴ J. F. Dias e M. C. Andrade, *supra* n. 8, 437.

¹⁵ G. Santos e J. Cruz, “Crime de Colarinho Branco e Crime Comum: Um Contraponto”, *Revista de Investigação Criminal* N.º 8 (ASFIC/PJ, 2015), 54.

que a incriminação do branqueamento de capitais foi o seu primeiro instrumento e que resultou da impossibilidade de se evitar ou reprimir o rendimento obtido através do tráfico de estupefacientes que, como se sabe, traz grande e avultados rendimentos aos seus agentes, surgindo a necessidade de o colocar nos mercados lícitos. Assim, a sua incriminação tem também como *ratio* a concretização e transmissão da mensagem comunitária que o crime não compensa¹⁶.

Como já referimos, não é um crime novo ou, pelo menos, a sua origem como crime de colarinho branco já tem longa história. Contudo, a evolução social e a crise de valores fizeram-no espoletar, passando a ser o centro das atenções a todos os níveis.

De seguida concentremos a nossa atenção na relação do branqueamento de capitais com a criminalidade informática.

2. Os crimes informáticos e a sua relação com o branqueamento de capitais

A título introdutório, cumpre-se esclarecer que existe uma relação muito especial entre os crimes informáticos e o financiamento do terrorismo, por força do branqueamento de capitais. Ou seja, os crimes informáticos são um veículo para o branqueamento e este serve para financiar o terrorismo. Assim, nestes crimes, a relação com o branqueamento é totalmente diferente da relação deste com os crimes precedentes. Apesar de ambos, quer os crimes informáticos, quer o terrorismo, o poderem ser por força da cláusula geral constante do n.º 1 do artigo 368.º-A do CP.

Outra característica destes crimes, quando associados, é o seu carácter organizado. Os crimes informáticos e de terrorismo são praticados por grupos criminosos cujo engenho e astúcia determinam uma maior erudição na sua prática, características que o branqueamento de capitais também comporta. Por força desta característica, verifica-se a necessidade de uma cooperação internacional dos Estados não só na sua incriminação, mas, principalmente, na sua prevenção e repressão. Assim, a luta contra esta criminalidade está constantemente a ser partilhada pelos diversos Estados a nível global, quer do ponto de vista de cooperação de campo, quer ao nível da harmonização do direito material interno de todos os Estados, não sendo o nosso país uma exceção, muito pelo contrário. Como bem refere a doutrina espanhola, em especial Juan Carlos Ortiz Pradillo,

¹⁶ J. C. Correia, *Da Proibição do Confisco à Perda Alargada* (Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 2012), 41-42, e G. Santos e J. Cruz, *supra* n. 15, 78.

a legislação portuguesa é um exemplo do reforço da necessidade da junção de forças entre os Estados, principalmente ao nível da prova eletrónica ou digital¹⁷.

Os crimes informáticos podem ser um meio de se conseguir o branqueamento e este poderá ser uma forma de financiamento do terrorismo.

Hoje, quando se fala em crimes informáticos, não podemos deixar de ter como referência a lei do cibercrime, ou seja, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro.

A nova sociedade a que nos referimos *supra* espoleta também uma evolução vertiginosa da informática e das novas tecnologias que, consequentemente, tem repercussões nas práticas criminosas. E também denota uma grande preocupação na forma como se podem investigar os referidos crimes, trazendo, para o direito probatório em processo penal, novos e eficazes meios de obtenção de prova que, por força da sua relação de instrumentalidade com o branqueamento, poderão também ser usados na repressão e investigação deste. Neste sentido também encontramos Armando Ramos que, apesar de a sua investigação se centrar na prova digital com referência ao correio eletrónico, considera que a evolução das novas tecnologias se repercute também na forma de cometimento de crimes novos ou os já existentes se apetrecharem das vantagens e facilidade que os instrumentos informáticos hoje nos fornecem¹⁸.

A própria informatização da sociedade em todos os sectores e o uso imprescindível da Internet facilitam as condutas branqueadoras. Ou seja, mesmo sem condutas ilícitas ao nível do *cibercrime*, a própria Internet é, por si só, um meio para a prática do branqueamento, por ser fácil e acessível a todos, por permitir a prática de atos à distância, porque muitas vezes não se consegue determinar quem de facto a utilizou e, por tal facto, merece uma atenção especial quando em causa está o referido crime, quer no âmbito da repressão quer, principalmente, no âmbito da prevenção¹⁹.

Isto é, a Internet é hoje um instrumento essencial, mas por vezes pernicioso. É impossível configurar-se uma sociedade sem a possibilidade do uso da Internet, que muito nos auxilia e é por vezes imprescindível em termos laborais, de saúde, de justiça e muitos outros, sendo transversal a todos os sectores da vida em sociedade. Contudo, pode também ser usada com o propósito de se praticarem crimes cuja investigação dificilmente é profícua, atendendo às suas próprias características.

¹⁷ J. C. Pradillo, "Nuevas medidas tecnológicas de investigación criminal para la contención de prueba electrónica", in J. P. Gil (ed.), *El Proceso Penal en la Sociedad de la Información. Las Nuevas Tecnologías para Investigar y Probar el Delito* (La Ley, 2012), 285.

¹⁸ A. Ramos, *A Prova Digital em Processo Penal: O Correio Eletrónico* (Chiado Editora, 2014), 83.

¹⁹ Já Rui Gonçalves assim o determinava ainda antes da lei de 2009 – R. Gonçalves, *Fraude Fiscal e Branqueamento de Capitais* (Almedina & Leitão Lda., 2007), 16.

Ou seja, o anonimato da autoria, a impossibilidade de determinação do lugar da sua prática, a tecnicidade que comporta, a sua dimensão mundial e o seu efeito instantâneo determinam uma grave dificuldade investigatória. Porém, as referidas características também espoletam a criação de novos instrumentos legais que determinam o uso de aplicações informáticas com vista a promover a descoberta de condutas branqueadoras. A informática serve como um veículo para a prática do crime, mas também poderá servir como forma de o reprimir ou prevenir.

O branqueamento de capitais pode ser praticado através de várias condutas; todavia, no nosso entendimento, para concretizá-lo, utilizam-se, com alguma frequência, crimes informáticos para o efeito, ou seja, alguns dos crimes informáticos são a forma de execução do crime de branqueamento de capitais. Todavia, também podem ser um dos crimes precedentes do branqueamento e, neste caso, têm o tratamento que a generalidade dos crimes precedentes tem do ponto de vista dogmático. Mas, quando são o veículo para a prática das condutas branqueadoras, a questão dogmática e processual poderá ser diferente.

Com base em classificações distintas, os autores tendem a distinguir os crimes praticados através dos sistemas informáticos dos crimes informáticos, conforme a sua tipificação na Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro. Esta distinção assenta *grossa modo* na (im)possibilidade de os crimes poderem ser praticados, ou não, através do uso de outros meios que não apenas a informática e tendo por base a axiologia subjacente à sua tipificação²⁰.

Tal delimitação conceptual demonstra a especificidade e a necessária consunção pelo branqueamento, pois o crime informático preenche um tipo legal, por exemplo, é uma falsidade informática e é ao mesmo tempo um instrumento para a prática daquele. É certo que protegem valores diferentes, mas tal axiologia não legitima por si só o concurso real de crimes.

No nosso entendimento, tendo como referência os crimes descritos da referida lei e analisando os elementos objetivos do tipo do crime de branqueamento, em especial as condutas descritas nos n.os 2 e 3 do artigo 368.º-A, estas poderão ser executadas através de várias operações informáticas que, por si só, também são crime. Basta pensarmos e atentarmos à descrição típica da falsidade informática, da sabotagem informática ou do acesso ilegítimo²¹ e facilmente constatamos que são essas as formas que, muitas das vezes, se usam para operar a conversão, transferência ou facilitar qualquer uma delas com vista a impedir responsabilização do agente do crime precedente ou dissimular a verdadeira origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens. É

²⁰ Sobre essa distinção, vide P. Venâncio, *Lei do Cibercrime: Anotada e Comentada*. (Coimbra Editora, 2011), 17.

²¹ Artigos 3.º, 5.º e 6.º, respetivamente, da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro.

certo que as condutas podem ser praticadas sem ser através de qualquer falsidade informática, mas a informática, como vimos, potencia estas condutas. Assim, resta saber, no caso de o branqueamento consistir numa das condutas descritas na lei do *cibercrime*, se haverá concurso de normas ou concurso de crimes.

Para responder à questão colocada importa desde logo ter em conta os seus bens jurídicos. De facto, os bens jurídicos são distintos do branqueamento de capitais. Hoje a doutrina e jurisprudência são quase unânimes em afirmar que a generalidade dos crimes informáticos tem como bem jurídico a proteção da autenticidade ou integridade de um qualquer sistema informático ou de informação e não o património, ou a realização da justiça²². Todavia a reserva da vida privada, o direito à palavra virtual e o direito à imagem são também bens jurídicos protegidos em alguns crimes informáticos, em especial nos crimes de interceção ilegítima e acesso ilegítimo. Contudo, esta diferença de bem jurídico não pode ser, por si só, a razão de ser do concurso real, apesar de ser o principal argumento que a jurisprudência nacional utiliza para determinar a existência do concurso real²³.

Quanto a nós, tal raciocínio não pode ser automático, por um lado, e, por outro, dever-se-á atender às circunstâncias do caso concreto, quer no que concerne ao juízo de reprovação ético-jurídico, em especial no âmbito do desvalor da ação, quer quanto aos fins das penas. Ou seja, aferir se as finalidades das penas ficam saciadas com a punição em concurso aparente ou se será necessário o concurso real. Assim, se tal raciocínio não é legítimo, sem mais, na análise do concurso com os crimes precedentes, muito mais será ilegítimo quando em causa estejam crimes informáticos utilizados como um veículo do branqueamento e não sendo estes as fontes das vantagens constantes do tipo incriminador.

Referimo-nos, em especial, à situação em que o ato de execução do crime de branqueamento é um crime informático, ou seja, por exemplo, quando a dissimulação da origem ou localização da vantagem obtida através dos factos ilícitos descritos no n.º 1 do artigo 368.º-A é feita através de uma modificação de da-

²² Neste sentido, o Acórdão da Relação do Porto de 24/04/2013, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/872f3063233d8de480257b78003e60f3?OpenDocument>, consultado em 15 de fevereiro de 2019.

²³ Neste sentido, o Acórdão da Relação de Lisboa de 30/06/2011, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fd8c21bdd02218c0802578d30030770e?OpenDocument>, consultado em 15 de fevereiro de 2019.

Neste acórdão, a análise do concurso prendia-se com os crimes de contrafação de moeda e falsidade informática. E considerou-se que entre ambos existe um concurso real por força da diferença de bens jurídicos.

A Relação do Porto, em 30/04/2008, considerou existir concurso real entre a falsidade informática e burla. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/1ed7f-9993ce687df80257442005bcedb?OpenDocument>, consultado em 15 de fevereiro de 2019.

dos informáticos. Aqui, a conduta é uma só, a falsidade informática é o meio de branquear. Apesar de tutelarem bens jurídicos distintos, quanto a nós, é violador do *ne bis in idem* a sua punição em concurso real ou de crimes, pelo que existirá antes uma relação de consunção entre as referidas normas. Ora, se a execução do branqueamento só foi conseguida através da uma falsidade informática, há também uma relação de consunção, pois a conduta do agente esgota-se no crime de branqueamento, que é punido sempre com uma pena superior a qualquer crime informático. Melhor, o diferente juízo de censura que o branqueamento de capitais comporta e, por força dele, a necessidade da sua punição ficam garantidos com a punição em concurso de normas. Não há nestes casos um maior desvalor da ação, grau de censura sobre o comportamento do agente, ou maior ilicitude do facto que mereça a punição em concurso real. Há uma “unidade criminosa” e, como refere Figueiredo Dias, a conduta do agente esgota-se com o branqueamento, este é o seu fim último. Como ainda refere o autor: “(...) um ilícito singular surge, perante o ilícito principal, unicamente como meio de o realizar e nesta realização esgota o seu sentido e os seus efeitos.”²⁴.

Apesar de defendermos o concurso aparente quando o branqueamento é praticado através de um crime informático, em especial a falsidade informática e, consequentemente, o agente estará a ser investigado apenas por aquele e não pelo crime informático que foi consumido, tal consunção não impede o uso das ferramentas investigatórias descritas na parte processual da lei do *cibercrime*. Desde logo porque assim determina a referida lei, quando legitima o uso das suas ferramentas investigatórias quando o crime é praticado através de um sistema informático.

Pretendemos ainda realçar que os mecanismos investigatórios da lei do *cibercrime* poderão ser utilizados na investigação do branqueamento, quando a sua prática preenche os elementos do tipo de um dos crimes informáticos aí descritos, mesmo que consumidos, quer sejam ao nível da mera recolha de dados informáticos ou de uma verdadeira interceção de comunicações informáticas, pois o uso do sistema informático para branquear está sempre presente e o tipo legal do branqueamento assim o permite²⁵.

Analisemos as medidas adjetivas na sua prevenção e combate.

²⁴ J. F. Dias, *Direito Penal, Parte Geral – Tomo I – 2.ª edição – Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do Crime* (Coimbra Editora, 2007), 993 e 1018.

²⁵ O que a Relação de Évora denomina como um regime processual *geral* e um regime processual *especial*.

Acórdão da Relação de Évora de 20/01/2015, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db-04f39bf2802579bf005f080b2fbd21285478f5f80257de10056ff7a?OpenDocument>, consultado em 18 de fevereiro de 2019.

3. As medidas de combate e prevenção face à especial relação entre os crimes informáticos e o branqueamento de capitais

Na repressão dos crimes informáticos surge, como vimos *supra*, a Convenção *Cibercrime*, que tem como objetivo, por um lado, uniformizar a identificação e classificação das condutas como crime informático e, por outro, dotar os Estados signatários de novas ferramentas processuais que consistem na preservação expedita de dados, nas diferentes formas de buscas e apreensões e na previsão de obtenção de dados de livre acesso. Resumidamente, a primeira ferramenta consiste na possibilidade de obter dados, em tempo real, do percurso de uma determinada comunicação, possibilitando que se possa saber quem, num determinado dia e hora, acedeu a um determinado sítio da Internet. Tratando-se de dados de conteúdo, ou seja, dados que corporizam o conteúdo da comunicação, essa interceção e posterior apreensão terão de ser autorizadas por um Juiz, com respeito pelos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade.

As buscas e apreensões em ambiente digital que podem consistir não na efetiva apreensão dos bens, mas na cópia dos dados informáticos em causa, consagram a obrigação das entidades fornecedoras de Internet (ISP – *Internet Service Provider*) de identificar o local onde se encontram os dados que se pretendem apreender. Por último, a obtenção livre de dados consiste na possibilidade de obter dados que estejam alojados de forma digital no estrangeiro, num local de fonte aberta, um local acessível a todos os utilizadores. São ferramentas processuais que tentam estabelecer uma igualdade de armas entre os Estados na investigação criminal.

No regime jurídico-processual da lei do *cibercrime*, podemos determinar que esta se divide em duas partes: uma parte referente à preservação ou armazenamento de dados informáticos, pois tem a natureza de uma verdadeira apreensão de dados informáticos que poderão ser o meio de prova da prática de crimes informáticos ou praticados através de um sistema informático; uma segunda parte que corresponde a meios de obtenção de prova que tendem a recolher prova de um crime que está nesse momento a ser praticado. Com os mecanismos constantes da primeira parte, apenas se tenta descobrir um crime com a recolha de dados que são o seu resultado criminoso ou o veículo da sua prática, e, como tal, o crime já se consumou; com os da segunda parte, o meio de investigação é concomitante com a prática do crime. A construção de que existem dois regimes na parte adjetiva da lei do *cibercrime* é também defendida pela jurisprudência da Relação de Évora, em especial no seu Acórdão de 20/01/2015²⁶.

²⁶ Acórdão da Relação de Évora de 20/01/2015, *supra* n. 25.

A pertinência da distinção, quanto a nós, é também reveladora de uma maior ponderação no respeito pelos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação.

Interessante é também a relação que estes meios de investigação têm com os métodos dissimulados ou ocultos de investigação, como são por excelência as escutas telefónicas. E daí a sua extrema eficácia. Por força de tal relação, a doutrina tendencialmente divide-se em defender a necessidade de os referidos meios de investigação deverem constar do Código de Processo Penal (doravante, CPP), no seu livro das provas; outras vozes se erguem no sentido de defender que estão muito bem inseridas em legislação extravagante, atendendo principalmente à especificidade que os crimes informáticos possuem que, consequentemente, se repercute nos seus métodos de obtenção da prova. Tal diferença de opinião assenta sobretudo no facto de se tratarem de meios ocultos de investigação, por força da sua danosidade latente, ou seja, poderem afetar vários destinatários, mesmo sem serem suspeitos, sem nunca terem conhecido a invasão do seus direitos e, assim, segundo os primeiros, a sua não inserção no livro das provas implicará um menor controlo na atuação dos intervenientes judiciais e, com isso, um maior risco de a informação recolhida ser usada para fins diferentes da investigação criminal. Outros autores entendem que o facto de se encontrar fora do CPP em nada põe em causa, de forma desproporcional ou desnecessária, os direitos fundamentais dos cidadãos, devendo tal regulamentação existir fora do CPP, de forma a realçar as especificidades desta criminalidade e, consequentemente, dos métodos de recolha e produção da sua prova, permitindo às entidades investigatórias uma maior valência e cooperação com outras entidades policiais ou operadoras de fornecimentos dos serviços de telecomunicações e Internet²⁷. Compreendemos e realçamos a preocupação de Paulo Dá Mesquita e Manuel da Costa Andrade²⁸ com o uso de meios de investigação ocultos ou dissimulados, pois a sua eficácia quase constante pode levar à tentação do seu uso ilegal. Todavia, a sua inserção sistemática é, em nossa perspetiva, irrelevante, pois o mais importante é o respeito exímio do seu regime jurídico, que acreditamos ser a regra nos nossos intervenientes judiciais. O facto de a sua danosidade ser

²⁷ No sentido da necessidade da sua inserção no CPP, P. D. Mesquita, *Processo Penal, Prova e Sistema Judiciário* (Coimbra Editora, 2010), 85, e M. C. Andrade, “Bruscamente no Verão passado”, *A Reforma do Código de Processo Penal: Observações Críticas Sobre Uma Lei Que Podia e Devia Ter Sido Diferente* (Coimbra Editora, 2009), 127.

Defendendo a manutenção do regime jurídico fora do CPP, C. Cabreiro, *Cibercrime em Portugal: Trajetórias e Perspetivas de Futuro* (2017), 48, disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/17168/2/Cibercrime%20em%20Portugal%20Trajet%C3%B3rias%20e%20Perspetivas%20de%20Futuro.pdf>, consultado em 8 de maio de 2017, e A. R. Leite, *Criminalidade Informática – Investigação e Meios de Obtenção de Prova* (Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2014), 48.

²⁸ P. D. Mesquita, *supra* n. 27, 85 e M.C. Andrade, *supra* n. 27, 127.

efetivamente maior e haver um maior risco de lesão de diferentes bens jurídicos titulados por diversas pessoas é a consequência do próprio meio de investigação, só por si. Em conclusão, o facto de se encontrar em legislação extravagante, na nossa ótica, não permite uma maior nulidade ou abuso na sua utilização, até porque, no seu regime jurídico, há referência às regras de obtenção da prova da lei geral, que é o CPP²⁹.

Assim, o facto de existir um regime probatório no CPP e um fora do CPP carece de uma análise na sua correlação. Iremos, pois, aferir se os meios de investigação constantes na lei do *cibercrime* determinam uma nova interpretação do regime jurídico de extensão das escutas telefónicas. Apenas relacionamos com este meio de obtenção da prova, pois só aqui se colocará a presente questão, principalmente quando o legislador do CPP, no artigo 189.º, n.º 1, utiliza a expressão “ou outras formas de transmissão de dados via telemática, mesmo que se encontrem guardadas em suporte digital”.

A jurisprudência da Relação de Évora, na mesma decisão em referência, determina que: “O regime processual das comunicações telefónicas previsto nos artigos 187.º a 190.º do CPP deixou de ser aplicável por extensão às «telecomunicações electrónicas», «crimes informáticos» e «recolha de prova electrónica (informática)» desde a entrada em vigor da Lei 109/2009, de 15-09 (Lei do Cibercrime) como regime regra. (...) O artigo 189.º do CPP nunca é aplicável a crimes informáticos, seja qual for o catálogo aplicável”. De facto, parece-nos ser esta a melhor interpretação a fazer, pois a lei do *cibercrime* é especial em relação ao CPP e, como em nada o derroga, dever-se-á promover a aplicação da lei especial. Todavia, entendemos que o facto de continuar a existir a referida expressão no artigo 189.º do CPP poderá dar azo a confusões, devendo a mesma ser retirada. Neste mesmo sentido, também a Relação de Évora reforça tal entendimento no seu Acórdão de 25/10/2016. Nesta decisão judicial, determina-se que existe um regime legal especial de investigação, quando em causa estejam crimes informáticos ou crimes que se relacionem com a informática e, por tal, derogam o regime jurídico da prova constante do CPP. Esta interpretação, quanto a nós, é a mais correta, pois esclarece-se a relação entre os diferentes regimes jurídicos, no que diz respeito à prova em ambiente informático. Mais uma vez verificamos que a investigação criminal digital ou informática é especial em relação àquela que consta no CPP e, não obstante poder receber os princípios deste, certo é que, atendendo à sua especificidade, tem um objeto muito próprio, que são os dados informáticos.

²⁹ O mesmo se diga em relação ao registo de voz e imagem constante da Lei n.º 5/2002, de 5 de janeiro, que desde sempre nela esteve estatuído como meio de obtenção da prova e nunca tal argumento foi levantado.

Por tudo isto, reforçamos, para melhor enquadramento da forma de recolha e preservação de prova em ambiente informático, que seria importante a criação de um regime processual penal autónomo em diploma diferente quer da lei do *cibercrime*, quer da lei que regula a preservação e conservação dos dados informáticos e respetivos diplomas complementares, quer do próprio CPP onde, de forma sistemática e ordenada, se disporia do regime jurídico da prova digital.

Para Paulo Dá Mesquita verifica-se a existência de um capítulo *escondido* do livro das provas referente à prova eletrónica, que corresponderá ao capítulo V do livro das provas³⁰.

Quanto a nós, tal regime jurídico deveria ser criado e compilado em legislação autónoma do CPP, de forma a demonstrar a especificidade que estes meios de investigação comportam, por força, também, das especificidades dos crimes que investigam. Contudo, em tal diploma deveriam ser realçadas as exigências de respeito estrito pelos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, atendendo – referimos, mais uma vez – à danosidade e devassa que tais instrumentos em abstrato comportam. E, evidentemente, sem nunca violar o princípio da reserva de lei.

Este novo e específico regime jurídico da prova deverá aplicar-se, como já acontece na investigação do branqueamento de capitais, quando uma das suas condutas seja praticada através de um sistema informático ou os seus atos de execução correspondam a um crime informático. Apesar de existir uma relação de consunção entre alguns crimes informáticos e o branqueamento, quando praticado através do uso de um sistema informático, tal concurso aparente ou de normas não impede que se utilizem os meios de obtenção da prova dos crimes informáticos. Aliás, o sistema informático é um pressuposto para a aplicação das disposições processuais da lei do *cibercrime*, impondo-se um maior grau de ponderação e exigibilidade em relação à interceção das comunicações e às ações encobertas (previstas nos artigos 18.º e 19.º, respetivamente, da referida lei). Assim, sempre que um crime seja cometido por meio de um sistema informático, podem usar-se os meios de obtenção da prova relativos aos crimes informáticos. Todavia, nos mais invasivos, tal como acontece no direito probatório constante do CPP, a ponderação da necessidade, adequação e proporcionalidade são realçadas.

Detenhamo-nos mais um pouco na interceção de comunicações e nas ações encobertas constantes da lei do *cibercrime*, pois serão aquelas que garantem uma maior eficácia, embora, por outro lado, sejam as que causam uma maior danosidade na inviolabilidade das comunicações e reserva da vida privada.

³⁰ P. D. Mesquita, *supra* n. 27, 101.

Na interceção de comunicações, há uma remissão para os crimes de catálogo das escutas telefónicas, o que desde logo determina a sua aplicabilidade ao branqueamento de capitais. A sua positivação deveria merecer uma alteração ao regime de extensão das escutas, tal como referimos antes, pois, neste meio de obtenção da prova, cabem todas as comunicações com o uso da palavra virtual, reduzindo o âmbito de aplicação do artigo 189.º, n.º 1, do CPP às comunicações efetuadas através do uso da palavra falada, pelo telefone ou outro mecanismo ou diretamente. Mas não remete apenas para o âmbito de aplicação material das escutas, impõe também o respeito pela existência das fundadas exigências de necessidade³¹. Em bom rigor, trata-se de um meio de obtenção da prova com os mesmos requisitos de substância e de forma das escutas telefónicas, mas com um objeto diferente, a palavra virtual. Apenas com uma pequena *nuance*, por força da diferente natureza da forma de comunicação, apesar de várias vozes determinarem que há um erro legislativo nesta parte³².

Em nossa opinião, é possível que a interceção sirva os seus precisos termos, ou seja, que se intercete e capte a comunicação realizada, mas pode servir apenas para a recolha e registo dos dados de tráfego, sem necessidade de obtenção do conteúdo da comunicação³³. Formas de comunicação que cabiam no regime de extensão das escutas telefónicas.

Apesar de haver a remissão para crimes do catálogo na alínea b), deve tal remissão ser interpretada de forma ultra sistemática, ou seja, o catálogo admite a interceção telefónica na investigação dos crimes punidos com pena de prisão superior a três anos ou os menos graves, quando praticados através do telefone. Quando estes sejam praticados através de um sistema informático, cabem neste meio de obtenção da prova, pois o que está em causa é a forma de comunicação utilizada e não a palavra virtual. É evidente que esta questão não se coloca quando em causa esteja a investigação do crime de branqueamento de capitais, pois, desde logo, cabe nos crimes de catálogo por força do *quantum* da pena.

No que respeita às ações encobertas, faremos apenas uma breve referência. Neste âmbito estende-se a aplicabilidade deste meio de obtenção de prova para as investigações dos mesmos crimes que cabem na interceção das comunicações. As ações encobertas, que objetivamente são um meio enganoso de obtenção de prova, mas admissíveis pela ponderação exígua dos interesses em conflito, neste âmbito, vão permitir que se criem perfis falsos, se encetem conversa

³¹ Sobre a excecionalidade das escutas, e.g. A. R. Conceição, *Escutas Telefónicas, Regime Processual Penal* (Quid Iuris, 2009), 59-65.

³² A. Cancela, *A Prova Digital: Os Meios de Obtenção de Prova na Lei do Cibercrime*, disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitsream/10316/31398/1/A%20prova%digital.pdf>, consultado em 6 de março de 2017, 51.

³³ Também neste sentido, P. Venâncio, *supra* n. 20, 119.

ou comunicações falsas, ou até mesmo que se constituam *sites* ou outro tipo de informações *online*, de forma a investigar a criminalidade referida, isto é, acaba por consistir na prática do crime de falsidade informática, mas justificada por exigências de prevenção e investigação criminal³⁴.

Assim, a informática e a possibilidade de aceder a formas de comunicação nesse mundo, mesmo com a criação de informações falsas, são um meio de obtenção da prova extremamente eficaz quando em causa estejam condutas branqueadoras, praticadas através do uso da mesma. Aliás, o seu combate e luta pressupõem uma grande atenção a esse mesmo nível. Contudo, se atentarmos ao regime jurídico das ações encobertas previstas na Lei n.º 101/2011, de 25 de agosto, dali resulta que também é uma medida de prevenção e que as exigências de necessidade não são tão fortes como nos demais meios de investigação dissimulados, apenas se exigindo ser “adequadas aos fins de prevenção e repressão criminais identificados em concreto, nomeadamente a descoberta de material probatório, e proporcionais quer àquelas finalidades quer à gravidade do crime em investigação”, o que denota uma prevalência da proporcionalidade neste meio de obtenção da prova³⁵.

No nosso entender, este é o princípio prevalente neste meio de obtenção da prova. É certo que na lei do *cibercrime* se alarga o seu âmbito de aplicação, passando a ser aplicável aos crimes informáticos, aos praticados através de um sistema informático com a cláusula geral da pena superior a cinco anos ou inferior e se se tratar de crimes sexuais e os ofendidos forem menores ou incapazes; nos demais ali constantes, respeita-se a cláusula dos cinco anos. Assim, parece-nos que a proporcionalidade nas ações encobertas na lei do *cibercrime* segue a linha da proporcionalidade da lei geral deste meio de obtenção da prova, adaptando-a à nova realidade da criminalidade informática ou praticada através de um sistema informático. A crítica que podemos apontar é à própria lei geral, pois a necessidade não está referenciada no texto da lei, mas resultará inferida do artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa.

Por fim, importa ainda referir que, em 28 de novembro de 2016, passou a vigorar o Decreto-Lei n.º 81/2016, que criou a Unidade Nacional de Combate ao *Cibercrime* e à Criminalidade Tecnológica³⁶, que surgiu de forma a especializar

³⁴ Conforme refere Federico Mata, as ações encobertas em ambiente digital devem obedecer a rigorosos e apertados requisitos – F. Mata, “Un centinela virtual para investigar delitos cometidos a través de las redes sociales: Deberían ampliarse las actuales funciones del agente encubierto en internet?”, in J. P. Gil (ed.), *El Proceso Penal en la Sociedad de la Información. Las Nuevas Tecnologías para Investigar y Probar el Delito* (La Ley, 2012), 332.

³⁵ Segundo Alberto Cancela, em ambiente digital, este meio de obtenção da prova viola o princípio da proporcionalidade – A. Cancela, *supra* n. 32, 65.

³⁶ Legislação disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2608&tabela=leis&so_miolo=, consultada em 16 de março de 2019.

a Polícia Judiciária (PJ) no combate e prevenção deste tipo de criminalidade³⁷. Mais um instrumento que dota a PJ de competência científica na luta contra a criminalidade informática e a criminalidade praticada por meio da informática, cumprindo assim as soluções e fins prosseguidos na União Europeia.

Assim, e em jeito de conclusão, no que concerne às formas de investigação no âmbito da informática, entendemos que seria relevante a criação de um regime probatório autónomo onde o branqueamento de capitais dele deveria constar de forma expressa³⁸, não obstante a sua inexistência não impedir a utilização dos referidos meios. Desta forma, seria claro e simples para os investigadores que as condutas branqueadoras informáticas cabem no âmbito dos meios de investigação ao serviço do *cibercrime*.

4. Conclusão

O branqueamento de capitais tem vindo a consolidar-se como epicentro da criminalidade organizada. Surgido da necessidade de os beneficiários de proventos ilícitos darem a aparência de licitude aos rendimentos, produtos ou vantagens obtidas com a prática de crimes, começou nas lavandarias americanas, tomou conta de todos os sectores do país e é cada vez mais internacional. E sempre com o mesmo mote: a necessidade de fazer desaparecer a sua mancha original.

A nova sociedade sem fronteiras, onde o conhecimento e a informação estão à distância de um *click*, associados a uma evolução tecnológica e informacional rápida e incontrolável, oferece também as melhores condições para o cometimento deste tipo de criminalidade e acrescidas dificuldades no que respeita à sua prevenção e repressão; além disso, a sua relação quase simbiótica com a criminalidade informática e o financiamento do terrorismo contribuíram decisivamente para o aumento, ainda mais, das naturais dificuldades investigatórias e acrescentaram-lhe uma perigosidade mais latente e universal, sempre potencian-do a criminalidade organizada.

A especial relação entre a criminalidade informática e as condutas branqueadores não poderá determinar, de modo automático, que, por tais incriminações protegerem bens jurídicos distintos, não estão sujeitas a concurso aparente, mas antes um concurso real ou efetivo de crimes. A instrumentalidade dos crimes informáticos, funcionando, muitas vezes, como atos de execução do crime de branqueamento, poderá determinar a existência de uma efetiva consunção, em respeito pelo princípio constitucional do *ne bis in idem*.

³⁷ Fundamento constante na exposição de motivos do referido Decreto-Lei.

³⁸ Semelhante ao catálogo constante da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, ou da Lei n.º 101/2011, de 25 de agosto.

Face a esta relação de proximidade, vários instrumentos são criados de modo a prevenir e combater o branqueamento de capitais e a criminalidade informática. Sem prejuízo do concurso aparente, que poderá verificar-se entre estes dois tipos legais de crime, a prática do branqueamento com um crime informático legitima a utilização das medidas processuais de combate a este. As quais deveriam constar em diploma avulso, de natureza apenas adjetiva, de modo a facilitar o intérprete e o aplicador da lei, privilegiando-se a especialização da Polícia Judiciária e a cooperação entre os Estados.

Bibliografia

Andrade, M. C., “Bruscamente no Verão passado”, *A Reforma do Código de Processo Penal: Observações Críticas Sobre Uma Lei Que Podia e Devia Ter Sido Diferente* (Coimbra Editora, 2009).

Baratta, A., *Criminologia Critica e Critica Del Diritti Penale: Introduzione Alla Sociologia Giuridico-Penale* (Il Mulino, 1982).

Cabreiro, C., *Cibercrime em Portugal: Trajetórias e Perspetivas de Futuro* (2017), disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/17168/2/Cibercrime%20em%20Portugal%20Trajet%C3%B3rias%20e%20Perspetivas%20de%20Futuro.pdf>, consultado em 8 de maio de 2017.

Cancela, A., *A Prova Digital: Os Meios de Obtenção de Prova na Lei do Cibercrime*, disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31398/1/A%20prova%20digital.pdf>, consultado 6 de março de 2017.

Conceição, A. R., *Escutas Telefónicas, Regime Processual Penal* (Quid Iuris, 2009).

Correia, J. C., *Da Proibição do Confisco à Perda Alargada* (Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 2012).

Dias, J. F., *Direito Penal, Parte Geral – Tomo I – 2.ª edição – Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do Crime* (Coimbra Editora, 2007).

Dias, J. F. e Andrade, M. C., *Criminologia. O Homem Delinquente e a Sociedade Criminológica* (Coimbra Editora, 1997).

Foucault, M., *Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão* (R. Ramalhete, trad., Editora Vozes, 1975).

Godinho, J., *Do Crime de Branqueamento de Capitais. Estudos de Direito Bancário* (Coimbra Editora, 1990).

Gonçalves, R., *Fraude Fiscal e Branqueamento de Capitais* (Almedina & Leitura Lda., 2007).

Leite, A. R., *Criminalidade Informática – Investigação e Meios de Obtenção de Prova* (Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2014).

Lourenço, J., *Branqueamento de Capitais*, Estudo efetuado na qualidade de auditor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Verbo Jurídico, 2002).

Mata, F., “Un centinela virtual para investigar delitos cometidos a través de las redes sociales: Deberían ampliarse las actuales funciones del agente encubierto en internet?”, in J. P. Gil (ed.), *El Proceso Penal en la Sociedad de la Información. Las Nuevas Tecnologías para Investigar y Probar el Delito* (La Ley, 2012), 311-328.

Mesquita, P. D., *Processo Penal, Prova e Sistema Judiciário* (Coimbra Editora, 2010).

Pradillo, J. C., “Nuevas medidas tecnológicas de investigación criminal para la contención de prueba electrónica”, in J. P. Gil (ed.), *El Proceso Penal en la Sociedad de la Información. Las Nuevas Tecnologías para Investigar y Probar el Delito* (La Ley, 2012).

Ramos, A., *A Prova Digital em Processo Penal: O Correio Eletrónico* (Chiado Editora, 2014).

Sani, A., *Temas de Vitimologia* (Almedina, 2011).

Santos, C. C., *A Justiça Restaurativa. Um Modelo de Reacção ao Crime Diferente da Justiça Penal. Porquê, Para Quê e Como?* (Coimbra Editora, 2014).

Santos, G., e Cruz, J., “Crime de Colarinho Branco e Crime Comum: Um Contraponto”, *Revista de Investigação Criminal* N.º 8 (ASFIC/PJ, 2015), 52-70.

Schneider, F., “Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings”, Paper (2019), 19, disponível em: <http://www.xn--geldwschecompliance-kwb.de/media/files/Schneider.pdf>, consultado em 13 de fevereiro de 2019.

Sousa, A., *Branqueamento de Capitais. Enquadramento Legal e Análise Comparativa*, Dissertação de Mestrado, (2015), disponível em: http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/7876/1/Adriana_Sousa_MCV_2015.pdf, consultado em 14 de fevereiro de 2017.

Venâncio, P., *Lei do Cibercrime: Anotada e Comentada*. (Coimbra Editora, 2011).

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O DIREITO PENAL COMO INSTÂNCIA DE CONTROLO SOB O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Fernando Conde Monteiro

*Professor da Escola de Direito da Universidade do Minho
cmonteiro@direito.uminho.pt*

Resumo: O presente discurso assume-se como uma reflexão, a partir do direito penal, enquanto instância formal de controlo social e com os seus pressupostos epistemológicos, sobre o impacto que as novas tecnologias de informação podem ter relativamente ao mesmo.

Palavras-chave: Direito penal – Tecnologias de informação – Ética – Empirismo.

1. Introdução

O nosso texto constitui uma reflexão a partir do direito penal como instância formal de controlo. Nos nossos dias, assiste-se a um desenvolvimento notável das tecnologias de informação. Este facto repercute-se ou pode repercutir-se no direito penal enquanto instância formal de controlo do crime? O antigo paradigma liberal de uma lei penal mínima (a existir ainda) pode sobreviver a esse impacto, nomeadamente num futuro mais ou menos próximo? Estaremos deste modo diante de uma dissolução pura e simplesmente do direito penal? Ou perante um seu novo paradigma?

Estas são algumas questões fundamentais a que pretendemos responder no nosso estudo.

2. Direito penal: conceito

O direito penal tem um propósito fundamental. Este propósito consiste em controlar a atividade criminosa¹.

Para executar este desiderato, o direito penal descreve antes de mais o seu objeto, através da proibição de ações e da exigência de comportamentos positivos, acompanhando ambos dos seus pressupostos². Tal constitui o lado ético do direito penal (ética penal)³. Significa assim uma escolha complexa entre valores e tipos de comportamentos que os colocam em risco ou produzem lesões⁴. Constitui, por outro lado, uma consequência (entre outras) da interação humana⁵. De qualquer forma, fatores empíricos também estão aqui presentes: vida, integridade física, saúde, coisas materiais, agressões contra valores, intenções, etc. têm um elemento empírico óbvio. Portanto, este aspeto encontra-se largamente neste âmbito⁶. De qualquer forma, o ponto fundamental a considerar é constituído pelo *dever-ser*. O que em todo o caso não significa que o lado empírico possa mesmo assumir-se, em certas situações, como determinante da questão ética. Assim, por exemplo, a intervenção jurídico-penal pode revelar-se ineficaz, por via de relevantes aspetos empíricos, que deste modo condicionem irrefragavelmente a escolha ético-penal⁷.

¹ Vai longe o dia em que a ideia seria a eliminação do crime, neste sentido, J. de Maillard, *Crimes e Leis* (trad., Instituto Piaget, 1995), 7-8.

² Assim, F. Conde Monteiro, *Direito Penal I* (Elsa-UMinho, 2015), 13.

³ Sobre isto, F. Conde Monteiro, “Algumas reflexões epistemológicas sobre o direito penal”, in M. Costa Andrade, M. J. Antunes, S. A. de Sousa (orgs.), *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias*, vol. II (Coimbra Editora, 2009), 760; “Ética e direito penal (Reflexões epistemológicas sobre as relações entre ética e direito penal em face do direito positivo português)”, in *Anuário Publicista da Escola de Direito da Universidade do Minho*, t. II, Ano de 2013, *Ética e Direito* (Escola de Direito da Universidade do Minho, Departamento de Ciências Jurídicas Públicas, 2014), 46-48.

⁴ Sobre as noções de desvalor de ação e de resultado, F. Conde Monteiro, *Direito Penal I*, *supra* n. 2, 103.

⁵ Neste âmbito, F. Conde Monteiro, “Ética e direito penal...”, *supra* n. 3, 48.

⁶ Cf. neste sentido, F. Conde Monteiro, “O Problema da Verdade em Direito Processual Penal (Considerações Epistemológicas)”, in M. F. Monte (coord.), M. C. Calheiros, F. Conde Monteiro, F. N. Loureiro (dirs.), *Que Futuro para o Direito Processual Penal?* (Coimbra Editora, 2009), 327-329.

⁷ Sobre o fenómeno da descriminalização, J. Figueiredo Dias e M. Costa Andrade, *Criminologia* (Coimbra Editora, 1984), 397-434.

Além disso, é necessário considerar o lado empírico do direito penal como critério fundamental decisório em contraste com a perspectiva ética⁸. Tal significa basicamente uma escolha, igualmente, agora entre realidades empíricas. Deste modo, a questão é: como deve o legislador prosseguir a ideia fundamental de controlar o crime em termos de ferramentas e meios empíricos? Isto também constitui uma questão muito complexa. Em termos ideais, poderíamos usar unicamente para executar esta proposição, por exemplo, sanções, desde a pena de morte até simples censuras. Poderíamos também discutir o tipo de consequências ou medidas, por exemplo, penalidades ou medidas de segurança. Igualmente se a escolha das consequências do crime deveria ser feita em geral ou em função de crimes específicos. Poderíamos mesmo pensar no momento da sua aplicação, se depois ou antes da prática de crimes, etc. Por outro lado, temos efetivamente muita falta de conhecimento científico neste campo. Praticamente, o grosso neste âmbito deriva basicamente da experiência histórica e presente⁹. De qualquer forma, os instrumentos mais utilizados e documentados nas diferentes legislações são sanções (geralmente, prisão e multa), ao lado de medidas de segurança, aplicadas minoritariamente¹⁰. Por outro lado, não se trata aqui de uma mera questão de facto. O problema ético encontra-se igualmente presente. Por outras palavras, a escolha das ferramentas empíricas, o seu âmbito de aplicação, os seus limites, etc. são também sujeitos a uma ponderação valorativa jurídico-penal¹¹.

Em conclusão, o crime apresenta dois aspetos fundamentais a considerar: a ética jurídico-penal e o lado empírico. Estas realidades entrelaçam-se mutuamente, contribuindo deste modo para o estabelecimento das bases da infração penal: a sua definição e o seu modo de operar.

3. Criminologia: o conceito

A criminologia é geralmente apresentada como a ciência do crime. Procura deste modo entender este e como controlá-lo. Tem assim um objeto: o aludido crime, que, naturalmente, como realidade social que antes de mais é, apresenta-se como uma combinação de elementos éticos com aspetos empíricos, como anteriormente fizemos referência relativamente ao direito penal. O controlo das infrações penais implica também os dois fatores com predominância

⁸ Sobre isto, F. Conde Monteiro, “Ética e direito penal...”, *supra* n. 3, 54-56.

⁹ Relativamente aos problemas epistemológicos neste âmbito implicados, F. Conde Monteiro, “Algumas reflexões epistemológicas...”, *supra* n. 3, 757.

¹⁰ Sobre o problema em geral do monismo/dualismo, F. Conde Monteiro, *Consequências Jurídico-Penais do Crime* (Elsa-UMinho, 2015), 17-19.

¹¹ Neste sentido, *idem, ibidem*, 15.

dos elementos empíricos limitados por considerações éticas, como também já deixámos dito. Em consequência de tudo isto, temos metodologias efetivamente quantitativas e qualitativas nesta disciplina¹².

4. Política criminal: noção

A política criminal apresenta-se com o objetivo de controlar o crime. Para executar este objetivo, tem como meio o estudo da infração penal e os processos para controlá-la¹³. Deste modo, é óbvia a estreita ligação entre esta disciplina, o direito penal e também a criminologia. Neste último caso, a coincidência é praticamente total. Desta forma, quando falamos de política criminal, falamos simultaneamente em maior ou menor medida sobre direito penal e criminologia.

5. A ciência jurídica criminal¹⁴

A ciência criminal assume-se acima de tudo como uma perspetiva crítica do crime. Tal implica, por consequência, como ponto de partida, a tomada de posição sobre a questão epistemológica desta designada ciência. Portanto, a crítica de todos os sistemas concretos de direito penal ao redor do mundo nos âmbitos ético e empírico é algo a que não pode naturalmente renunciar. A partir daqui, obviamente que o ponto de chegada pode constituir uma hipotética aceitação em geral dos sistemas criminais ou o seu repúdio total ou ficar em meios-termos. Como igualmente poderá aceitar um direito penal concreto, em geral ou em parte. Também, com certeza, que se poderá criar um direito penal diferente em relação à totalidade dos sistemas. Pode, por fim, acontecer a criação de algo completamente diferente das formas de controlo do crime através do direito penal, etc.

As metodologias usadas para garantir esse objetivo não estão desde logo limitadas à partida. Da simples opinião às estatísticas, tudo pode ser usado em função do objeto e da finalidade. Esta é uma consequência lógica do caráter híbrido desta disciplina, onde os aspetos éticos e empíricos são omnipresentes.

Assim, em consequência de tudo isso, não há possibilidade de distinção entre ciência do crime, criminologia ou mesmo política criminal. Todas essas disciplinas estudam o crime, têm um ponto de vista crítico, usam múltiplas metodologias, assumem como desiderato controlar o crime.

¹² Sobre estas, J. Figueiredo Dias e M. Costa Andrade, *supra* n. 7, 117-167.

¹³ Cf., neste âmbito, *idem, ibidem*, 104-113.

¹⁴ Sobre este tema, cf. F. Conde Monteiro, "Algumas reflexões epistemológicas...", *supra* n. 3, 760.

6. O contexto da política criminal

6.1. Introdução

A intervenção do direito penal é uma entre outras formas que a sociedade possui para a defesa dos seus interesses, enquanto tal. Basicamente, neste âmbito, podemos considerar intervenções informais e formais.

6.2. Intervenções informais

Família, vizinhos, amigos, escola, igrejas, opiniões públicas, entre outros, podem constituir exemplos de instâncias informais de controlo do crime¹⁵. Em geral, estas entidades contribuem para a socialização da pessoa, mas, numa minoria de casos, podem influenciar a prática de infrações criminais. De facto, é reconhecido, por exemplo, a influência das famílias não estruturadas na delinquência juvenil, da religião no terrorismo, de amigos na prática de crimes, etc. De qualquer forma, a sua relevância para o controlo criminal é inegável, contribuindo deste modo para a estabilização das sociedades. Por outro lado, é igualmente inegável a sua insuficiência para executar em plenitude esta sua função¹⁶. Por isso, em todos os Estados ao redor do mundo, também existem instâncias formais de controle.

6.2.1. Prevenção situacional

Desde tempos remotos até aos nossos dias, o ser humano usou muitas ferramentas diferentes para prevenir a prática de crimes. Efetivamente, do simples uso de animais até à utilização moderna de alta tecnologia, a lista de métodos nesta matéria é praticamente infinita¹⁷.

6.2.2. Intervenções formais

6.2.2.1. Intervenções preventivas gerais.

Particularmente nos Estados modernos, existem muitas políticas executadas pela maioria dos Estados que têm como objetivo a integração dos cidadãos nas suas sociedades. Da educação à saúde até ao apoio social, à cultura, ao desporto, etc., existem muitas instituições e práticas que criam e desenvolvem aptidões académicas e profissionais dos cidadãos, contribuem para a sua integração

¹⁵ Sobre isso, M. Cusson, *Criminologia* (trad., Casa das Letras, 2.ª ed., 2007), 200-204.

¹⁶ V. Krey, *Deutsches Strafrecht, AT, Band I, 3. Auf.* (Kohlhammer, 2008), 1.

¹⁷ M. Cusson, *supra* n. 15, 204-210.

social e profissional, enfim, promovem em geral o seu bem-estar¹⁸ e, portanto, fazem com que estes sejam menos propensos a cometer crimes, particularmente relacionados com as deficiências na socialização.

6.2.2.2. *Intervenções preventivas específicas:*

6.2.2.2.1. *Serviços de inteligência.* Nos nossos Estados, existem serviços de inteligência que, entre outras, têm a função importantíssima de prevenir a prática de crimes ou atos contra a segurança do Estado através do uso de informações e ações para atuar em conformidade com os comportamentos de risco detetados. Eles são, obviamente, a primeira linha para evitar a prática de certos crimes e, em geral, promover a segurança de todos (Estados)¹⁹.

6.2.2.2.2. *Políticas concretas para evitar riscos de certos crimes.* Um dos aspetos importantes para prevenir crimes diz respeito a políticas específicas que os Estados executam para reduzir ou eliminar a concretização de certos crimes. Da prevenção de incêndios ao internamento compulsivo de pessoas perigosas, há muitas políticas neste campo a ser consideradas. A sua natureza pode abranger diferentes tipos de intervenções, tais como campanhas de saúde, cursos de educação, ações de alerta, etc.

6.2.2.2.3. *Polícias.* Os diferentes tipos de polícias existentes nos Estados modernos constituem uma parte essencial da prevenção da prática de crimes²⁰. Esta função não se encontra somente dirigida à infração penal, mas também em relação a outras espécies de infrações (contraordenações, por exemplo). Portanto, neste último aspeto, podemos falar de um duplo efeito em termos de prevenção: prevenção de comportamentos preventivos (de crimes) ou *prevenção de prevenção*.

6.2.2.2.4. *Ministério Público.* O Ministério Público tem fundamentalmente uma ação de repressão do crime. No entanto, também desempenha um papel na prevenção, nomeadamente em articulação com as polícias²¹.

¹⁸ Que se pode mesmo inserir *cum grano salis* na ideia de saúde inerente à Organização Mundial de Saúde, caracterizada por “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. Sobre o estado social, por exemplo, F. Castles *et al.*, *The Oxford Handbook of The Welfare State* (Oxford University Press, 2012); sobre a Constituição Portuguesa, cf. artigos 24.º e segs. da mesma.

¹⁹ Para se obter um panorama de alguma da principal bibliografia sobre esta temática, consultar http://intellit.muskingum.edu/sources_folder/sourcesmajor.html, acesso em 07/07/2017.

²⁰ Como *first-line enforcer* é usualmente designada a polícia no combate à criminalidade – J. Figueiredo Dias e M. Costa Andrade, *supra* n. 7, 443.

²¹ Cf., no caso português, desde logo com o artigo 3.º, n.º 1, alínea i), da Lei n.º 47/86, de 15 de outubro.

6.2.2.2.5. *Advogados*. Os advogados não têm o dever formal de prevenir crimes, mas podem desempenhar um papel mais ou menos relevante através do aconselhamento e da prestação de apoio legal aos seus clientes.

7. O direito penal como instância de controlo

7.1. Primeiro controlo

7.1.1. A existência da lei penal

A existência de leis escritas de natureza penal pode ser vista como uma primeira forma de prevenir crimes. Efetivamente, apesar de tudo o que podemos dizer sobre esse aspeto, o certo é que é em torno da lei que as instâncias formais atuam. Naturalmente que a reação em função da prática dos crimes é o fulcro da sua funcionalidade²².

7.2. Segundo controlo

7.2.1. Características gerais

Em geral, os sistemas penais são reativos, como afirmámos. Atuam após a prática dos crimes. São igualmente punitivos. Excecionalmente, são puramente preventivos (caso das medidas de segurança).

7.2.2. Funções

7.2.2.1. Do ponto de vista punitivo.

A função punitiva em relação aos sistemas de direito penal está vinculada à ideia de prevenção. Após a prática de um crime, o único facto empírico a considerar em termos de proteção é, naturalmente, a prevenção de crimes no futuro, quer relativamente ao concreto delinquente, quer a potenciais. E se lidarmos com o castigo, é natural que a sanção em relação ao futuro crie ou intente criar uma inibição para os seus destinatários (potenciais criminosos). Assim, estamos diante da prevenção especial de intimidação (em relação ao infrator) e na presença da prevenção geral de intimidação (em relação aos outros criminosos potenciais)²³.

De qualquer forma, outra ideia de prevenção foi desenvolvida nesta matéria. Com a punição do crime, o desiderato fundamental seria o de restaurar

²² Sobre tudo isto, F. Conde Monteiro, *Direito Penal I*, *supra* n. 2, 32.

²³ *Idem*, *ibidem*.

a paz, a confiança nas normas, valores e instituições afetados pela sua prática. Estaríamos deste modo perante a prevenção geral positiva²⁴.

7.2.2.2. Do ponto de vista da socialização.

A socialização é um grande vetor dos modernos sistemas penais. Efetivamente, este tópico constitui, em larga medida, uma consequência de uma questão ética, a saber, a ideia de que o direito penal deve ser limitado por considerações axiológicas, como dissemos antes. Isto significa basicamente que a socialização, em termos de significado negativo (as consequências jurídico-penais devem, se possível, evitar-se, caso sejam muito negativas para esta) e na sua expressão positiva (essas consequências podem e terão mesmo de contribuir para a reintegração dos condenados na sociedade, na medida do possível), deve, em princípio²⁵, limitar a função de prevenção (geral e individual) no plano da punibilidade²⁶. Algo que naturalmente adquire um significado fundamental para a esfera jurídica do condenado, preservando-a. Por outro lado, há também uma conexão entre este uso e os juízos éticos inerentes à culpa. Por exemplo, a intensidade do dolo ou a qualidade da motivação do delinquente podem adquirir o mesmo sentido para a ressocialização e culpa. Naturalmente que também haverá diferenças e até oposição, um severo juízo de culpa no momento da prática do crime pode ser uma desvantagem para a necessidade de uma penalização leve no momento do julgamento, prejudicando a ressocialização do delinquente. De resto, a conexão da socialização com o aspeto empírico (*lato sensu*) do direito penal também é óbvia. A permanência dos condenados na sociedade e o apoio do sistema de direito penal à sua reabilitação são, naturalmente, formas de prevenção de crimes relativamente aos delinquentes e, portanto, constituem uma proteção à comunidade²⁷. Certamente que neste plano há lugar a muitas questões não resolvidas²⁸. Nunca, por outro lado, conheceremos o *design* do sistema penal perfeito, estando mesmo muito longe disso. Deste modo, mais ou menos

²⁴ Sobre isto, *idem, ibidem*, 33.

²⁵ A referência à expressão em causa justifica-se para poder salvaguardar casos (excepcionais) em que eventualmente a espécie da pena ou sua medida se devam aplicar no plano de uma maior gravidade para o delinquente, por via de a sua socialização passar por aí.

²⁶ F. Conde Monteiro, *Direito Penal I*, *supra* n. 2, 28-29.

²⁷ F. Conde Monteiro, “Algumas reflexões epistemológicas...”, *supra* n. 3, 774-776.

²⁸ Lembremos desde logo os ataques feitos à ressocialização na modernidade a partir do anátema de Martisson e de toda a discussão infundável sobre este tópico até hoje.

caos estará sempre aqui presente. De qualquer forma, podemos construir uma solução razoável (pelo menos, como uma profissão de fé)²⁹.

7.2.2.3. Do ponto de vista da segurança.

A ideia de segurança foi desenvolvida através das medidas com este mesmo nome. Com elas o propósito era/é a recuperação ou, em última instância, o isolamento do delinquente, mesmo a sua inocuidade. Se esta perspectiva nunca se tornou efetivamente dominante, de qualquer forma, os sistemas penais em geral possuem-na, ainda que num plano secundário³⁰.

7.2.2.4. Considerações éticas.

Como dissemos antes, o funcionamento do sistema criminal não é imune a considerações éticas. Estas estão, antes de tudo, presentes na escolha e caracterização das condutas que coloquem em causa os bens jurídicos a proteger³¹. Num segundo momento, na seleção global de consequências legais do direito penal³². Num terceiro momento, na aplicação concreta das consequências jurídico-penais. Assim, tal expressa um princípio geral de proporcionalidade nesta matéria³³. Em relação à punibilidade, a expressão deste princípio assume a forma de culpa. Deste modo, esta categoria expressa fundamentalmente um juízo ético que barra (ou possui a intenção de fazê-lo)³⁴ a intervenção de considerações preventivas acima do seu limite³⁵. Não é, finalmente, imune a considerações empíricas³⁶.

²⁹ Sobre isto, cf. F. Conde Monteiro, “O Direito Penal como Expressão de Jogos de Lotaria ou uma Reflexão Epistemológica sobre a Aleatoriedade neste Ramo Jurídico”, in M. Costa Andrade *et al.* (orgs.), *Direito Penal, Homenagem ao Prof. Peter Hünerfeld* (Coimbra Editora, 2013), 595-611.

³⁰ Sobre isto, F. Conde Monteiro, *Direito Penal I*, *supra* n. 2, 25-28.

³¹ Cf. *idem*, *ibidem*, 103.

³² Neste âmbito, F. Conde Monteiro, *Consequências Jurídico-Penais do Crime*, *supra* n. 10, 16.

³³ Cf., neste sentido, *idem*, *ibidem*, 59.

³⁴ De notar que esta função-limite a desempenhar pelo princípio da culpa apresenta questões epistemológicas insolúveis, dada a sua óbvia fragilidade epistemológica ao nível da sua fundamentação e no plano da sua concreta efetivação (F. Conde Monteiro, *Direito Penal I*, *supra* n. 2, 35-36), onde, tendo em conta a sua indeterminabilidade, nem a violação do princípio da igualdade não deixa de ter lugar [neste último sentido, pioneiros entre nós, M. Simas Santos e Correia Ribeiro, *Medida Concreta da Pena, Disparidades* (Vislis, 1998)].

³⁵ Neste sentido, por todos, entre nós, J. Figueiredo Dias, *Direito Penal Português* (Aequitas, 1993), 73.

³⁶ F. Conde Monteiro, *Consequências Jurídico-Penais do Crime*, *supra* n. 10, 66-67.

Em relação às medidas de segurança, devemos considerar neste plano axiológico a presença indispensável de um princípio de proporcionalidade³⁷.

7.2.2.5. A negociação como fuga ao sistema ou à sua rigidez.

A negociação sobre o crime pode essencialmente revestir duas formas. De um lado, poderemos encontrar-nos perante um acordo relativo à medida, substituição ou mesmo à renúncia da pena. Neste plano, por exemplo, entre outros modelos³⁸, poderemos considerar o *plea bargaining* norte-americano em que Ministério Público e Defensor negociam os termos de um acordo sujeito à homologação do juiz³⁹. Em essência, encontrar-nos-emos perante quadros de atuação ainda movidos nos limites de uma estrutura jurídico-penal. Já outras formas de negociação podem ter lugar completamente ao lado do sistema jurídico-penal e com referentes a ele opostos, constituindo eventualmente sistemas alternativos aos referentes caracterológicos do direito penal⁴⁰.

7.2.3. Síntese

Em geral, os sistemas de direito penal caracterizam-se por ser sistemas essencialmente punitivos; num plano secundário encontramos o modelo de segurança a coexistir com o primeiro. A função dominante dos sistemas é preventiva, através da reação à prática de infrações, nela se inserindo, além da intencionalidade intimidativa, finalidades de socialização e de, eventualmente, paz social. A negociação pode ser utilizada como válvula de atenuação ou escape do sistema.

7.2.4. Crítica do modelo padrão

7.2.4.1. Ponto de vista político-criminal:

7.2.4.1.1. O ponto de partida do direito penal geral: punição e segurança.
Um sistema com estas características apresenta um óbvio caráter utópico: antes de mais, nunca poderemos saber qual será o melhor sistema penal, sequer se

³⁷ Sobre isto, *idem, ibidem*, 117-129, *passim*.

³⁸ Neste âmbito se pode situar, por exemplo, entre nós, o arquivamento em caso de dispensa da pena (artigo 280.º, n.º 2, do Código de Processo Penal Português) ou a suspensão provisória do processo penal (artigos 281.º e 282.º do Código de Processo Penal Português).

³⁹ Sobre este modelo no quadro norte-americano, J. Figueiredo Dias e M. Costa Andrade, *supra* n. 7, 483-491; P. S. de Albergaria, *Plea Bargaining: Aproximação à Justiça Negociada nos E.U.A.* (Almedina, 2007).

⁴⁰ Sobre os crimes particulares *latu sensu* e sua relevância neste âmbito, J. Figueiredo Dias, *Direito Processual Penal, Lições do Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias* (coligidas por Maria João Antunes, Secção de Textos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1989-9), 91; relativamente à justiça restaurativa, cf., neste sentido, por exemplo, U. C. Eiras Nordenstahl, *Mediación Penal, De la Práctica a la Teoría* (Librería Histórica, 2005).

este modelo é efetivamente necessário⁴¹. Além disso, a opção por sanções punitivas gerais cria problemas de adequação, naturalmente não resolvidos em relação a diferentes tipos de crimes com diferentes motivações e contextos, seja numa perspetiva empírica, seja do ponto de vista ético. De resto, a escolha da medida das penalidades é obviamente questionável, como o processo da sua aplicação⁴².

Além de tudo, há uma questão crucial a considerar. O êxito de qualquer sistema jurídico-penal depende em muito larga medida da sua capacidade reativa em face das violações das suas normas. Efetivamente, desde a certeza antecipadamente do seu funcionamento em caso da prática de ilícitos até à certeza do seu contrário (não funcionamento neste plano), há toda uma série de possibilidades que se podem desenhar neste âmbito: altas, poucas, médias, etc. Além do lado objetivo da efetividade deve considerar-se o seu lado subjetivo, isto é, o grau de convicção do potencial agente de que poderá ser descoberto e punido pelo sistema. Nem sempre haverá lugar a uma relação de proporcionalidade entre estas duas realidades. Uma alta probabilidade de funcionamento do direito penal pode não ser apreendida pelo agente em causa, por múltiplas circunstâncias (v.g., otimismo exagerado nas suas próprias capacidades de iludir o sistema, desconsideração de determinada prova, etc.), como, ao invés, uma pouca probabilidade de efetivação da punição pode não ser perceptível pelo potencial delinquente, que assim pode desistir do seu intento, por exemplo. De resto, o agente pode ser totalmente insensível ao funcionamento do sistema penal (v.g., bombista suicida, criminoso por convicção, etc.) ou mesmo nem sequer representar tal facto (v.g., negligência inconsciente). De qualquer maneira, a ideia inicialmente referida de que político-criminalmente um sistema jurídico-penal será tanto mais bem-sucedido quanto maior eficácia demonstrar na prática continua a ser, nos nossos dias, inteiramente válida⁴³.

Chegados aqui, a questão que colocamos é simplesmente a de saber se, nas nossas sociedades, apetrechadas cada vez mais de tecnologia informativa, onde o espaço de privacidade se tem reduzido substancialmente, por via disso mesmo e tendo igualmente em conta o alargamento da eficiência no que toca a provas (v.g., prova genética, videovigilância, gravações, etc.), não estaremos no caminho de uma revolução ao nível jurídico-penal em que mais e mais vezes o

⁴¹ Sobre isto, F. Conde Monteiro, "Crime e Democracia: Algumas Reflexões Epistemológicas sobre o Papel do Direito Penal na Defesa dos Valores do Estado de Direito Democrático e Social da Constituição da República Portuguesa", in Álvaro Balsas (org.), *Política e Filosofia I: A Democracia em Questão (Politics and Philosophy I: Democracy in Question)* [Evocatio Prof. Doutor Bacelar e Oliveira, SJ (1916-1999), Vol. 72, Fasc. 4, 2016], 180-1182.

⁴² Neste sentido, F. Conde Monteiro, "O Direito Penal como Expressão de Jogos de Lotaria...", *supra* n. 29, 608-611; cf., com interesse, M. Simas Santos e Correia Ribeiro, *supra* n. 34.

⁴³ Neste sentido, J. Figueiredo Dias, *Direito Penal I*, t. I (Coimbra Editora, 2.ª ed., 2007), 52.

grau de alta probabilidade, se não mesmo de certeza da sua aplicação, se tornem em realidades comuns.

7.2.5. As sociedades reais sob o imperium da tecnologia da informação: do ser humano transparente à opacidade do mesmo

7.2.5.1. Comunicação e artificialidade.

Nunca como hoje houve lugar tão facilmente ao acesso ao outro. A espécie humana passou de certa maneira a ser considerada a partir de um conceito abstrato para aparentemente uma realidade concreta. Se no passado e ainda hoje contactamos com os nossos parentes, amigos e vizinhos, atualmente estabelecemos facilmente contacto com o nosso próximo, que pode ser muito provavelmente ninguém, isto é, qualquer pessoa que calhe. Por outro lado, este contacto é fundamentalmente mediatizado por um instrumento tecnológico de cariz comunicacional, o que lhe confere características próprias em contraposição com as relações humanas diretas. Efetivamente, estamos perante um ser humano fundamentalmente construído, a maior parte das vezes, por ele próprio ou ainda por terceiros, mas sem que possamos geralmente ter a confirmação da realidade das descrições (desde logo pela distância e pela impossibilidade de o identificarmos de facto). É assim um ser que nos advém por um processo virtual e que naturalmente se assume desta mesma forma. Portanto, se a comunicação nos aproxima, também, por outro lado, não anula a distância. Para todos os efeitos, encontramos-nos em definitivo perante um ser virtual ou não sabemos da sua natureza efetivamente real⁴⁴. O artifício é deste modo o veículo e o produto desta comunicação.

7.2.5.2. Vigilância e devassa da privacidade.

Nunca também como nos nossos dias a vigilância se exerceu de forma tão avassaladora. Se o século XX se caracterizou pela implementação de fortes dispositivos de vigilância, maioritariamente humanos, fundamentalmente no âmbito dos Estados totalitários, agora esta mesma vigilância democratizou-se, perdendo o seu caráter ideológico, de todo. Efetivamente, a nossa vida é diariamente monitorizada. Desde a simples utilização da internet, sem mais, até ao exercício da atividade profissional, passando pelo lazer, família, amigos; tudo de facto é objeto de atenta vigilância. De resto, o nosso contributo para tal devassa não é deveras pouco significativo. Prestamos aos outros muito entusiasticamen-

⁴⁴ Podemos deste modo caracterizar, neste plano, três arquétipos na evolução da humanidade. Num primeiro momento, desde os tempos em que éramos caçadores-coletores até às sociedades agrícolas, em que dominavam as relações num plano concreto (*homem concreto*); depois, com a industrialização, em que a criação das urbes produziu o anonimato nas inter-relações (*homem anónimo*); finalmente, com o advento das tecnologias de informação, caracterizando a comunicação pela virtualidade (*homem virtual*).

te, com maior ou menor abundância, informações sobre nós próprios, amigos, conhecidos, etc.⁴⁵. Vivemos deste modo sob o signo da transparência. Desejamos o conhecimento dos outros e, por via disso, damo-nos a conhecer em troca.

7.2.5.3. Vigilância e crime.

No contexto que deixámos referido, encontramos-nos assim perante o abrir de portas a uma hipotética sociedade em que se levasse a cabo a total monitorização do ser humano. Deste modo, a certeza ou, pelo menos, a altíssima probabilidade de aplicação do direito penal seria definitivamente alcançada. E se neste caso ainda não se poderia extinguir o crime definitivamente, pois sempre poderia haver lugar à prática de infrações penais em que o respetivo agente não se importasse ou nem sequer pensasse nas consequências judiciais das mesmas, o certo é que as taxas de criminalidade seriam reduzidas a níveis pouco significativos, expressando deste modo o bom fundamento da ideia de que a certeza ou alta probabilidade da aplicação de sanções penais constitui o melhor antídoto para o combate eficaz do crime⁴⁶.

Um modelo deste teor, que já esteve bem mais longe do que atualmente sucede e no futuro poderá vir a acontecer, tem, no entanto, contra si desde logo um argumento muito importante. A extrema e mesmo absoluta devassa do ser humano significaria a máxima informação sobre o indivíduo e, portanto, a conexão ao titular da mesma do máximo poder. Uma tal relação, pelo seu abismal desequilíbrio, levaria inevitavelmente ao domínio (escravidão) do monitorizado pelo monitor. Estaríamos deste modo em face de um novo totalitarismo de cariz tecnológico, mas nem por isso de menor gravidade do que os que o antecederam. Dir-se-ia deste modo que o doente morreria da cura. Noutras palavras, o preço a pagar pelo controlo do crime seria simplesmente in comportável. Nem sequer a existência de eventuais mecanismos de defesa do sigilo ou uso indevido da informação a ser obtida seriam garantia da sua efetiva preservação. O risco de um abuso geral e totalitarismo terem efetivamente lugar seriam por demais óbvios e, assim, inaceitáveis. Algo que se aplicaria igualmente em caso de atuações preventivas do crime.

8. Conclusão

Sem dúvida que a ideia político-criminal de melhorar a eficácia do direito penal no sentido do seu funcionamento altamente provável é o melhor antídoto para combater o crime. No entanto, deve-se também neste plano ser cauteloso e

⁴⁵ Sobre o impacto avassalador do *Facebook* nas nossas vidas, apenas num plano estatístico, consultar https://facestore.pt/estatisticas_do_facebook, acesso em 12/07/2017.

⁴⁶ *Supra* n. 43.

fazer aqui funcionar um princípio da proporcionalidade que limite a eficácia do direito penal em nome da preservação da dignidade da pessoa humana, isto é, nunca sacrificando o seu núcleo essencial axiológico, princípio básico de qualquer Estado democrático e de direito⁴⁷.

Bibliografia

Albergaria, P. S. de, *Plea Bargaining: Aproximação à Justiça Negociada nos E.U.A.* (Almedina, 2007).

Castles, F., et al., *The Oxford Handbook of The Welfare State* (Oxford University Press, 2012)

Conde Monteiro, F., “Algumas reflexões epistemológicas sobre o direito penal”, in M. Costa Andrade, M. J. Antunes, S. A. de Sousa (orgs.), *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias*, vol. II (Coimbra Editora, 2009).

_____, “O Problema da Verdade em Direito Processual Penal (Considerações Epistemológicas)”, in M. F. Monte (coord.), M. C. Calheiros, F. Conde Monteiro, F. N. Loureiro (dirs.), *Que Futuro para o Direito Processual Penal?* (Coimbra Editora, 2009).

_____, “O Direito Penal como Expressão de Jogos de Lotaria ou uma Reflexão Epistemológica sobre a Aleatoriedade neste Ramo Jurídico”, in M. Costa Andrade et al. (orgs.), *Direito Penal, Homenagem ao Prof. Peter Hünerfeld* (Coimbra Editora, 2013).

_____, “Ética e direito penal (Reflexões epistemológicas sobre as relações entre ética e direito penal em face do direito positivo português)”, in *Anuário Publicista da Escola de Direito da Universidade do Minho, t. II, Ano de 2013, Ética e Direito* (Escola de Direito da Universidade do Minho, Departamento de Ciências Jurídicas Públicas, 2014).

_____, *Direito Penal I* (Elsa-UMinho, 2015).

_____, *Consequências Jurídico-Penais do Crime* (Elsa-UMinho, 2015).

⁴⁷ Colocando a ênfase na liberdade no que se refere à dignidade humana, J. Miranda e A. Cortês, *Constituição Portuguesa Anotada*, t. I (Almedina, 2.ª ed., 2010), 78, que perentoriamente afirmam: “Uma sociedade que respeita a dignidade da pessoa humana é aquela em que as pessoas são reconhecidas como pólos de liberdade.”

_____, “Crime e Democracia: Algumas Reflexões Epistemológicas sobre o Papel do Direito Penal na Defesa dos Valores do Estado de Direito Democrático e Social da Constituição da República Portuguesa”, in Álvaro Balsas (org.), *Política e Filosofia I: A Democracia em Questão (Politics and Philosophy I: Democracy in Question)* [Evocatio Prof. Doutor Bacelar e Oliveira, SJ (1916-1999), Vol. 72, Fasc. 4, 2016].

Eiras Nordenstahl, U. C., *Mediación Penal, De la Práctica a la Teoría* (Librería Histórica, 2005)

Figueiredo Dias, J., *Direito Processual Penal, Lições do Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias* (coligidas por Maria João Antunes, Secção de Textos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1989-9).

_____, *Direito Penal Português* (Aequitas, 1993).

_____, *Direito Penal I*, t. I (Coimbra Editora, 2.^a ed., 2007).

Figueiredo Dias, J., e Costa Andrade, M., *Criminologia* (Coimbra Editora, 1984).

Krey, V., *Deutsches Strafrecht, AT, Band I, 3. Auf.* (Kohlhammer, 2008).

Maillard, J. de, *Crimes e Leis*, (trad., Instituto Piaget, 1995).

Miranda, J., e A. Cortês, A., *Constituição Portuguesa Anotada*, t. I (Almedina, 2.^a ed., 2010).

Simas Santos, M., e Correia Ribeiro, *Medida Concreta da Pena, Disparidades* (Vislis, 1998).

DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA DE GÊNERO:

REFLEXÕES SOBRE A SITUAÇÃO DA GUINÉ-BISSAU

Joana Torres

Faculdade de Direito da Universidade do Porto e Universidade da Maia-ISMAI

joanat@ufp.edu.pt

Joana Topa

Universidade da Maia-ISMAI e Centro Interdisciplinar de Estudos de Género

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa (CIEG/ISCSP-ULisboa)

jtopa@ismai.pt

Resumo: Na Guiné-Bissau, a violência de género continua a ser uma presença inequívoca e constante na vida de milhares de mulheres e jovens raparigas guineenses^{1/2}. Apesar de nos últimos anos se ter feito alguns avanços no que diz respeito à igualdade de género no país, muito ainda há a fazer para assegurar os direitos e liberdades e, assim, prevenir a violência contra as mulheres. Este artigo tem como objetivo analisar, de uma forma crítica, a violência de género que continua a pontuar a realidade da sociedade guineense e que impactua com

¹ T. Moura, S. Roque, S. Araújo, M. Rafael e R. Santos, “Invisibilidades da guerra e da paz: Violências contra as mulheres na Guiné-Bissau, em Moçambique e em Angola” (2009), *Revista Crítica de Ciências Sociais* 86, 95-122, disponível em: <https://doi.org/10.4000/rccs.240>.

² J. Moreira, *A Cultura di Matchundadi na Guiné-Bissau: Género, Violências e Instabilidade Política* (Tese de Doutoramento, 2017), retirado de <https://www.iscte-iul.pt/tese/7237>.

os direitos fundamentais das mulheres guineenses, trazendo a debate as questões culturais e o papel que a criminologia ocupa na compreensão e combate a este tipo de situações.

Palavras-chave: Violência de género – Guiné-Bissau – Direitos humanos – Criminologia.

1. Introdução

A violência de género é um fenómeno global e transversal a todos os países do mundo, que afeta maioritariamente mulheres e jovens raparigas³. Sob a égide do sistema de dominação patriarcal sobre a mulher⁴, de uma ideologia social, historicamente balizada, que tem, ao longo de décadas, depreciado e desvalorizado o sexo feminino em detrimento do sexo masculino, a violência de género surge como um meio de controlo social, preconizado sobre o género, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado⁵, predominantemente feminino, inibindo do exercício dos seus direitos em liberdade e em pé de igualdade com os homens.

A violência de género assume diversas causas, formas e efeitos e todas elas coartam liberdades e garantias a todas as mulheres de que dela são vítimas, sendo por isso tido como um dos maiores atentados aos Direitos Humanos da era atual⁶, configurando-se como um problema de saúde pública de proporções epidémicas.

Historicamente, a Recomendação Geral do Comité das Nações Unidas (ONU) sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW Committee) reconheceu em 1992 que violência baseada em género é a “violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately” (artigo 6) e que “is a form of discrimination that seriously inhibits women’s ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality with men” (artigo 1)⁷.

³ S. Neves e D. Costa (orgs.), *Violências de Género* (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2017), 77,78.

⁴ I. Dias, “Violência Doméstica e de Género: Paradigmas e Debates Atuais”, in I. Dias (org.), *Violência Doméstica e de Género* (Pactor, 2018), 1-27.

⁵ J. Scott, “Género: uma categoria útil de análise histórica” (1995), *Educação & Realidade* 2, 71-99.

⁶ WHO, *Injuries and Violence – the Facts* (World Health Organization, 2014), disponível em: http://www.who.int/violence_injury_prevention/en, consultado em 13 de dezembro de 2020.

⁷ UN (1992), CEDAW Committee (1992), General Recommendation No. 19 on Violence against women, adopted at the 11th session, A/47/38, 29 January 1992.

Claro está que a violência de gênero interage com outros fatores como a cultura, religião, classe social, pobreza, conflitos, estilos de governação, que contribuem para a sua perpetuação ao longo dos tempos⁸.

África apresenta a maior prevalência de violência contra mulheres com uma taxa relatada de 40% em quase metade dos países africanos, o que acarreta inúmeras consequências tanto a nível da saúde mental como a nível da saúde física destas mulheres⁹. Se considerarmos que a violência de gênero surge como um indicador do valor social da mulher em qualquer sociedade, em alguns países africanos, esse indicador é deveras preocupante, com especial destaque para as zonas em conflito que ainda tendem a agravar mais a situação¹⁰.

A situação da Guiné-Bissau não é exceção. Apesar de a igualdade entre homens e mulheres constituir um direito fundamental consagrado na Constituição da Guiné-Bissau e nos instrumentos internacionais por ela ratificados, a violência de gênero continua a ser legitimada, estrutural e simbólica.

Este artigo pretende analisar criticamente as violências exercidas contra as mulheres na Guiné-Bissau, as condições que levam à sua legitimação e perpetuação, conceptualizando a importância da criminologia na prevenção e combate a este tipo de problemática.

2. A violência de gênero na Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau, situada na Costa Ocidental de África, tem cerca de 1874 milhões de habitantes (Banco Mundial, 2018)¹¹. O país tem um histórico de instabilidade política desde a sua independência em 1973/1974 e nenhum presidente eleito conseguiu completar com sucesso um mandato completo, o que tem complexificado o desenvolvimento do país.

Na Guiné-Bissau, a violência contra as mulheres nem sempre foi encarada como violação dos direitos humanos. Num país onde a violência estrutural é inequívoca, onde os problemas se acumulam ao nível económico, político, governativo e onde, na última década, se assistiu ao empobrecimento de grande

⁸ I. Dias, *supra* n. 4.

⁹ Breiding et al., *Intimate Partner Violence Surveillance* (2015), disponível em: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv/intimatepartnerviolence.pdf>, consultado em 29 de novembro de 2020.

¹⁰ M. Hossain, C. Zimmerman, L. Kiss, T. Abramsky, D. Kone, M. Bakayoko-Topolska, J. Annan, H. Lehmann e C. Watts, "Working with men to prevent intimate partner violence in a conflict-affected setting: a pilot cluster randomized controlled trial in rural Côte d'Ivoire" (2014), *BMC Public Health* 1,13.

¹¹ Disponível em: <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.

parte da população, com a degradação das condições de vida após o conflito¹², analisar as violências sofridas pelas mulheres não ocupa uma preocupação central, podendo mesmo ser considerada como irrelevante.

A violência estrutural existente no país, caracterizada pela violação dos direitos humanos, pela injustiça social, pelo poder desigual e pela violência leva a cenários de fome, miséria, doença e/ou morte bem como propicia a criminalidade e violência social¹⁷. A situação é de tal forma grave e estrutural no país que a violência é normalizada, ignorada e silenciada por milhares de mulheres que veem as suas vidas amputadas. Esta violência estrutural surge ainda mais complexificada pelas questões culturais, repercutindo-se nos mais variados contextos¹³.

Em termos legais e segundo o Social Institutions and Gender Index¹⁴, a Constituição da Guiné-Bissau de 1984, nos seus artigos os artigos 24.º e 25.º, proíbem todas as formas de discriminação em razão do sexo, raça ou religião. O país ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 1985 e o Protocolo sobre a violência contra as mulheres em 2009, assim como o Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e das Pessoas sobre os Direitos da Mulher em 2008, contudo, continua a ter grandes fragilidades na prevenção e combate a este flagelo social.

A Guiné-Bissau conheceu, nestes últimos anos, crises políticas sucessivas e um conflito armado que constituiu uma ameaça para a paz no país e na sub-região. Esta situação cria um clima propício para as violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos, nomeadamente os das mulheres e das crianças¹⁵. Estas múltiplas violências e a insegurança provocaram um êxodo massivo de pessoas refugiadas e de pessoas deslocadas, maioritariamente as mulheres e as crianças, acarretando grandes consequências sociais, económicas e psicológicas.

No intuito de consolidar a paz e de caminhar firmemente para o desenvolvimento, o governo da Guiné-Bissau inscreveu-se numa lógica de paz, com o apoio da comunidade internacional, nomeadamente, das Nações Unidas. Conscientes de que os efeitos da construção da paz na Guiné-Bissau são indissociáveis da igualdade de género e do desenvolvimento, o governo está empenhado em apoiar ativamente a implementação dos instrumentos internacionais relativos

¹² World Bank, *Guinea-Bissau: Integrated Poverty and Social Assessment: Transition from Post Conflict to Long-Term Development: Policy Considerations for Reducing Poverty* (2005), 27.

¹³ H. Hudson, "Gendercidal violence and the technologies of othering in Libya and Rwanda" (2014), *Africa Insight* 44, 103, 120.

¹⁴ Ver <https://www.genderindex.org/country/guinea-bissau/>.

¹⁵ Disponível em: http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/guineabissau_nationalactionplan_2010.pdf.

à proteção das mulheres nas situações de conflitos e pós-conflitos, com especial destaque para a resolução 1325 do conselho de segurança.

Contudo, e apesar da implementação e ratificação destas leis e convenções, o governo não consegue fazer cumprir as disposições legais existentes para promover a igualdade de género e os direitos das mulheres no país, sendo a subalternização da mulher uma questão estrutural, que se circunscreve tanto na esfera privada como na esfera pública¹⁶.

A manutenção da paz nacional, a promoção e a defesa dos direitos humanos e da democracia e a resolução pacífica dos diferendos continuam a ser um grande desafio.

As convicções culturais e religiosas parecem alicerçar a discriminação, a subjugação e a exclusão de que as mulheres são alvo, nas quais a religião islâmica, sendo a mais predominante em termos estatísticos, é também a que tendencialmente se mostra mais penalizadora para as mulheres. Esta discriminação é também visível nas dinâmicas políticas onde a participação das mulheres é ainda muito deficitária, sendo quase sempre relegadas para áreas culturalmente associadas à feminilidade, tais como a saúde, a educação, a solidariedade e a promoção feminina²².

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)¹⁷, a taxa de pobreza na Guiné-Bissau é de 58,4%, contudo, a constatação da pobreza generalizada tende a ser secundarizada nas análises sobre as causas dos conflitos no país ou omitida quando se abordam questões como a violência estrutural e a fraqueza das instituições do Estado. No entanto, percebe-se que a pobreza é a principal causa dos conflitos no continente africano e também o maior retardador do desenvolvimento dos países, onde a Guiné-Bissau não é exceção. De acordo com o PNUD, as mulheres guineenses são as antepenúltimas, a nível mundial, em termos de rendimentos (*estimated earned income*). Esta situação pode explicar-se, por um lado, pela situação económica e social antecedente à guerra e, por outro, pela incapacidade e/ou ausência de respostas adequadas no que diz respeito às políticas pós-conflito armado. A pobreza é substancialmente mais acentuada nas mulheres em todas as faixas etárias e todas as regiões do país, o que as vulnerabiliza em múltiplas esferas²¹.

Outro tipo de violência estrutural com impactos graves em termos de sobrevivência e qualidade de vida diz respeito à própria capacidade de manutenção da vida, dificultada por um sistema de saúde em falência, não funcional e inacessível em termos económicos¹⁸. Segundo o relatório sobre o direito à saúde

¹⁶ J. Moreira, *supra* n. 2.

¹⁷ https://www.gw.undp.org/content/guinea_bissau/pt/home.html.

¹⁸ T. Moura, S. Roque, S. Araújo, M. Rafael e R. Santos, *supra* n. 1.

na Guiné-Bissau¹⁹, a pobreza generalizada contribui para a vulnerabilidade de toda a população. 69,3% da população da Guiné-Bissau vive abaixo do limiar nacional de pobreza e cerca de 80,4% da população vive em pobreza multidimensional, isto é, um mesmo agregado familiar sofre privações relativamente à educação, saúde e nível de vida; enquanto 58,4% da população vive em pobreza multidimensional severa²⁰.

A Guiné-Bissau está entre os países do mundo com os piores resultados em matéria de saúde materna. A taxa de mortalidade materna na Guiné-Bissau está entre as mais altas do mundo e os/as guineenses têm uma esperança de vida muito baixa, que é de 55,5 anos, de acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2016. A situação precária de saúde impede o progresso político, pois reduz a expectativa de vida, afeta a capacidade dos indivíduos de aceder à educação e de participar ativamente na vida pública e em atividades económicas e acentua a pobreza.

Por outro lado, na Guiné-Bissau verificam-se fortes desigualdades no acesso à educação, nomeadamente associado ao género, com uma elevada discrepância entre o sexo masculino e o feminino, e associado à localização geográfica, com uma diferenciação entre o meio urbano (essencialmente, a capital Bissau) e o meio rural²¹. Em 2014, a taxa de conclusão do ensino primário foi de 75,7%, enquanto a taxa de admissão ao ensino primário foi de 31,1%²². Além disso, 40,1% da população adulta é analfabeta. Simultaneamente, a literacia para e sobre a saúde, que inclui educação sobre saúde sexual e reprodutiva, é praticamente inexistente, o que limita a capacidade da população de adquirir novos comportamentos e, consecutivamente, contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde no país.

2.1. Tipologias da violência de género na Guiné

A violência estrutural e cultural que afeta homens e mulheres no país é extremamente acentuada, estando intimamente relacionada com a violência de género, que continua a ser perpetuada em múltiplos contextos e assume diferentes formas que vão desde o casamento forçado ao casamento arranjado, violência nas relações de intimidade, violência sexual, heranças, mutilação genital

¹⁹ https://www.ohchr.org/Documents/Countries/GW/RightHealthGuineaBissau_PT.pdf.

²⁰ PNUD, "Human Development Report 2016" (Relatório do Desenvolvimento Humano 2016), 200, disponível em: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, consultado em 21 de novembro de 2020.

²¹ ONU, *Premier Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement en Guinée Bissau* (2004), 17.

²² UNICEF, Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) (UNICEF, 2007).

feminina, casamento polígamo, entre outras. Iremos aqui destacar as formas de violência de gênero mais expressivas no país.

O casamento arranjado e, normalmente, forçado pode ocorrer na idade adulta ou na infância/adolescência. Apesar de impactar na sua maioria em raparigas/mulheres, existem alguns meninos que também são obrigados a fazê-lo. Há casos que ocorrem sobretudo em situação de viuvez, onde as questões das heranças podem incluir a obrigatoriedade de relações sexuais com o detentor da herança (e.g., cunhado)²³.

Nas crianças, esta situação varia de acordo com a etnia e situação económica, mas normalmente situa-se entre os 12 e os 16 anos. Esta situação presume uma relação de poder extremamente desequilibrada (homem mais velho e rico e mulher muito mais nova), o que coloca as meninas e jovens raparigas em situação de vulnerabilidade acentuada (e.g., vitimação, maternidade precoce, abandono escolar).

O casamento infantil é uma violação dos direitos humanos e esta prática vai contra o Código Civil guineense, que conceptualiza que o casamento deve ocorrer entre pessoas de sexo diferente, com o consentimento das duas partes envolvidas e que tenham idade superior a 18 anos.

Em 2015, e segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano²⁴, a taxa de natalidade adolescente era de 89,5%. As taxas de gravidez na adolescência estão relacionadas com a violência sexual de que muitas meninas são vítimas, mas também devido ao casamento precoce, infantil e forçado. Atualmente, 7% das meninas são casadas antes dos 15 anos, não obstante a Lei de Saúde Reprodutiva fixar a idade mínima de 18 anos para o casamento.

O casamento é considerado forçado quando uma das partes discordar com a sua realização; na maioria dos casos, para a consumação do casamento, a família da noiva pede como recompensa um “dote” para poder dar a filha ao futuro marido. Em outros casos, a filha é dada como recompensa de uma dívida que a família tem com a família do noivo ou com o próprio noivo. Percebe-se que esta prática é visível em todo o país, mas com maior predominância no Sul, principalmente nas meninas de etnia Balanta. Quando as/os meninas/os tentam fugir, a vítima é punida com violência física e psicológica, tais como: a humilhação pública, privação da liberdade, exílio da tabanca (comunidade de aldeias) e, em algumas das vezes, espancamento até a morte.

²³ S. Roque, *Um Retrato da Violência contra Mulheres na Guiné-Bissau* (2011), disponível em: https://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/907_VAW%20study_completed_FINAL.pdf, consultado em 2 de dezembro de 2020.

²⁴ Relatório do Desenvolvimento Humano, *supra* n. 20.

Esta prática é punível pela Lei n.º 83/2015, que especificou as seguintes punições: o crime de casamento forçado, definindo que quem constranger outra pessoa a contrair casamento ou união equiparável à do casamento é punido com prisão de até cinco anos. Estipula ainda uma pena de prisão até um ano ou uma pena de multa de até 120 dias para quem execute atos preparatórios relativos ao casamento forçado, como o de atrair a vítima para território diferente do da sua residência com o intuito de a coagir a contrair casamento ou união equiparável.

O casamento polígamo, por sua vez, assenta na ideologia da poligamia que implica que o homem tem o direito de ter várias esposas; sendo, contudo, considerado imoral, para a mulher, ter vários esposos, ou seja, praticar a *poliandria*. Na Guiné-Bissau, o casamento polígamo ainda é praticado por muitos, principalmente nas zonas rurais do país. O casamento polígamo não é só praticado por algumas etnias, mas sim por todas. Os Mandingas usam o argumento de que o Islão permite que um homem se case simultaneamente com quatro mulheres no máximo, e que ele seja capaz de ser justo e de igualar todas elas com os mesmos direitos. Esta religião somente reforça e legitima a prática que já existia na África tradicional. Além de praticarem a poligamia, também praticam a excisão feminina. Para os praticantes do Islão, a poligamia é uma lei regulada pelo Alcorão, livro sagrado que autoriza o homem a ter até quatro esposas.

Relativamente à violência nas relações de intimidade, o relatório “Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau”²⁵ elenca que, entre 2006 e 2010, foram registadas, em todos o país, 23193 denúncias de mulheres de violência nas relações e intimidade, estando a sua maioria centralizadas geograficamente na capital, Bissau. O relatório reflete ainda que, embora o sistema de denúncia seja frágil, a dimensão dos atos de violência denunciados é preocupante, sobretudo se pensarmos nas cifras negras. Na Guiné, este tipo de casos é raramente denunciado, não só devido à naturalização da violência contra as mulheres, mas também devido à baixa confiança das populações em relação à polícia e ao sistema judicial²⁶.

Segundo dados da UNICEF²⁷, 51,5% das mulheres consideram aceitável que o marido lhes bata por diferentes motivos. Claro está que esta violência assume diferentes tipologias, desde a violência física, psicológica e sexual. No contexto familiar, isto é, entre pais e filhos ou outros responsáveis pela família, a violência física e psicológica é extremamente comum, sendo executada pelo pai como uma medida educativa, para obter a obediência da esposa e dos filhos, e vista como algo natural.

²⁵ S. Roque, *supra* n. 23.

²⁶ World Bank, 2005, *supra* n. 12.

²⁷ UNICEF, *supra* n. 22.

Numa sociedade patriarcal, onde os modelos de masculinidade levam ao controlo e subordinação das mulheres, e onde o acesso a um marido ou companheiro significa, muitas vezes, a sobrevivência económica das próprias e da família, as próprias mulheres sentem necessidade de contribuir para a manutenção de ideais violentos de relacionamento²⁸.

Na atualidade, a fraca escolarização feminina, acompanhada do desemprego masculino, no setor formal, fez aumentar a economia informal executada na sua maioria por mulheres (e.g., na agricultura e no comércio). Isto levou consequentemente a uma ascensão económica feminina que, na maioria das vezes, é mal vista pelos seus companheiros, que se sentem inferiorizados e que mais uma vez incentivam e legitimam a prática de violências múltiplas para com as mulheres.

A violência sexual, principalmente no casamento, é invisibilizada e, devido à vergonha das vítimas, é, em muitos casos, difícil de identificar. Segundo Roque e Negrão, grande parte da violência sexual ocorre dentro do casamento e não é, por isso, julgada como violação, mas antes como um direito do homem. Segundo Adichie²⁹, quando se repete uma coisa várias vezes, ela torna-se normal, quando vemos uma coisa com frequência, ela tende-se a legitimar. A violência sexual é um dos exemplos da naturalização das coisas.

No dia 18 de julho de 2013, o parlamento da Guiné-Bissau aprovou por unanimidade um projeto de lei que criminaliza a violência doméstica, estabelecendo penas de prisão que podem ir até 12 anos e a criação de centros de acolhimento para as vítimas de violência doméstica, casamento forçado e mutilação genital feminina. Contudo, mesmo sendo criminalizados pela Constituição da República Guineense, estes crimes continuam a ser perpetuados e muitas vezes silenciados.

Outra das formas de violência de género perpetuadas na Guiné é a mutilação genital feminina, comumente denominada por fanado. A circuncisão feminina é uma prática multicultural que, tal como noutros países, é associada aos rituais de passagem à idade adulta (fanado). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS ou WHO)³⁰, afeta cerca de duas mil meninas por ano, sendo a grande maioria islamizada e uma pequena parte pertencente a etnias não islamizadas, que recorrem de forma pouco frequente à excisão feminina.

A cerimónia de passagem é feita através do corte, isto é, remoção parcial ou total dos órgãos genitais, conhecido pelo mundo inteiro como mutilação ge-

²⁸ S. Roque e S. Negrão, *Mulheres e Violências: Combater as Violências: Propostas para a Guiné-Bissau* (2009), disponível em: https://ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/375_ManualMulheresEViolenciasGB.pdf, consultado em 24 de novembro de 2020.

²⁹ C. Adichie, *Todos Devemos ser Feministas* (Publicações Dom Quixote, 2015).

³⁰ WHO, *Female Genital Mutilation. A Handbook for Frontline Workers* (Geneva, 2000).

nital feminina. É praticada por algumas etnias do país, principalmente as da religião muçulmana. As meninas são submetidas à excisão, na sua maioria, a partir dos sete anos, pelo facto de que elas não têm consciência do mal que esta prática lhes causa ou que lhes causará no futuro. Ou seja, a mutilação genital feminina é praticada em meninas muito jovens; também é feita nos bebés, com a ideia de que eles são insensíveis à dor. Por último, é também praticada em mulheres adultas, caso não tenha ocorrido na infância.

A excisão feminina na Guiné-Bissau é feita por “fanatécas”, denominação dada às mulheres especialistas em excisar. Esta prática é feita em péssimas condições sanitárias e sem recurso a anestesia, resultando frequentemente em problemas de saúde e até em morte, em caso extremo. Quando isto acontece, muitas vezes, a culpa é atribuída à família (de alguma forma aquela menina estava impura ou estava predestinada), não existindo conhecimento de criminalização e punição destes factos.

As consequências das excisões variam segundo o tipo e a gravidade da intervenção praticada. Segundo a OMS³¹, a forma de excisão praticada na Guiné-Bissau corresponde à excisão ou clitoridectomia (tipo II), que inclui a ablação do clítoris e pequenos lábios. Não parece ser o caso, como noutras partes do mundo, em que a excisão se refere apenas à remoção do prepúcio, ou seja, da pele que cobre o clítoris, e que, ao deixá-lo mais exposto, facilitaria a obtenção de prazer³².

As consequências de não passar pelo fanado podem ser a discriminação e exclusão social, passando pela recusa do casamento ou, quando este sucede, existir exclusão dentro da família no que diz respeito a determinadas tarefas.

As razões desta prática e a sua permanência em contexto de mudanças sociais e culturais são várias, implicam diferentes agentes e formas de legitimação. Entre as principais razões apontadas pelas famílias contam-se as seguintes: atenuar o desejo sexual na mulher e aumentar o prazer sexual do homem; reservar a castidade e a virgindade antes do casamento e a fidelidade durante o casamento, de uma forma geral, evitar a promiscuidade; aumentar a fecundação e a sobrevivência dos descendentes; promover a identificação com a herança cultural e a integração social; iniciar as raparigas na condição de mulheres e levar à sua purificação; aumentar as oportunidades de casamento e honrar a família.

Esses costumes são impostos de uma forma rígida para controlar a sexualidade, garantindo a virgindade das meninas antes do casamento, diminuindo o seu desejo sexual. Fala-se, também, de obrigar a mulher a ser fiel ao marido.

³¹ WHO, *Female Genital Mutilation – Programmes to Date: What Works and What Doesn't* (World Health Organization, 1999).

³² INDE, *Relatório Técnico do Encontro de Líderes Religiosos Muçulmanos para Debate e Reflexão sobre a Problemática da Excisão Feminina* (2005).

A mutilação genital feminina é criminalizada no país através da Lei n.º 14/2011 para Prevenir, Combater e Suprimir a Mutilação Genital Feminina. No entanto, a prevalência desta prática situa-se em cerca de 45%, sendo que cerca de metade das mulheres com idade entre os 45 e os 49 anos e quase metade das mulheres com idade entre os 15 e os 19 anos foram submetidas a mutilação genital feminina, o que efeitos negativos múltiplos, nomeadamente para a saúde materna.

3. Os direitos humanos em debate, a partir da obra de Norberto Bobbio

Os direitos humanos são hoje um discurso de persuasão pública, que chamam a si um reconhecimento implícito da esfera sociopolítica, das noções normativas de formação de sujeitos e das singularidades paradoxais³³.

Roig³⁴ apresenta quatro postulados de reflexão em torno de Norberto Bobbio que nos servirão como ponto de partida para esta incursão: “a) Direitos humanos são direitos históricos que não têm base absoluta, mas consensual; b) O reconhecimento dos direitos humanos são um indicador do progresso histórico da humanidade; c) Existe uma inter-relação entre direitos humanos, democracia e paz; d) Os direitos humanos têm natureza problemática e até contraditória”.

Para Bobbio³⁵, a conservação, a transformação e/ou o desenvolvimento dos direitos humanos ficam dependente de três fatores centrais: os sujeitos, o tempo e a cultura – triangulação que justifica a falta de concordância entre a teoria e a prática no que toca à aplicação dos citados direitos³⁶. Neste sentido, a produção de uma abordagem histórica dos direitos humanos, de forma abrangente, leva-nos à necessidade de ir além da teoria retórica e ter em conta movimentos sociais e diferenças de escala e alcance geopolítico³⁷. E, neste ponto em concreto, devemos salientar que, apesar dos esforços crescentes dos teóricos que se dedicam à temática dos direitos humanos, no sentido de se fazer cumprir o reconhecimento histórico, a verdade é que a história dos direitos humanos foi escrita sob um universalismo exclusivo que, na verdade, durante anos, não foi além de uma dicotomia “Eu-Outro” – o dito universal aplicar-se-ia, então, a todos os que não se encontrassem nas *cluster*: escravos, povos colonizados, povos

³³ W. Hesford, *Spectacular Rhetorics: Human Rights Visions, Recognitions, Feminisms* (Duke University Press, 2011).

³⁴ R. Roig, “Bobbio y los Derechos Humanos”, in A. Llamas (ed.), *La Figura y el Pensamiento de Norberto Bobbio* (Universidad Carlos III de Madrid, 1994), 169-185.

³⁵ N. Bobbio, *Era dos Direitos* (Elsevier Brasil, 2004).

³⁶ *Idem, ibidem*.

³⁷ W. Hesford, *supra* n. 33.

indígenas, mulheres, crianças e pessoas com doença mental³⁸. Nesta conceção, ser “Outro” era, assim, não ser totalmente humano e, consequentemente, não chamar a si estes direitos.

Na atualidade, Bobbio vê os direitos humanos como um tema com amplo espaço de debate, que se traduz num indicador de progresso moral de tal forma relevante que concerne em si implicações e obrigações morais sobre os sujeitos em torno da dignidade humana, vertidas em obrigações e direitos³⁹ – somos aqui conduzidos, portanto, à discussão em torno das condições para que tal se verifique. Apenas um Estado de Direito Democrático contém meios satisfatórios para promover, proteger e garantir os direitos humanos⁴⁰, sendo este reconhecimento e proteção a base dos sistemas democráticos e o pressuposto para que tal esteja garantido, numa atmosfera de paz⁴¹, aqui compreendida como “o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional”⁴². Em consonância, é também indicado que um clima de “paz perpétua” só será possível através de um processo de democratização do sistema internacional que, por seu turno, fica dependente da evolução e da extensão do reconhecimento e da proteção dos direitos humanos acima de cada Estado – “Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos.”⁴³. Para Bobbio, tudo o que se discute neste breve trecho apresentado está recolhido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, instrumento que se edifica, portanto, sobre um entendimento universal e básico em torno de conjunto fundamentado⁴⁴ de valores⁴⁵ que livremente foram expressos e acolhidos por uma parte representativa dos seres humanos e partilhados com a autoridade depositada por estes nos seus representantes – os Estados⁴⁶. A democracia está assim implícita no suporte do desenvolvimento dos direitos humanos e, consequentemente, é um aspeto fundamental na história dos direitos, designadamente, em questões tão relevantes como o reconhecimento ou a proteção destes – um ponto bastante

³⁸ U. Baxi, *The Future of Human Rights* (Oxford University Press, 2007).

³⁹ R. Roig, *supra* n. 34.

⁴⁰ N. Bobbio, *supra* n. 35.

⁴¹ R. Roig, *supra* n. 34.

⁴² N. Bobbio, *supra* n. 35.

⁴³ *Idem, ibidem*.

⁴⁴ *Idem, ibidem*.

⁴⁵ *Idem, ibidem*.

⁴⁶ *Idem, ibidem*.

relevante a considerar para a discussão da temática aqui em análise, uma vez que nos conduz para o debate em torno do poder, dos seus limites, das vontades do poder político e da importância da consciência coletiva implícita num Estado democrático e com capacidade de contestar direitos humanos que vão além da resposta nacional e alcançam terreno num plano internacional do direito⁴⁷.

3.1. Direitos humanos das mulheres: a genderização do direito e o processo de especificação

A Humanidade desde sempre se viu em sistemas recíprocos de obrigações (direitos e deveres), sustentados por diferentes sistemas de controle (interno ou externo) que, numa primeira fase, era atribuído a entidades divinas, seguindo-se a aristocracia e a figura do rei, substituída pelo governo, na figura do Estado, sob a sua relação estrutural Estado-cidadão⁴⁸.

Como tivemos a oportunidade de ver anteriormente, a análise dos direitos humanos carece de uma ponderação que contemple os sujeitos, o tempo e a cultura⁴⁹, por isso, começamos por lembrar que a intervenção jurídica no âmbito da violência de género é algo relativamente recente, muito embora não se trate de um fenómeno novo na sociedade, mas que, devido ao seu carácter “privado” e “íntimo”, suportado pela ideologia patriarcal que ainda hoje se faz sentir, só muito recentemente deteve espaço de contestação.

O século XX, fortemente marcado pelo sentimento de revolta com as atrocidades resultantes da Segunda Guerra Mundial⁵⁰, é também o período que comporta as principais conferências internacionais e marcos políticos e legais que versam sobre as definições dos direitos humanos mínimos para todas as pessoas (e.g., Carta das Nações Unidas, 1945; Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948) que, por sua vez, impulsionaram a identificação e investigação da violência de género contra a mulher⁵¹.

Deste modo, se numa primeira fase da era moderna dos direitos humanos a mesma se pautou pela exploração e consciencialização da universalidade dos direitos humanos, caracterizada por uma abrangência destes, passível até de ser

⁴⁷ R. Roig, *supra* n. 34.

⁴⁸ J. Galtung, *Human Rights in Another Key* (Polity Press, 1994).

⁴⁹ N. Bobbio, *supra* n. 35.

⁵⁰ F. Piovesan, “Direitos Humanos e Diálogo entre Jurisdições” (2012), *Revista Brasileira de Direito Constitucional* 19, 67-93.

⁵¹ L. Casique e A. Furegato, “Violência Contra Mulheres: Reflexões Teóricas” (2006), *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 14.

compreendida como algo problemática e contraditória⁵², é também essa mesma abrangência que permite a flexibilidade necessária para tecer novas leituras sobre os direitos, e o seu contínuo reconhecimento de necessidades e esperanças geradas pelos novos desafios do mundo⁵³.

Falar de direitos humanos é, assim, não perder de vista a sua essência dinâmica e construcionista, que vai desde a afirmação universal do ser humano como detentor de direitos e liberdades; passando pela generalização dos direitos a todos os membros de uma comunidade, num sentido universal da cidadania; pela internacionalização dos direitos humanos através de sistemas de proteção internacional, subjacente a limites fronteiriços; e, por fim, pela especificação dos direitos que, considerando que um tratamento universal e genérico não responde às necessidades concretas das pessoas, propõem um aprofundamento da tutela, promovendo respostas justas socialmente^{54/55}.

O processo de especificação dos direitos humanos, no que toca à violência contra as mulheres, traz à tona a vulnerabilidade a que as mulheres estão expostas devido aos estereótipos sociais e culturais associados ao seu gênero, cristalizados numa estrutura ideológica de superioridade e dominação dos homens sobre estas – o sistema patriarcal⁵⁶. Este apoia e perpetua a transmissão da supremacia masculina e da submissão das mulheres em todas as áreas das suas vidas, inclusive nos domínios dos direitos onde, segundo a teoria feminista do Direito, se reproduz num ordenamento jurídico não representativo das pessoas em geral, mas de quem o constrói: homens (ocidentais) que, enquanto detentores de poder, multiplicam uma discriminação institucional⁵⁷.

Uma construção legislativa cega às questões de gênero fica suportada em dois grandes erros: 1) a exigência de que as pessoas se insiram numa norma, forçando uma identificação com o modelo que originou a lei de igualdade, des-

⁵² R. Stavenhagen, *The Ethnic Question: Conflicts, Development, and Human Rights* (United Nations University Press, 1990).

⁵³ C. Bunch, “Women’s Rights as Human Rights: Toward a Re-vision of Human Rights” (1990), *Human Rights Quarterly* 12, 486-498.

⁵⁴ N. Bobbio, *supra* n. 35.

⁵⁵ B. de Sousa Santos e J. Nunes, “Introdução: para Ampliar o Cânone do Reconhecimento, da Diferença e da Igualdade”, in B. de Sousa Santos (org.), *Reconhecer para Libertar: Os Caminhos do Cosmopolitismo Multicultural* (Civilização Brasileira, 2003), 52.

⁵⁶ J. Arochena “El derecho fundamental a vivir sin violencia de género” (2014), *Anales de la Cátedra Francisco Suárez* 48, 31-48.

⁵⁷ *Idem, ibidem*.

cartando então a existência de pessoas fora do sistema padrão^{58/59}; 2) que a igualdade passe por uma equiparação, assumindo-se que as ações dirigidas à proteção das mulheres, enquanto pessoas em desvantagem, geram estigma⁶⁰.

Somos então chegados a um conflito inevitável entre o princípio da igualdade e o direito à diferença: por um lado, a dualidade da reivindicação por direitos iguais e um tratamento igualitário; por outro, o direito a um tratamento diferenciado e a valorização das especificidades da mulher⁶¹. Este mesmo conflito ilustra, assim, exatamente a passagem necessária pelo processo de generalização – universalidade dos direitos – para a sua adaptação, através do processo de especificação, e que nos leva ao cruzamento dos direitos humanos estabelecidos em diploma com o quotidiano de todas as pessoas e incita a apropriação destas de forma adequada de resposta às especificidades delas e das suas vidas⁶².

Dar respostas específicas às violências sofridas pelas mulheres baseadas no género, por via do desenvolvimento de instrumentos de promoção dos direitos humanos das mulheres, é reconhecer que a violência contra elas é uma questão de direitos humanos. E a especificação, presente nos instrumentos de direitos humanos das mulheres, permite compreender e dar respostas adequadas às formas de violência sofridas, designadamente através da responsabilidade estatal por atos individuais de violência⁶³.

4. Considerações finais

Ao longo destas páginas, analisámos o contexto sociocultural da Guiné-Bissau, as lógicas, os valores e as tradições associadas às múltiplas formas de violência de género em vigor no país.

A Guiné-Bissau é um país marcado pela violência estrutural, que acumula problemas ao nível económico, político e social, verificáveis nas carentes condições e qualidade de vida vigentes⁶⁴ que nos remetem para inúmeras formas de violação dos direitos humanos, injustiça social, desigualdades de poder, vio-

⁵⁸ C. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press, 1989).

⁵⁹ M. Minow, *Making all the Difference: Inclusion, Exclusion, and American Law* (Cornell University Press, 1991).

⁶⁰ C. MacKinnon, *supra* n. 58.

⁶¹ E. Jelin, “Mulheres e direitos humanos” (1994), *Estudos Feministas* v. 2 n. 3, 117-149.

⁶² R. Roig, *supra* n. 34.

⁶³ L. Hasselbacher, “State Obligations Regarding Domestic Violence: The European Court of Human Rights, due Diligence, and International Legal Minimums of Protection” (2009), *Northwestern Journal of Human Rights* 8, 190-215.

⁶⁴ World Bank, *Guinea-Bissau...*, *supra* n. 12.

lência, fome, miséria, doença e/ou morte – um cenário propício à criminalidade e violência social⁶⁵.

Concretamente ao nível das relações sociais de género, há uma preponderância de discursos tradicionais de género opressores que impactam de uma forma transversal todos os domínios da vida das mulheres guineenses (e.g., laboral, íntima e social), “naturalmente” remetidas para a esfera doméstica e subalternidade, que as empurram para cenários de violências naturalizadas⁶⁶, veda o acesso aos seus direitos e à possibilidade de desenvolvimento igualitário.

Na realidade, o país encontra-se sob uma dominação institucional masculina, que mantém uma perpetuação dos privilégios masculinos e que vai reforçando difusão de múltiplas violências institucionais que impactuam a vida das mulheres de uma forma avassaladora⁶⁷.

Assim, não será estranho que as violências sofridas pelas mulheres nem sempre sejam encaradas socialmente como violações dos seus direitos humanos, apesar de o país ter vindo a ratificar diversos instrumentos de direitos humanos das mulheres (e.g., CEDAW em 1985, Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e das Pessoas sobre os Direitos da Mulher em 2008). Tal situação mostra um distanciamento existente entre a proteção legal e política formal e a efetivamente praticada e conseguida.

Especificamente no que toca às tipologias das violências de género, estas acontecem em múltiplos contextos e sob diferentes formas.

Começemos pela violência doméstica, que, apesar de ser crime público na Guiné-Bissau desde 2014, é uma realidade com dimensões ainda muito desconhecidas devido à naturalização da violência sofrida, do frágil sistema de denúncia e da baixa confiança na polícia e no sistema judicial, levando ao silenciamento das situações de violência⁶⁸. Estes mesmos problemas são igualmente extensíveis às práticas nocivas vigentes no país, tais como o casamento infantil, o casamento precoce, polígamo, forçado e arranjado e a mutilação genital feminina.

O caso concreto da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau fornece-nos um exemplo claro da necessidade de, não deixando de compreender a base estrutural da violência em questão, ter em conta as especificidades culturais e mesmo religiosas presentes nestes territórios, que dão alicerce ao sistema opressor instituído.

⁶⁵ M. Minayo, “Violência Social sob a Perspectiva da Saúde Pública” (1994), *Cadernos de Saúde Pública* 10, 7-18.

⁶⁶ J. Moreira, *supra* n. 2.

⁶⁷ *Idem, ibidem*.

⁶⁸ S. Roque, *supra* n. 23.

E, neste sentido, seria, no nosso entender, de grande acrescento para o tratamento deste e de outros fenómenos com este tipo de particularidades cruzadas recorrer às perspetivas integradoras do crime, possibilitando compreender saberes da criminologia feminista, cultural, transnacional, ou outras que se mostrem pertinentes a analisar um fenómeno tão multicausal quanto este.

A problemática aqui em apreço, as violências contra as mulheres e, neste caso mais concreto, a mutilação genital feminina, sustenta-se numa assimetria de poder baseada no género à qual a criminologia feminista tem fornecido contributos inegáveis, ao colocar as mulheres no centro da questão e ao possibilitar a construção de considerações distintas das mais convencionais, que não contemplam as questões de género⁶⁹.

Por seu turno, a criminologia feminista internacional e transnacional – um subcampo do estudo da criminologia feminista – pode verificar-se igualmente um campo a explorar, dado que compreende a natureza global do crime, da vitimização e da justiça, propondo expandir-se para quadros teóricos e conceptuais internos que englobem forças estruturais mais amplas que moldam o crime das mulheres, a sua vitimização e a resposta de género dos sistemas de justiça criminal dos países, bem como das normas internacionais e mecanismos de responsabilização estabelecidos⁷⁰. Esta visão compreende a desigualdade de género como um fenómeno histórico, sociocultural e geopolítico, no contexto de sistemas interligados de patriarcado, racismo, colonialismo e injustiça económica⁷¹, podendo ser uma abordagem interessante a ter em conta na migração do próprio fenómeno para outras zonas do globo onde não há um historial sedimentado da prática (e.g., casos de mutilação genital feminina em Portugal).

Além das abordagens já mencionadas, e compreendendo toda a bolha cultural onde se insere o fenómeno, gostaríamos de mencionar as potencialidades da lente de análise da ainda emergente criminologia cultural⁷², que se propõe estudar o crime, a criminalidade e o seu controlo, no contexto da cultura, compreendendo estas dimensões como produtos culturais que devem ser lidos tendo em consideração os significados que carregam⁷³.

⁶⁹ K. Henne, “Feminist Criminology”, in A. Deckert e R. Sarre (eds.), *The Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice* (Palgrave Macmillan, 2017), 587-602. G. Monti, “New Directions in EC Competition Law”, in T. Tridimas (ed.), *European Union Law for the Twenty-First Century*, vol 2 (Hart Publishing, 2004), 177, 179.

⁷⁰ R. Barberet, “International and Transnational Feminist Criminology” (2019), *The Encyclopedia of Women and Crime*, 1, 2.

⁷¹ *Idem*, *ibidem*.

⁷² J. Ferrell e C. Sanders, “Culture, Crime and Criminology”, in J. Ferrell e C. Sanders (eds.), *Cultural Criminology* (Northeastern University Press, 1995).

⁷³ K. Haward, *City Limits: Crime, Consumer Culture and the Urban Experience* (Glasshouse, 2004).

Para finalizar, lembrando que poderia haver pontos de diferentes abordagens que fariam sentido ser tidos em consideração na análise do problema, compreendemos que se pode beneficiar do uso das abordagens integradas que permitem uma leitura interdisciplinar para a compreensão do crime e o controlo do crime, por meio da incorporação de, pelo menos, dois corpos de conhecimento disciplinares (e.g., dados, teorias, métodos) que forneçam explicações sobre a produção de crimes, criminosos e controlo social⁷⁴.

Feita esta breve discussão em torno das lentes de análise passíveis de serem exploradas em futuros trabalhos e investigações, gostaríamos de terminar esta reflexão salientando que há um longo caminho a percorrer na garantia dos direitos humanos das mulheres guineenses, sendo urgente conhecer os verdadeiros contornos e dimensões das violências que estas sofrem, não esquecendo, porém, que esta é uma situação que se enquadra num problema ainda mais lato de violência estrutural em que o país se insere. Como defende Bobbio, não é possível falarmos de direitos humanos sem compreender que estes se interrelacionam com paz e democracia⁷⁵.

Referências bibliográficas

B. de Sousa Santos e J. Nunes, “Introdução: para Ampliar o Cânone do Reconhecimento, da Diferença e da Igualdade”, in B. de Sousa Santos (org.), *Reconhecer para Libertar: Os Caminhos do Cosmopolitismo Multicultural* (Civilização Brasileira, 2003).

Breiding et al., *Intimate Partner Violence Surveillance* (2015), disponível em: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv/intimatepartnerviolence.pdf>, consultado em 29 de novembro de 2020.

T. Moura, S. Roque, S. Araújo, M. Rafael e R. Santos, “Invisibilidades da guerra e da paz: Violências contra as mulheres na Guiné-Bissau, em Moçambique e em Angola” (2009), *Revista Crítica de Ciências Sociais* 86, 95-122, disponível em: <https://doi.org/10.4000/rccs.240>.

C. Adichie, *Todos Devemos ser Feministas* (Publicações Dom Quixote, 2015).

C. Bunch, “Women’s Rights as Human Rights: Toward a Re-vision of Human Rights” (1990), *Human Rights Quarterly* 12, 486-498.

⁷⁴ G. Barak, *Criminology: An Integrated Approach* (2009), 153, disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=gSFtAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=integrative+criminology+barak&ots=YY-1cHea8G&sig=m_TYWcpVdqAzLS5oPzxvPce-sdQ-v=onepage&q=integrative+criminology+barak&f=false, consultado em 12 de novembro de 2020.

⁷⁵ N. Bobbio, *supra* n. 35.

C. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press, 1989).

E. Jelin, “Mulheres e direitos humanos” (1994), *Estudos Feministas* v. 2 n. 3, 117-149.

F. Piovesan, “Direitos Humanos e Diálogo entre Jurisdições” (2012), *Revista Brasileira de Direito Constitucional* 19, 67-93.

G. Barak, *Criminology: An Integrated Approach* (2009), disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=gSftAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=integrative+criminology+barak&ots=YY-1cHea8G&sig=m_TYWcpVdqAzLS5oPzxvPce-sdQ-v=onepage&q=integrativecriminologybarak&f=false, consultado em 12 de novembro de 2020.

G. Monti, “New Directions in EC Competition Law”, in T. Tridimas (ed.), *European Union Law for the Twenty-First Century*, vol 2 (Hart Publishing, 2004).

H. Hudson, “Gendercidal violence and the technologies of othering in Libya and Rwanda” (2014), *Africa Insight* 44.

I. Dias, “Violência Doméstica e de Género: Paradigmas e Debates Atuais”, in I. Dias (org.), *Violência Doméstica e de Género* (Pactor, 2018), 1-27.

INDE, *Relatório Técnico do Encontro de Líderes Religiosos Muçulmanos para Debate e Reflexão sobre a Problemática da Excisão Feminina* (2005).

J. Arochena “El derecho fundamental a vivir sin violencia de género” (2014), *Anales de la Cátedra Francisco Suárez* 48, 31-48.

J. Ferrell e C. Sanders, “Culture, Crime and Criminology”, in J. Ferrell e C. Sanders (eds.), *Cultural Criminology* (Northeastern University Press, 1995).

J. Galtung, *Human Rights in Another Key* (Polity Press, 1994).

J. Moreira, *A Cultura di Matchundadi na Guiné-Bissau: Género, Violências e Instabilidade Política* (Tese de Doutorado, 2017), retirado de <https://www.iscte-iul.pt/tese/7237>.

J. Scott, “Género: uma categoria útil de análise histórica” (1995), *Educação & Realidade* 2, 71-99.

K. Haward, *City Limits: Crime, Consumer Culture and the Urban Experience* (Glasshouse, 2004).

K. Henne, “Feminist Criminology”, in A. Deckert e R. Sarre (eds.), *The Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice* (Palgrave Macmillan, 2017), 587-602.

L. Casique e A. Furegato, “Violência Contra Mulheres: Reflexões Teóricas” (2006), *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 14.

L. Hasselbacher, “State Obligations Regarding Domestic Violence: The European Court of Human Rights, due Diligence, and International Legal Minimums of Protection” (2009), *Northwestern Journal of Human Rights* 8, 190-215.

M. Hossain, C. Zimmerman, L. Kiss, T. Abramsky, D. Kone, M. Bakayoko-Topolska, J. Annan, H. Lehmann e C. Watts, “Working with men to prevent intimate partner violence in a conflict-affected setting: a pilot cluster randomized controlled trial in rural Côte d’Ivoire” (2014), *BMC Public Health* 1.

M. Minayo, “Violência Social sob a Perspectiva da Saúde Pública” (1994), *Cadernos de Saúde Pública* 10, 7-18.

M. Minow, *Making all the Difference: Inclusion, Exclusion, and American Law* (Cornell University Press, 1991).

N. Bobbio, *Era dos Direitos* (Elsevier Brasil, 2004).

ONU, *Premier Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement en Guinée Bissau* (2004).

PNUD, “Human Development Report 2016” (Relatório do Desenvolvimento Humano 2016), disponível em: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, consultado em 21 de novembro de 2020.

R. Barberet, “International and Transnational Feminist Criminology” (2019), *The Encyclopedia of Women and Crime*.

R. Roig, “Hacia una Nueva Generalización de los Derechos. Un Intento de Hacer Coherente la Teoría de los Derechos”, in I. Cervera (ed.), *Una Discusión Sobre la Universalidad de los Derechos Humanos y la Inmigración* (Librería-Editorial Dykinson, 2006).

_____, “Bobbio y los Derechos Humanos”, in A. Llamas (ed.), *La Figura y el Pensamiento de Norberto Bobbio* (Universidad Carlos III de Madrid, 1994), 169-185.

R. Stavenhagen, *The Ethnic Question: Conflicts, Development, and Human Rights* (United Nations University Press, 1990).

S. Neves & D. Costa (orgs.), *Violências de Género* (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2017).

S. Roque, *Um Retrato da Violência contra Mulheres na Guiné-Bissau* (2011), disponível em: https://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/907_VAW%20study_completed_FINAL.pdf, consultado em 2 de dezembro de 2020.

S. Roque e S. Negrão, *Mulheres e Violências: Combater as Violências: Propostas para a Guiné-Bissau* (2009), disponível em: https://ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/375_ManualMulheresEViolenciasGB.pdf, consultado em 24 de novembro de 2020.

U. Baxi, *The Future of Human Rights* (Oxford University Press, 2007).

UNICEF, *Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)* (UNICEF, 2007).

United Nations. CEDAW Committee (1992), General Recommendation No. 19 on Violence against women, adopted at the 11th session, A/47/38, 29 January 1992.

United Nations General Assembly, *Declaração Universal dos Direitos Humanos* (1948), disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>, consultado em 2 de dezembro de 2020.

W. Hesford, *Spectacular Rhetorics: Human Rights Visions, Recognitions, Feminisms* (Duke University Press, 2011).

World Bank, *Guinea-Bissau: Integrated Poverty and Social Assessment: Transition from Post Conflict to Long-Term Development: Policy Considerations for Reducing Poverty* (2005).

World Health Organization, *Female Genital Mutilation – Programmes to Date: What Works and What Doesn't* (WHO, 1999).

_____, *Female Genital Mutilation. A Handbook for Frontline Workers* (Geneva, 2000).

_____, *Injuries and Violence – the Facts* (World Health Organization, 2014), disponível em: http://www.who.int/violence_injury_prevention/en, consultado em 13 de dezembro de 2020.

TORTURA: (IM)PRESCRITIBILIDADE E REPARAÇÃO

Jorge dos Reis Bravo

Procurador-Geral Adjunto

Doutor em Ciências Jurídico-Criminais (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – FDUC)

Investigador colaborador do Instituto Jurídico (FDUC)

jorgebravo@netcabo.pt

Torture fails to make us safe, but it certainly makes us less free.

Jerrold Nadler

Resumo: No texto procura-se refletir sobre o crime de tortura, essencialmente a partir do conceito conformador da Convenção contra a Tortura da ONU/1984, de outros instrumentos internacionais e dos princípios constitucionais, no confronto com a lei penal nacional, procurando esboçar propostas de solução para problemas particulares sobre a prescrição (do procedimento criminal e das penas) e as modalidades de reparação (das vítimas).

Palavras-chave: Direitos humanos – Tortura – Vítimas – (Im)prescritibilidade – Reparação.

1. Introdução

O princípio da proibição da tortura integra, de acordo com a penetrante observação de W. Hassemer, o «universo do “indisponível” no direito (processual) penal».

A crescente consciencialização da gravidade das distintas práticas de tortura que as comunidades tomam parece estar em linha com o conhecimento crescente de casos de aplicação das mesmas por parte de Estados e de grupos de indivíduos que agem sob a sua indiferença ou cumplicidade.

A proibição absoluta e incondicional da tortura é, pois, um indeclinável *acquis* civilizacional, emergindo dos princípios humanistas do Iluminismo, como reação às medidas processuais e punitivas do *Ancien Régime*. Importa, contudo, neste breve estudo, avaliar a sua consistência, interiorização e efetividade na realidade contemporânea e procurar responder a dois dos aspetos que podem suscitar: um de índole dogmática – a questão da (im)prescritibilidade do procedimento criminal e da pena – e outro de índole político-criminal, que respeita à reparação das vítimas.

O artigo 5.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o artigo 3.º da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) preveem a proibição incondicional da tortura e da aplicação de penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Outras disposições, nomeadamente a Declaração das Nações Unidas contra a Tortura (Resolução 3452 [XXX], de 09.12.1975, da Assembleia Geral das Nações Unidas) e a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984 (doravante CaT ONU/1984)¹, cometem aos Estados a obrigação de impedir a tortura².

¹ Cujas data de conclusão foi 10.12.1984 e o início de vigência na ordem internacional foi 26.06.1987. Foi aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República (AR) n.º 11/88, de 21 de maio (pub. no *Diário da República* (DR), I Série, n.º 118, de 21.05.1988) e ratificada pelo Decreto do Presidente da República (PR) n.º 57/88, de 20 de julho.

² Portugal ratificou o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (PFCAT), na sequência da ratificação da CaT ONU/1984. Este Protocolo entrou em vigor na nossa ordem jurídica em 14.02.2013 (no 30.º dia após a data em que Portugal depositou o seu instrumento de ratificação junto do Secretário-Geral das Nações Unidas). O PFCAT foi aprovado pela Resolução da AR n.º 143/2012 e ratificado pelo Decreto do PR n.º 167/2012, ambos de 13 de dezembro. Em Portugal, a designação de Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP) foi atribuída ao Provedor de Justiça, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2013, de 20 de maio. Ao MNP cabe examinar regularmente o tratamento das pessoas privadas de liberdade em locais de detenção, fazer recomendações às autoridades competentes a fim de melhorar o tratamento e a situação das pessoas privadas de liberdade e prevenir a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e apresentar propostas e observações a respeito da legislação vigente ou de projetos legislativos sobre a matéria. O MNP tem poderes para efetuar, com ou sem aviso, visitas de inspeção a todo e qualquer setor da atividade da administração central, regional e local, designadamente serviços públicos e estabelecimentos prisionais civis e militares, empresas e serviços de interesse geral, qualquer que seja a sua natureza jurídica, ou a quaisquer entidades sujeitas ao seu controlo, ouvindo os respetivos órgãos e agentes e pedindo informações, bem como a exibição de documentos que reputar convenientes.

De acordo com o artigo 6.º do Tratado da União Europeia, o respeito pelos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais constitui um dos princípios comuns aos Estados-Membros.

O artigo 4.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CD-FUE) estabelece que ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratamentos ou penas desumanos ou degradantes. Em 9 de abril de 2001, o Conselho adotou «Directrizes para a política da UE em relação a países terceiros no que respeita à tortura e a outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes». As diretrizes referem tanto a adoção do Código de Conduta da União Europeia relativo à Exportação de Armas, em 1998, como os trabalhos em curso para a introdução de controlos das exportações de equipamento paramilitar em toda a União Europeia como exemplos de medidas eficazes para se prevenir a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes no âmbito da Política Externa e de Segurança Comum.

Na Resolução contra a Tortura e a outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada a 25 de Abril de 2001, e subscrita pelos Estados-Membros da União Europeia, a Comissão das Nações Unidas para os Direitos do Homem apelou aos países membros das Nações Unidas para que adotassem medidas adequadas, inclusive a nível legislativo, destinadas a evitar e a proibir, entre outras, a exportação de equipamentos concebidos especificamente para infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Esse apelo foi reiterado em resoluções adotadas a 16 de abril de 2002, 23 de abril de 2003, 19 de abril de 2004 e 19 de abril de 2005³.

As considerações que se expõem são, assim, exclusivamente relevantes para ordenamentos jurídicos – como o nosso – que assumem formalmente o sistema de direitos humanos e acolhem o princípio da proibição da tortura, em que, por um lado, seria de esperar que o fenómeno não ocorresse, mas em que também são previstas consequências, designadamente de natureza penal e reparatória.

2. O conceito de tortura: o alcance do artigo 1.º da CaT ONU/1984 e do artigo 243.º do Código Penal

A tortura passa, assim, a ter uma incriminação plural no nosso ordenamento jurídicocriminal: como crime contra as pessoas (integridade pessoal) no CP, como crime contra a paz e a humanidade (em sentido amplo), na Lei sobre Violações de Direito Humanitário, e como crime de guerra contra as pessoas, no Código de Justiça Militar (CJM).

³ Observado pela União Europeia através do Regulamento 1236/2005 (CE) do Conselho de 27.06.2005, JO L 200/1.

A incriminação da tortura foi introduzida no Código Penal – concretamente, os artigos 243.º a 245.º – através da Reforma de 1995 (Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março), apesar de constar já do Anteprojeto de revisão do CP apresentado em 1987⁴.

A sua imutabilidade durante 25 anos pode, eventualmente, resultar da escassa aplicação de tal incriminação ao longo deste período de vigência do CP⁵. Importa, no entanto, indagar se o seu conteúdo corresponde às expectativas e intenções subjacentes à formulação do conceito de tortura da CaT ONU/1984.

A *Reforma Penal de 2007* alterou a sistemática do Código Penal (através do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro), nomeadamente o título III da Parte Especial – em que se inserem os artigos 243.º a 245.º –, que mudou novamente de epígrafe, para «Dos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal», sendo eliminada a divisão em capítulos. Em grande medida, essas alterações foram consequência da transferência do texto do Código Penal dos crimes entretanto tipificados em legislação penal avulsa que adaptou o ordenamento interno ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional: a Lei n.º 31/2004, de 22 de julho, e o seu Anexo⁶.

O legislador da *Reforma Penal de 2007* parece, portanto, ter feito uma opção dogmática no sentido de conceber a tortura como um crime contra a *integridade pessoal*, o que significa que transcende a tutela da integridade, assegurada pelas incriminações contidas nos artigos 143.º e seguintes, no capítulo III do título I (Crimes Contra as Pessoas) do CP. Esta é uma opinião já oportunamente expressa por autorizados Autores, como Teresa Beleza⁷, Maria João Antunes⁸ e Faria Costa⁹.

⁴ A versão originária do Código Penal de 1982 (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro) contemplava no seu artigo 412.º o crime de extorsão de depoimento, decalcado do § 343 do StGB alemão.

⁵ Apesar do número crescente de processos em que vem sendo imputado o tipo de crime de tortura a agentes de forças de segurança.

⁶ O artigo 4.º deste diploma alterara a designação do título III do Livro II do Código Penal para «Dos crimes contra a paz, identidade cultural e integridade pessoal» (n.º 1), ficando o capítulo II do mesmo título III a denominar-se «Dos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal» (n.º 2).

⁷ Cfr. T. Beleza, «A morte e a donzela», in *Estudos Comemorativos dos 10 Anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa*, vol. I (Almedina, 2008), 700.

⁸ Cfr. M. J. Antunes, anotação ao artigo 243.º do Código Penal, in J. de Figueiredo Dias (dir.), *Comentário Coimbraense do Código Penal*, vol. II (Coimbra Editora, 1999), 585 a 595.

⁹ F. Costa, «Vida e morte em direito penal (esquisto de alguns problemas e tentativa de autonomização de um novo bem jurídico)» (jan.-jun. 2004), *RPCC* – Ano 14.º – Fasc. 1 e 2 – *Número Especial: Novas Tarefas e Fronteiras do Direito (Penal) Médico*, 171-196.

O título III do CP, que abrangia, antes de 2007, os crimes contra a paz e a humanidade, entretanto deslocados pelas alterações decorrentes da ratificação do Estatuto de Roma e da necessária adaptação da lei nacional (Lei n.º 31/2004, de 22 de julho), modificou a arrumação sistemática, operando uma alteração de valoração legal de um crime que o anterior texto classificava como crime contra a humanidade para um crime agora catalogado como crime contra a integridade pessoal¹⁰.

O conceito de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante, indicado no artigo 1.º da CaT ONU/1984 consiste, no essencial, na prática de «qualquer acto por meio do qual uma dor ou sofrimento agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa nomeadamente com o fim de obter dela ou de um terceiro, informações ou confissões, de a punir por um acto que ela ou um terceiro cometeram ou se suspeita que tenham cometido, de intimidar ou pressionar uma pessoa ou um terceiro ou por qualquer outro motivo baseado numa forma de discriminação, desde que essa dor ou sofrimento sejam infligidos por um agente público ou outra pessoa agindo a título oficial, por sua instigação ou com o seu consentimento expresso ou tácito»¹¹.

O artigo 1.º da CaT ONU/1984 fixa um conceito de tortura que não reveste um significado eminentemente criminal, mas que deve conformar e inspirar as diversas soluções incriminatórias recortadas pelos ordenamentos jurídicos nacionais.

No nosso Código Penal, a definição de tortura é estabelecida no artigo 243.º, n.º 3, considerando-se «(...) tortura, tratamento cruel, degradante ou desumano, o acto que consista em infligir sofrimento físico ou psicológico agudo, cansaço físico ou psicológico grave ou no emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios, naturais ou artificiais, com intenção de perturbar a capacidade de determinação ou a livre manifestação de vontade da vítima».

A tortura pode materializar-se, assim, em atos que provoquem sofrimento físico ou psicológico agudo, cansaço físico ou psicológico grave, emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios, naturais ou artificiais, com a intenção de perturbar a capacidade de determinação ou a livre manifestação de vontade da vítima; há modalidades que compreendem os tipos de maus tratos

¹⁰ Sendo um dos efeitos inerentes a tal modificação a supressão da legitimidade de qualquer pessoa para se constituir como assistente em processos por crimes de tortura (artigo 68.º, n.º 1, alínea e) *a contr.* do Código de Processo Penal – CPP).

¹¹ Por outro lado, há atos que consistem em “penas” ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes que não constituem tortura, mas que o artigo 16.º da CaT ONU/1984 preconiza que sejam proibidos pelos Estados Partes, sendo-lhes aplicáveis a disciplina dos artigos 10.º (formação do pessoal com atribuições médicas e com intervenção em interrogatórios, guarda ou tratamento de detidos), 11.º (vigilância sistemática da aplicação das disposições de prevenção), 12.º (oficiosidade de investigação de episódios de tortura) e 13.º (direito de queixa e de proteção).

elencados no artigo 126.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), do CPP – aí se podendo contemplar as ofensas à integridade física, a ameaça de violência, os maus tratos, sendo certo que há algumas formas que se mostram mais controversas, como a hipnose e o emprego do polígrafo (com o consentimento dos visados)¹², a simulação de colocação no corredor da morte ou a prática de *waterboarding* (técnica de simulação de asfixia por afogamento)¹³.

O conceito de tortura da CaT ONU/1984 (artigo 1.º, n.º 1) tem, assim, um alcance mais amplo que o acolhido na norma incriminatória do nosso Código Penal (artigo 243.º); esta, embora recorte o conteúdo material essencial da conduta ilícita prevista na Convenção – a infligção de dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, praticados por agentes públicos ou pessoas agindo a título oficial ou mediante instigação ou com o seu consentimento expresso ou tácito, destinada a obter informações ou confissão –, não a transpõe na sua integralidade, designadamente quanto aos sujeitos ativos abrangidos e quanto à realização de atos de tortura «por qualquer outro motivo baseado numa forma de discriminação».

De acordo com a solução positivada no direito penal português, o crime preenche-se, caso alguém colocado numa posição *específica* (funcionário de investigação de infração ou de execução de sanção criminal, contraordenacional ou disciplinar) torture ou maltrate (através de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes) pessoa detida ou presa, com a finalidade de obter confissão ou informação, de a castigar ou de a intimidar. O tipo é alargado, no que diz respeito aos autores, aos usurpadores de funções (n.º 2) e, relativamente às finalidades, às hipóteses de a declaração pretendida ou a intimidação desejada poderem ser dirigidas relativamente a terceiras pessoas.

O artigo 243.º, n.º 1, do CP comina a aplicação de uma pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não for aplicável por força de outra disposição legal. A forma agravada do crime (artigo 244.º) exige que, nos termos e condições, se 1) produza ofensa à integridade física grave; 2) empreguem meios ou métodos de tortura particularmente graves, designadamente espancamentos, eletrochoques, simulacros de execução ou substâncias alucinatórias; ou 3) pratiquem habitualmente atos referidos no artigo anterior; sendo tais condutas puníveis com pena

¹² Não parecendo haver dificuldade em classificá-los como tal, no caso de não interceder autorização. O polígrafo, contudo, assume uma relevância discutível, pois, contrariamente à hipnose ou narcoanálise – que perturbam ou retiram as capacidades mentais-espirituais do visado e alteram a sua liberdade de vontade e decisão sobre o sentido das suas declarações –, aquele apenas regista as alterações fisiológicas em função de estímulos, não controláveis pela vontade, mas sem interferir nos mecanismos de controlo da manifestação do pensamento e ação [assim, S. Oliveira e Silva, *O Arguido como Meio de Prova Contra Si Mesmo – Considerações em Torno do Princípio Nemo Tenetur Se Ipsum Accusare* (Col. Teses, Almedina, 2018), 789].

¹³ Integrando estes métodos, quanto a nós, inequivocamente o conceito de tortura.

de prisão de 3 a 12 anos. Se dos factos descritos em ambos os artigos resultar suicídio ou morte da vítima, o agente é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos.

A tortura enquanto crime contra a humanidade, ou crime de guerra, passou a estar prevista na *Lei penal relativa às violações do direito internacional humanitário*, publicada como Anexo à Lei n.º 31/2004, que «adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário – 17.ª alteração ao Código Penal». Várias disposições de preceitos dessa Lei reportam-se a crimes de tortura e de maus tratos enquanto crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, como, por exemplo, no artigo 9.^{o14} e no artigo 10.^{o15}.

Note-se que, nos termos do artigo 7.º (Crimes contra a humanidade), n.os 1 e 2, alínea e), do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (ERTPI), «por “tortura” entende-se o acto por meio do qual uma dor ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controlo do arguido; este termo não compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionadas acidentalmente».

Além dessas normas, o CJM ainda consagra o crime de guerra contra as pessoas no artigo 41.º, n.º 1, alínea b).

A tortura passa, assim, a ter uma tutela plural no nosso ordenamento jurídico-criminal: como crime contra as pessoas (integridade pessoal) no Código Penal, como crime de direito internacional contra a paz e a humanidade (em

¹⁴ Com o seguinte teor: «Artigo 9.º (Crimes contra a humanidade) Quem, no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, praticar:

(...)

j) Tortura, entendida como o acto que consiste em infligir dor ou sofrimento, físico ou psicológico, grave, a pessoa privada da liberdade ou sob o controlo do agente;

(...).».

¹⁵ Com o seguinte teor: «Artigo 10.º (Crimes de guerra contra as pessoas) 1 - Quem, no quadro de um conflito armado de carácter internacional ou conflito armado de carácter não internacional, contra pessoa protegida pelo direito internacional humanitário, praticar:

(...)

b) Tortura ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, incluindo as experiências biológicas;

(...)

l) Actos que ultrajem a dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes;

(...).».

sentido amplo) na Lei sobre Violações de Direito Humanitário e como crime de guerra contra as pessoas no CJM.

Algumas das consequências desta “bifurcação” traduzem-se no diverso estatuto processual, em termos de legitimidade para a constituição de assistente (artigo 68.º, n.º 1, alínea e), do CPP – apenas se admitindo a constituição como assistente de qualquer pessoa nos casos em que a tortura integre crime contra a paz e a humanidade (mas não já no caso de se reconduzir ao crime contra a integridade pessoal) – e de regimes de prescrição – sendo imprescritível no caso de a tortura integrar crimes especiais contra a paz e a humanidade.

3. A tortura como crime imprescritível?

O artigo 29.º do ERTPI dispõe que os crimes de competência dessa jurisdição não prescrevem¹⁶. A regra da imprescritibilidade dos crimes internacionais suscita melindrosas questões políticas e dogmáticas, desde logo se perfilando várias perspectivas face aos ordenamentos jurídicos nacionais: 1) a de que os crimes internacionais são imprescritíveis perante a jurisdição internacional; 2) a de que os crimes internacionais são objetivamente imprescritíveis, devendo os Estados Partes do ERTPI conformar os seus ordenamentos de acordo com tal comando¹⁷; e, 3) ao abrigo de uma interpretação extensiva do artigo 17.º (2) do ERTPI, de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, a regra da imprescritibilidade e a jurisdição complementar do TPI valeriam quando uma jurisdição prioritária de um Estado Parte tivesse declarado prescrito um dos crimes previstos no Estatuto.

Não é este o momento e o lugar para tentar responder a essas complexas questões, apenas se enunciando os termos do problema, mas crê-se que o legislador nacional optou claramente por se colocar numa linha de continuidade com os limites da jurisdição do TPI, acolhendo uma regra aceite em ordens jurídicas de Países da *Common Law*¹⁸, mas que ainda provoca relutância aos penalistas

¹⁶ Artigo 29.º do ERTPI: «Os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional não prescrevem».

¹⁷ Parecendo ser essa a tese que o Estado português subscreveu ao ratificar o Estatuto de Roma e ao aprovar a Lei n.º 31/2004 e seu Anexo, concretamente o seu artigo 7.º.

¹⁸ Sobre a questão, em geral, M. L. Assunção, “TPI e Lei Penal e Processual Penal Portuguesa”, in *O Tribunal Penal Internacional e a Ordem Jurídica Portuguesa* (Coimbra Editora, 2004); P. Caeiro, *Fundamento, Conteúdo e Limites da Jurisdição Penal do Estado. O Caso Português* (Wolters Kluwer-Coimbra Editora, 2010); W. Brito, “Tribunal Penal Internacional: Uma Garantia Jurisdicional Para a Protecção dos Direitos da Pessoa Humana”, *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* (2000), vol. 76, 81-128; A. F. Velloso, “A imprescritibilidade dos crimes internacionais” (2015), *Ânima – Revista Electrónica do Curso de Direito das Faculdades Opet*, Ano VII, 13 (acessível em http://www.anima-opet.com.br/pdf/animal/artigo_Ana_Flavia_Velloso_a_imprescritibilidade.pdf).

de culturas jurídicas continentais, por constituir um desafio aos fundamentos jusfilosóficos do instituto da prescrição e dos efeitos do decurso do tempo sobre o crime e o seu agente, associados à própria legitimidade do *ius puniendi* do Estado¹⁹.

O artigo 7.º do Anexo da Lei n.º 31/2004 (que adaptou a legislação penal portuguesa ao ERTPI, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário) dispõe que «O procedimento criminal e as penas impostas pelos crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão são imprescritíveis».

A imprescritibilidade do procedimento criminal e das penas no tocante aos crimes de guerra e contra a humanidade é uma solução preconizada, pelo menos, desde a celebração da Convenção das Nações Unidas sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes Contra a Humanidade; essa Convenção foi adotada pela resolução 2391 da Assembleia Geral da ONU, em 26 de novembro de 1968, tendo entrado em vigor em 11 de novembro de 1970 (artigo 4.º). Por seu turno, a Convenção Europeia sobre a Imprescritibilidade dos Crimes contra a Humanidade e dos Crimes de Guerra (Estrasburgo, 1974)²⁰ fundamenta a imprescritibilidade na necessidade de salvaguardar a dignidade humana quer em tempos de guerra como em tempos de paz. Tal dignidade reclama que a repressão de tais crimes não seja comprometida pelo decurso do tempo, através dos institutos da prescrição do procedimento e da pena.

O crime de tortura pode ser recortado como crime internacional, estando previsto no artigo 7.º, n.ºs 1, alínea f), e 2, alínea e) – enquanto crime contra a humanidade –, e no artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, alínea a) ii) – como crime de guerra –, do ERTPI.

Entre nós, a tortura é classificada como *crime contra a humanidade*, de acordo com o artigo 9.º, alínea f), do Anexo da Lei n.º 31/2004, e é igualmente tipificada como *crime de guerra contra as pessoas*, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do mesmo Anexo da Lei n.º 31/2004.

¹⁹ Entre nós, a doutrina propende largamente para a rejeição da imprescritibilidade, ora com base em fundamentos dogmáticos, ora político-criminais ou por simples razões funcionalistas. Sobre a questão, F. Costa, “O Direito Penal e o Tempo (Algumas Reflexões Dentro do Nosso Tempo e em Redor da Prescrição)”, in *Linhas de Direito Penal e de Filosofia – Alguns Cruzamentos Reflexivos* (Coimbra Editora, 2005), 163-190; e debatendo o tema de modo mais atualizado P. Gama da Silva, *A Prescrição no Direito Penal Português* (Almedina – Colectânea de Jurisprudência, 2018), especialmente 58-67.

²⁰ Cfr. o Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República n.º 81/1979, de 28.09.1979, no qual se conclui pela inexistência de obstáculos na ordem jurídica nacional à ratificação da dita Convenção.

Lembre-se que também no CJM se tipifica a tortura como um *crime de guerra contra as pessoas*, no artigo 41.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2²¹.

Havendo uma parcial sobreposição entre o crime do artigo 41.º, n.º 1, alínea b), do CJM e o crime previsto no artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do Anexo da Lei n.º 31/2004, sendo este diploma posterior ao que aprovou aquele Código (a Lei n.º 100/2003, de 15 de novembro), poderia pensar-se ter-se operado uma revogação tácita.

Dispõe, no entanto, o artigo 3.º do Anexo da Lei n.º 31/2004 que «O disposto na presente lei não prejudica a aplicação do Código de Justiça Militar quando os crimes tiverem conexão com os interesses militares da defesa do Estado Português e os demais que a Constituição comete às Forças Armadas Portuguesas.»

Na verdade, os crimes praticados “em tempo de guerra” tipificados no CJM são apenas aplicáveis no caso de serem perpetrados «estando Portugal em estado de guerra declarada com País estrangeiro» (artigo 8.º do CJM), o que não ocorre nos termos do crime de guerra de tortura previsto no Anexo da Lei n.º 31/2004, podendo este aplicar-se no quadro de um “conflito armado de carácter internacional” ou de “conflito armado de carácter não internacional” (artigo 10.º, n.º 1, alínea b)).

O artigo 49.º, n.º 1, do CJM, por seu turno, consagra igualmente a imprescritibilidade do procedimento criminal e das penas para o crime de guerra de tortura, previsto no artigo 41.º (n.º 1, alínea b)).

Cremos, pois, que uma interpretação adequada a estas circunstâncias permite a conclusão de que as referidas normas incriminatórias se podem aplicar a situações diferenciadas, mantendo reciprocamente autonomia, sendo certo que o crime do CJM prevê a circunstância agravante adicional do n.º 2 do artigo 41.º (que inexistia na Lei n.º 31/2004): atos (praticados) sobre membros de instituição humanitária.

Aqui se pode, pois, surpreender uma relevante assimetria entre tais tipos e o de tortura dos artigos 243.º e 244.º do CP: se o crime de tortura, enquanto crime internacional (de guerra ou contra a humanidade) e de guerra contra as pessoas, é imprescritível, já enquanto crime específico próprio (codificado) não partilha de tal natureza.

²¹ Com o seguinte teor: «1 - Aquele que, sendo português, estrangeiro ou apátrida residindo ou encontrando-se em Portugal, ou contra essas pessoas, em tempo de guerra, praticar ou mandar praticar sobre a população civil, sobre feridos, doentes, náufragos, prisioneiros ou qualquer das pessoas especialmente indicadas no presente capítulo: (...) [b)] Tortura ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, incluindo as experiências biológicas; é punido com pena de prisão de 10 a 25 anos». Nos termos do n.º 2 do preceito, a pena é «(...) agravada de um quinto no seu limite mínimo quando os actos referidos no número anterior forem praticados sobre membros de instituição humanitária».

Tal diferenciação de regimes pode justificar-se tendo em conta a distinta natureza dos interesses jurídico-penais protegidos pelas diversas incriminações: no crime de tortura codificado, tutelam-se interesses jurídicos eminentemente pessoais ou essencialmente individuais; nos crimes de tortura contra a humanidade ou de guerra, estarão em causa interesses que, além de vulnerarem aqueles interesses individuais, violam de forma intolerável interesses supraindividuais – designadamente, e de uma forma indiferenciada, o direito à vida, integridade pessoal, liberdade e segurança dos cidadãos indefesos, de profissionais de saúde e socorro, ou de outras categorias de pessoas vulneráveis, perante abusos de grupos armados formal ou informalmente constituídos, em que se torna difícil (muitas vezes impossível) estabelecer a responsabilidade em termos contemporâneos²² – e que internacionalmente se encontram classificados como crimes imprescritíveis (v.g., o ERTPI).

A CaT ONU/1984 não impõe, contudo, a solução da imprescritibilidade²³. Poderia divisar-se aqui um quadro de potencial confronto entre as normas internacionais de *ius cogens* e o direito interno²⁴, que, todavia, a este propósito se pensa que não se coloca, justamente em virtude de a CaT ONU/1984 manter autonomia face à disciplina do ERTPI, impondo-se no artigo 4.º daquele instrumento a criminalização de todos os atos de tortura com a previsão de penas adequadas à sua gravidade. De todo o modo, o Comité contra a Tortura da ONU considerou, relativamente ao 7.º relatório periódico de Portugal (CAT/C/PRT/7), nas suas 1796.ª e 1799.ª sessões, realizadas em 19 e 20 de novembro de 2019, em Genebra, que deveria ser introduzida uma cláusula de imprescritibilidade quanto ao crime de tortura previsto no Código Penal, «com vista a impedir

²² Questão muito controversa será a do interesse no estabelecimento e salvaguarda da “verdade histórica”, relativamente às situações em que a tortura ocorra de forma sistemática, com a promoção ou conivência de regimes políticos, desiderato que, pela sua inequívoca relevância, e pelas dificuldades político-administrativas de tempestiva perseguição criminal, poderá constituir argumento sério no sentido da imprescritibilidade do crime de tortura.

²³ Apesar do silêncio normativo da CaT ONU/1984, o Comité contra Tortura da ONU tem repetidamente afirmado que, «atendendo à grave natureza» dos atos de tortura, se deveria abolir a prescrição». Cfr. J. A. Hessbruegge, “Justice Delayed, not Denied: Statutory Limitations and Human Rights Crimes” (2012), *Georgetown Journal of International Law*, Winter, 361.

²⁴ Sobre a questão, E. Wet, “The Prohibition of Torture as an International Norm of *jus cogens* and Its Implications for National and Customary Law” (2004), *European Journal of International Law* vol. 15, no. 1, 97-121.

qualquer risco de impunidade relativamente à investigação de atos de tortura e à perseguição e punição dos perpetradores»²⁵.

Se, na verdade, os fundamentos da imprescritibilidade dos crimes de guerra ou dos crimes contra a humanidade são aceitáveis, justamente em função de uma tutela atemporal da dignidade humana e como forma de suprir eventuais situações de impunidade (por encobrimento, manipulação, repressão política), estamos em crer que tais receios não se colocarão num Estado de Direito e que poderiam, por outro lado, afrontar o direito a um processo justo, equitativo e em prazo razoável, postulado pelo artigo 6.º da CEDH e pelo artigo 32.º, n.º 2, da nossa Constituição. Compreendem-se as razões dogmáticas e político-criminais que possam estar subjacentes a uma solução de imprescritibilidade do crime de tortura, mas pensamos que a mesma, a ser consagrada, constituiria também uma incongruência sistemática no sistema sancionatório, porquanto nenhum dos crimes previstos no Código Penal é imprescritível.

Se a imprescritibilidade dos crimes internacionais humanitários é uma solução já adquirida²⁶, nada parece impedir que dogmaticamente se buscasse, entre as hipóteses do regime comum da prescrição (artigos 118.º a 126.º do CP) – que pode surgir como injusta – e a solução da imprescritibilidade – que surgiria como assistemática –, uma alternativa híbrida em que se elevassem os prazos de prescrição do procedimento criminal²⁷ e das penas relativamente ao crime de tortura e se tipificassem causas específicas de suspensão e, eventualmente, de interrupção da prescrição do procedimento e das penas. Assim, poderia pensar-se na hipótese de suspensão da contagem do prazo de prescrição enquanto subsistam circunstâncias que dificultem ou impeçam a investigação dos visados, p. ex., a consagração de uma causa de suspensão do procedimento criminal enquanto os agentes públicos se mantiverem em funções. Paralelamente, tendo em atenção os princípios da segurança jurídica, da atualidade da reação penal e de

²⁵ Com o seguinte teor: «1. The Committee against Torture considered the seventh periodic report of Portugal (CAT/C/PRT/7) at its 1796th and 1799th meetings (see CAT/C/SR.1796 and 1799), held on 19 and 20 November 2019, and adopted the present concluding observations at its 1813rd and 1814th meetings, held on 2 December 2019 (CAT/C/SR.1813 and 1814).

(...)

The State party should ensure that the offence of torture is not subject to any statute of limitations, in order to preclude any risk of impunity in relation to the investigation of acts of torture and the prosecution and punishment of perpetrators».

²⁶ Assim, H. G. Tavares Gomes, *A Questão da Imprescritibilidade do Procedimento Criminal no Direito Internacional* (Dissertação apresentada no âmbito 2.º Ciclo de Estudos em Direito da FDUC – Orientador: Doutor Pedro Caeiro, Coimbra, 2013) (acessível em <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/34760/1/A%20questao%20da%20imprescritibilidade%20do%20procedimento%20criminal%20no%20Direito%20internacional.pdf>).

²⁷ P. ex. integrando o crime do artigo 243.º do CP no elenco da alínea a) do n.º 1 do artigo 118.º do mesmo diploma (sendo o limite máximo da moldura penal de 5 anos de prisão).

um processo equitativo, não deverá essa extensão ou prolongamento dos prazos de prescrição significar uma situação de “imprescritibilidade fática”.

Em suma, uma qualquer solução neste particular domínio, dada a sua sensibilidade, carece de aprofundada reflexão e debate.

4. A reparação das vítimas

A CaT ONU/1984 coloca igualmente elevadas expectativas no tocante aos mecanismos de reparação e de indemnização das vítimas de atos de tortura. No seu artigo 14.º, contempla-se a obrigatoriedade de os Estados providenciarem nos seus sistemas jurídicos pela adoção de garantias conferidas às vítimas de atos de tortura, do direito a obterem reparação e indemnização em termos adequados, incluindo os necessários à sua integral reparação, prevendo-se que, no caso de morte da vítima, a indemnização reverta a favor dos seus herdeiros.

Note-se, preambularmente, que, de acordo com a doutrina²⁸, a noção de vítima de tortura respeita à pessoa que é sujeita a atos de tortura ou a atos ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, o que pode não coincidir com a pessoa de quem se pretende extrair declarações, informações ou confissões, a pessoa que se visa castigar por ato praticado ou supostamente praticado, ou a pessoa que se pretende intimidar. Pode não haver coincidência entre esta(s) pessoa(s) e aquela(s) que é(são) vítima(s) de tortura, porquanto o tipo legal de crime do artigo 243.º do CP prevê expressamente que a vítima seja torturada – numa aceção abrangente – para obter de outrem confissão, depoimento, declaração ou informação, ou para castigar ou intimidar outra pessoa.

Poderá ser questionável que as pessoas – não sujeitas a tortura ou atos equiparados – em relação às quais se pretende que o ato de tortura produza efeito não sejam abrangidas na noção de vítimas, para esses efeitos. Contudo, parece-nos que a sua inclusão seria um alargamento excessivo da noção de vítima (de tortura), transcendendo claramente a teleologia de tutela subjetiva preconizada na CaT ONU/1984, bem como a própria noção legal de vítima consagrada no artigo 67.º-A do CPP.

O mecanismo especial de reparação às vítimas de crimes violentos – o regime aplicável ao adiantamento pelo Estado das indemnizações devidas às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, aprovado pela Lei n.º 104/2009, de 14 de setembro – parece não contemplar expressamente a possibilidade de reparação das vítimas do crime de tortura.

O regime em causa aplica-se às vítimas de crimes violentos: os crimes que se enquadram nas definições legais de criminalidade violenta e de criminalidade

²⁸ Cfr., por todos, M. J. Antunes, *supra* n. 8, 587.

especialmente violenta previstas nas alíneas j)²⁹ e l)³⁰ do artigo 1.º do CPP, além das vítimas do crime de violência doméstica. Nesses conceitos definitórios não estão indicados os crimes contra a integridade pessoal, bem jurídico tutelado pela incriminação da tortura. Na definição de criminalidade violenta parece, assim, estar excluída a tortura, o que pode constituir motivo para alguma perplexidade.

Um exercício sistémico-hermenêutico parece sugerir que, sendo a integridade pessoal um bem jurídico complexo – que abrange uma dimensão da integridade física e da integridade psíquica da pessoa, bem como a liberdade ambulatória, a saúde e mesmo o perigo para a vida –, e atendendo ao limite da pena de prisão (igual a 5 anos), o crime de tortura também se incluirá nos crimes que integram a “criminalidade violenta” (alínea j) do artigo 1.º do CPP), porquanto nele também está em causa a “integridade física” e a “liberdade pessoal”. Esse raciocínio faz recair o crime de tortura na previsão do artigo 1.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), da Lei n.º 104/2009, pelo que as vítimas de tortura seriam contempladas com as garantias oferecidas pela disciplina desse diploma.

Os mecanismos reparatórios do adiantamento da indemnização às vítimas de crimes violentos configuram-se como uma medida substitutiva e antecipatória da reparação da vítima, ficando o Estado, através da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPVC), sub-rogado nos direitos dos lesados contra o autor dos atos de violência e pessoas com responsabilidade meramente civil, dentro dos limites da indemnização prestada, devendo a vítima, posteriormente ao pagamento da provisão ou da indemnização, se obtiver, a qualquer título, uma reparação ou uma indemnização efetiva do dano sofrido, reembolsar a CPVC, total ou parcialmente, no valor correspondente às importâncias recebidas (artigos 15.º, n.º 1, e 16.º, n.º 1, da Lei n.º 104/2009)³¹.

A questão aqui apresentada pode relacionar-se, indiretamente, com a responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos de tortura cometidos pelos seus funcionários e agentes (excluindo-se, aqui, as hipóteses de intervenção de não funcionários, nomeadamente de órgãos policiais ou da administração prisional, na perpetração do crime). Em princípio, a efetivação da responsabilidade civil dos agentes de crime de tortura será tramitada conexamente com a

²⁹ Cujo teor é o seguinte: “Criminalidade violenta” as condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou a autoridade pública e forem puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos;».

³⁰ Cujo teor é o seguinte: “Criminalidade especialmente violenta” as condutas previstas na alínea anterior puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 8 anos;».

³¹ Importa sublinhar que as vítimas de criminalidade violenta e de criminalidade especialmente violenta são sempre consideradas como vítimas especialmente vulneráveis, para efeitos do disposto no n.º 1, alínea b), do artigo 67.º-A do CPP e, eventualmente, para os efeitos do disposto nos artigos 20.º a 27.º da Lei n.º 130/2015, de 4 de setembro (Estatuto da vítima).

ação penal, no caso de dedução de acusação, mediante pedido de indemnização civil (artigos 71.º e 72.º do CPP).

Nos casos em que sejam demandados os concretos agentes do crime de tortura, o Estado pode ser civilmente responsabilizado³², de forma solidária com os respetivos titulares de órgãos policiais ou prisionais, funcionários e agentes, se as ações ou omissões tiverem sido por eles cometidas – de forma exclusivamente dolosa (o crime de tortura não é punível a qualquer outro título) – no exercício das suas funções e por causa desse exercício (artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro).

É, todavia, questionável o modo de exercitação processual desta responsabilidade civil (solidária)³³ extracontratual do Estado, por factos ilícitos praticados por agentes públicos no exercício (abusivo) das suas funções, que se reconduzem ao exercício da atividade administrativa policial ou de administração prisional.

Se é certo que a efetivação de responsabilidade civil extracontratual do Estado por factos ilícitos ocorre, por regra, perante a jurisdição administrativa (artigos 22.º³⁴ e 212.º da Constituição da República Portuguesa, 1.º, n.ºs 1 e 2, 8.º, n.ºs 1 e 2, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas – RREE, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e 4.º, n.º 1, alínea f), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro), o artigo 1.º, n.º 1, Parte final do RREE parece viabilizar a efetivação da responsabilidade civil do Estado perante o tribunal criminal, no caso de os factos integrarem a prática de ilícito criminal e ter sido exercida a ação penal contra os concretos responsáveis diretos, assim configurando um caso «previsto em lei especial», passível de conhecer um desvio à regra da competência da jurisdição administrativa.

O disposto nos artigos 71.º e 72.º do CPP, ao consagrar o princípio da adesão, não execciona, nem é incompatível, com a efetivação da responsabilidade

³² Importa sublinhar a não punibilidade do Estado, ao abrigo do artigo 11.º, n.º 2, I Parte do CP.

³³ Cumpre lembrar neste ponto a discussão doutrinal sobre a propriedade da designação responsabilidade civil, sugerindo-se as expressões alternativas “patrimonial” ou “pública”. Por todos, J. J. Lechuga, *La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos en el Derecho Español* (Marcial Pons, 1999).

³⁴ O artigo 22.º da Constituição tem sido sempre interpretado no sentido de impor a responsabilidade da Administração independentemente de o (f)acto ou omissão lesivos poderem ser imputados a um sujeito em concreto, seja porque este atuou (apenas) com culpa leve, seja por estar em causa um funcionamento anormal dos serviços (cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 236/2004, de 12.04.2004 - proc. n.º 92/03).

civil contra responsáveis meramente civis – como é, no caso, o Estado – relativamente a danos causados por funcionários agentes de crime de tortura³⁵.

A opção pelo exercício da competente ação na jurisdição administrativa – demandando os eventuais responsáveis e o Estado – será a forma adequada de processo, caso o processo-crime não chegue à fase de acusação/pronúncia, mas em que a vítima pretenda discutir a responsabilidade por danos físicos, psicológicos, emocionais e patrimoniais decorrentes de tortura. Já no caso de um processo por crime de tortura seguir (após acusação/pronúncia) para a fase de julgamento, parece-nos adequado o recurso ao pedido de indemnização civil, podendo aí o Estado ser demandado.

Tais soluções aconselham, em nosso entendimento, a que o Estado tome a iniciativa da reparação das vítimas de tortura antes da utilização por estas de um dos mecanismos processuais à sua disposição: a ação por responsabilidade civil extracontratual ou o pedido de indemnização civil³⁶.

A propósito das questões da reparação das vítimas de tortura, poderia ainda conceber-se a instituição de mecanismos arbitrais ou de mediação, as quais não se afiguram de todo em todo adequadas, porquanto não faria sentido uma “transação” com o torturador e mesmo a substituição dos agentes torturadores pelo Estado potenciaria o desvirtuamento da igualdade das “partes”, além de poder constituir uma forma de condicionamento da autonomia da vítima.

O que se propõe é que, em vez dos mecanismos de (mero) adiantamento indemnizatório das vítimas de tortura (nos termos da Lei n.º 104/2009), fosse ponderada a instituição de um sistema – integrado ou não na CPVC – de indemnização e de reparação das vítimas de tortura a título definitivo – exonerando as vítimas do encargo de obrigatoriamente terem de pleitear em processo penal ou civil –, salvaguardando sempre o direito de regresso do Estado perante os agentes torturadores cuja responsabilidade viesse a ser disciplinar ou criminalmente estabelecida.

5. Considerações conclusivas

Neste texto, procurámos sublinhar a necessidade de (re)afirmação do princípio da proibição absoluta e incondicional das práticas de tortura.

³⁵ No sentido da atribuição aos tribunais criminais da competência para apreciarem pedidos de indemnização por responsabilidade civil extracontratual do Estado conexas com a responsabilidade criminal individual de agentes ou funcionários, cfr. Acórdãos da Relação de Lisboa de 08.05.2012 – proc. 499/08.2TBSB-A.L1-5 e 07.02.2019 – proc. 89/16.0NLLSB-AG.L1-9.

³⁶ Note-se ainda que, de acordo com o n.º 2 do artigo 14.º da CaT ONU/1984, «O presente artigo não exclui qualquer direito a indemnização que a vítima ou outra pessoa possam ter por força das leis nacionais», o que parece sugerir a possibilidade de acionamento cumulativo dos autores de atos de tortura e os mecanismos de reparação antecipatória.

Quanto à questão da (im)prescritibilidade do procedimento criminal e das penas do crime de tortura comum ou codificado, entre a hipótese do regime comum da prescrição (artigos 118.º a 126.º do CP) – que pode surgir como injusta – e a solução da imprescritibilidade – que apareceria como assistemática –, deve avaliar-se a alternativa da tipificação de novas causas de suspensão e de interrupção dos prazos prescricionais (do procedimento e das penas).

Colocar-se-á, também, ao legislador nacional a necessidade de ponderação da expressa inclusão do crime de tortura – enquanto crime contra a integridade pessoal – nos pressupostos legais do regime de adiantamento de reparação e indemnização às vítimas ou, alternativamente, a instituição de um sistema de reparação direta e definitiva, com salvaguarda do direito de regresso do Estado.

Em tempos de incerteza, o reforço de princípios no sentido de uma absoluta e incondicional proibição da tortura, de um regime de prescrição alargada e de reparação direta das suas vítimas pelo Estado significará uma inequívoca opção por *standards* de Civilização e de Humanismo.

Referências bibliográficas

A. F. Velloso, “A imprescritibilidade dos crimes internacionais” (2015), *Ânima* – Revista Electrónica do Curso de Direito das Faculdades Opet, Ano VII, 13 (acessível em http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Ana_Flavia_Velloso_a_imprescritibilidade.pdf).

E. Wet, “The Prohibition of Torture as an International Norm of *jus cogens* and Its Implications for National and Customary Law” (2004), *European Journal of International Law* vol. 15, no. 1, 97-121.

F. Costa, “Vida e morte em direito penal (esquisto de alguns problemas e tentativa de autonomização de um novo bem jurídico)” (jan.-jun. 2004), *RPCC* – Ano 14.º – Fasc. 1 e 2 – *Número Especial: Novas Tarefas e Fronteiras do Direito (Penal) Médico*, 171-196.

_____, “O Direito Penal e o Tempo (Algumas Reflexões Dentro do Nosso Tempo e em Redor da Prescrição)”, in *Linhas de Direito Penal e de Filosofia – Alguns Cruzamentos Reflexivos* (Coimbra Editora, 2005), 163-190.

H. G. Tavares Gomes, *A Questão da Imprescritibilidade do Procedimento Criminal no Direito Internacional* (Dissertação apresentada no âmbito 2.º Ciclo de Estudos em Direito da FDUC – Orientador: Doutor Pedro Caeiro, Coimbra, 2013) (acessível em <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/34760/1/A%20questao%20da%20imprescritibilidade%20do%20procedimento%20criminal%20no%20Direito%20internacional.pdf>).

J. A. Hessbruegge, “Justice Delayed, not Denied: Statutory Limitations and Human Rights Crimes” (2012), *Georgetown Journal of International Law*, Winter.

J. J. Lechuga, *La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos en el Derecho Español* (Marcial Pons, 1999).

M. J. Antunes, anotação ao artigo 243.º do Código Penal, in J. de Figueiredo Dias (dir.), *Comentário Conimbricense do Código Penal*, vol. II (Coimbra Editora, 1999), 585 a 595.

M. L. Assunção, “TPI e Lei Penal e Processual Penal Portuguesa”, in *O Tribunal Penal Internacional e a Ordem Jurídica Portuguesa* (Coimbra Editora, 2004).

P. Caeiro, *Fundamento, Conteúdo e Limites da Jurisdição Penal do Estado. O Caso Português* (Wolters Kluwer-Coimbra Editora, 2010).

P. Gama da Silva, *A Prescrição no Direito Penal Português* (Almedina – Coleção de Jurisprudência, 2018).

S. Oliveira e Silva, *O Arguido como Meio de Prova Contra Si Mesmo – Considerações em Torno do Princípio Nemo Tenetur Se Ipsum Accusare* (Col. Teses, Almedina, 2018).

T. Beleza, “A morte e a donzela”, in *Estudos Comemorativos dos 10 Anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa*, vol. L (Almedina, 2008).

W. Brito, “Tribunal Penal Internacional: Uma Garantia Jurisdicional Para a Protecção dos Direitos da Pessoa Humana”, *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* (2000), vol. 76, 81-128.

BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DA CONVENÇÃO DO CIBERCRIME PARA A OBTENÇÃO DE PROVAS DIGITAIS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Luis Felipe Miranda Ramos

*Doutorando em Ciências Jurídicas pela Escola de Direito da Universidade do Minho e Investigador do JusGov – Centro de Investigação em Justiça e Governação
id8856@alunos.uminho.pt*

Resumo: Os avanços tecnológicos observados nas últimas décadas proporcionam incontáveis benefícios para a sociedade em geral, embora tragam consigo potenciais riscos, quando utilizados por agentes mal-intencionados que visam o cometimento de crimes. A utilização de ferramentas digitais para o cometimento de delitos tem sido denominada de cibercrime e tem exigido profundas mudanças no mundo jurídico para enfrentar os desafios impostos para a investigação, coleta de provas, julgamento e aplicação de sanções aos criminosos virtuais. Apesar de diversos países contarem atualmente com legislações próprias que tipificam condutas cometidas por meio de sistemas informáticos, a complexidade do tema exige uma abordagem mais colaborativa, por meio da cooperação internacional entre os países, com o intuito de proporcionar auxílio mútuo às autoridades encarregadas da investigação e julgamento dessas condutas criminosas. O Brasil, nos últimos anos, tem editado normas que visam atualizar seu ordenamento jurídico para essa nova realidade digital, com foco especial na previsão legal de novos crimes que podem ser cometidos pela Internet. Entretanto, a ausência de regulamentação sobre aspetos processuais e referentes à

obtenção de provas eletrônicas armazenadas em outros países têm-se mostrado um obstáculo à efetiva persecução penal. Por outro lado, desde 2001, está em vigor a Convenção de Budapeste sobre o Cibercrime, que visa harmonizar as legislações dos países signatários a respeito de diversas condutas criminais, além de prever regras para uma cooperação internacional rápida e eficiente, mas que até o presente momento o Brasil não aderiu. Desta maneira, o presente trabalho visa apresentar alguns potenciais benefícios da adesão do Brasil à Convenção do Cibercrime.

Palavras-chave: Convenção de Budapeste – Cibercrime – Marco Civil da Internet – Prova digital – Cooperação Internacional.

1. Introdução

Na sociedade atual, o comportamento humano tem sofrido um grande impacto em decorrência da proliferação da tecnologia, sendo que as formas com que interagimos com o governo, com as empresas e com outras pessoas têm sido reestruturadas ao redor de tecnologias de comunicação mediadas por computador¹.

No entanto, essa contínua evolução do comportamento humano como resultado das inovações tecnológicas tem criado oportunidades únicas para o cometimento de diferentes crimes e abusos, que também se valem de uma contínua transformação tecnológica².

Nas últimas três décadas, tem havido um aumento significativo na utilização das tecnologias de informação e comunicação por criminosos comuns e novas aplicações da tecnologia para criar novas formas de crime que não existiam anteriormente, tendo dentre suas principais consequências imensos prejuízos financeiros, tanto para os cidadãos quanto para as empresas e os Estados envolvidos³.

A história demonstra que a relação entre crime e tecnologia não é uma novidade e que o potencial para criação de danos nunca está muito distante de

¹ T. J. Holt, A. M. Bossler e K. C. Seigfried-Spellar, *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction* (Routledge, 2015), 4.

² Neste sentido, v., e.g., D. S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Crime and Society Series* (Polity Press, 2007), 2; A. Zavrsnik, “Cybercrime definitional challenges and criminological particularities” (2008), *Masaryk University Journal of Law and Technology* 2(2).

³ Como pode ser concluído pela análise de alguns estudos em que esta questão é analisada. V., e.g., T. J. Holt, A. M. Bossler e K. C. Seigfried-Spellar, *supra* n. 1, 4; A. S. Neto, *Cibercrime e Cooperação Penal Internacional: Um Enfoque à Luz da Convenção de Budapeste* (Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas – Universidade Federal da Paraíba, Faculdade de Direito, João Pessoa, Paraíba, 2009), 72; A. Zavrsnik, *supra* n. 2.

qualquer desenvolvimento tecnológico aparentemente benéfico⁴. E, ainda que os avanços tecnológicos surjam “como um campo de liberdade à margem do direito”, a necessidade de aplicação do direito à sociedade da informação trouxe consigo questões de “competência territorial, de ausência de previsão legal dos seus mecanismos, de realidades novas dificilmente enquadráveis nos mecanismos legais existentes”⁵.

Ao lidar com a questão das novas formas de cometimento de crimes com o auxílio de ferramentas informáticas, também denominados de crimes informáticos ou cibercrimes, a primeira dificuldade que se enfrenta é a de conceituar de maneira adequada o objeto de estudo⁶. Isso porque é possível identificar três maneiras pelas quais os sistemas informáticos e a telefonia móvel podem ser abusados ou subvertidos por criminosos: (i) como um meio para comunicação e o desenvolvimento de subculturas *online*; (ii) como um mecanismo para alvejar recursos sensíveis e se envolver no crime; e (iii) como um dispositivo incidental para facilitar o cometimento de um crime e fornecer evidências de atividades criminais tanto *online* quanto *offline*⁷.

Nesse sentido, é possível distinguir os crimes informáticos como sendo: (a) cibercrimes-alvo, em que o sistema informático é o alvo do crime; (b) cibercrimes instrumentais, em que o computador é utilizado como ferramenta para facilitar a prática de um crime convencional; e (c) crimes em que o computador é apenas um aspeto incidental para o cometimento do crime, mas com importância significativa para as autoridades investigativas, por conterem evidências do crime praticado⁸.

O termo “ciberespaço” foi cunhado pelo escritor William Gibson e popularizado em seu romance *Neuromancer*, em 1985, como uma maneira de descrever um ambiente virtual construído mentalmente em que atividades computadorizadas interligadas em rede aconteciam. E, de uma maneira geral, o termo “cibercrime” passou a designar os crimes que eram cometidos naquele ambiente, vindo assim a simbolizar insegurança e risco *online*⁹.

Mais recentemente, a Comissão Europeia, numa comunicação ao Parlamento Europeu, definiu o cibercrime como sendo “actos criminosos praticados

⁴ D. S. Wall, *supra* n. 2.

⁵ P. D. Venâncio, *Lei do Cibercrime: Anotada e Comentada* (Coimbra Editora, 2011) 14-15.

⁶ A. S. Neto, *supra* n. 3, 63-65.

⁷ T. J. Holt, A. M. Bossler e K. C. Seigfried-Spellar, *supra* n. 1, 4-5.

⁸ J. J. Oerlemans, *Investigating Cybercrime* (Tese de doutoramento – Universiteit Leiden, 2017), 11.

⁹ D. S. Wall, *supra* n. 2, 10.

com recurso a redes de comunicações electrónicas e sistemas de informação ou contra este tipo de redes e sistemas”¹⁰.

No intuito de elaborar uma definição mais específica, a doutrina tem, já há alguns anos, colaborado para o aperfeiçoamento do conceito. Há quem entenda que “o conceito de criminalidade por computador abarca todos os comportamentos ilegais penalmente puníveis, que emergem dum processamento automático de dados”¹¹. Outros autores definem os crimes informáticos como sendo aqueles que “têm por instrumento ou por objecto sistemas de processamento electrónico de dados, ou estão de alguma forma significativa associados à utilização de tais sistemas”¹². Ainda, alguns autores sustentam que no conceito de criminalidade informática é possível incluir “todos aqueles crimes que têm por objecto o computador (numa noção ampla, abrangendo não só o computador propriamente dito como também todo o material periférico), bem como todos aqueles que têm o computador como instrumento do crime”¹³.

Uma definição mais atual de criminalidade informática, em sentido amplo, é expressada como sendo aquela que engloba todas as atividades que podem ser praticadas por meios informáticos, enquanto, em sentido estrito, trata-se apenas daqueles crimes em que o elemento digital aparece como parte integrante do tipo legal ou mesmo com seu objeto de proteção¹⁴.

Há ainda autores que argumentam que antigamente havia uma diferenciação entre os conceitos de cibercrime e de crime informático, sendo que o primeiro tipo englobava todos os crimes em que o agente utiliza conhecimentos especiais do ciberespaço, enquanto o segundo tipo envolvia os crimes em que o agente utiliza conhecimentos especiais de tecnologias informáticas. Entretanto, tendo em vista que praticamente todos os computadores hoje estão conectados em rede, não há mais a necessidade de segmentar essas condutas¹⁵.

Um dos conceitos mais abrangentes de cibercrime, levando em consideração o contexto português, é o que o define como sendo o “facto tipificado na lei como crime que é praticado através da utilização de um sistema informático na

¹⁰ Comissão Europeia, “Towards a general policy on the fight against cybercrime” (2007), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Committee of the Regions COM(2007) 267 final.

¹¹ A. V. Silva, “Criminalidade por computador, na R.F.A” (1985), *Scientia Iuridica* XXXIV: 197/198, 382.

¹² J. A. Vellozo e M. A. Rocha, “Criminalidade informática: modos de execução” (1986), *Scientia Iuridica* XXXV: 199/204, 173.

¹³ J. F. Costa e H. Moniz, “Algumas reflexões sobre a criminalidade informática em Portugal” (1997), *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* LXXIII: 73, 298.

¹⁴ P. D. Venâncio, *supra* n. 5, 17.

¹⁵ T. J. Holt, A. M. Bossler e K. C. Seigfried-Spellar, *supra* n. 1, 9.

ação do art.º 2.º, al. a), da Lei n.º 109/2009 ou em que o sistema informático é o objeto da ação, ainda que como alvo simbólico, ou dito de outro modo, o facto tipificado na lei como crime em que o sistema informático é objeto ou instrumento do crime ou cujo cometimento está significativamente ligado à utilização de um sistema informático”¹⁶.

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento na quantidade e na sofisticação dos crimes praticados por meio de sistemas informáticos, com a migração de delitos tradicionais como fraude, ameaça e extorsão para um ambiente digital, e cuja persecução penal não dispõe de ferramentas jurídicas adequadas, o que resulta em dificuldades para a prevenção da criminalidade e um aumento da insegurança coletiva. Atualmente, em decorrência das restrições de locomoção impostas pela pandemia de COVID-19, é possível identificar um aumento ainda maior na incidência de crimes cometidos por meio de sistemas eletrónicos ou informáticos¹⁷.

A obtenção de provas em formato eletrónico para a comprovação da autoria e da materialidade das mais diversas condutas criminosas, como homicídio, crimes financeiros, corrupção de agentes públicos, etc., também passa a ter uma importância destacada, pois cada vez mais evidências, como e-mails, intercetações telemáticas e ficheiros armazenados em servidores remotos, são utilizadas para a resolução desses crimes.

E, na medida em que a criminalidade informática vem aumentando, aliada à crescente necessidade da obtenção de provas digitais para a sua adequada persecução penal, diversos países passaram a editar legislações que forneçam as devidas condições para as autoridades combaterem o cibercrime.

Entretanto, considerando que os meios digitais não são limitados pelas fronteiras geopolíticas dos países, apenas por meio de uma cooperação internacional rápida e eficiente é que a obtenção das evidências digitais e o efetivo combate ao cibercrime pode ser realizado.

2. A Convenção do Cibercrime

Um crime cometido no ciberespaço não acontece em apenas um lugar. Ao contrário, seus efeitos podem atingir vítimas em qualquer lugar do planeta, independente de limites e fronteiras geográficas¹⁸. E, tendo em consideração que

¹⁶ D. R. Nunes, *Os Meios de Obtenção de Prova Previstos na Lei do Cibercrime* (Gestlegal, 2018), 14.

¹⁷ D. Buil-Gil, F. Miró-Llinares, A. Moneva, S. Kemp e N. Díaz-Castaño, “Cybercrime and shifts in opportunities during COVID-19: a preliminary analysis in the UK” (2021), *European Societies* 23, 2.

¹⁸ J. B. Hill e N. E. Marion, *Introduction to Cybercrime: Computer Crimes, Laws, and Policing in the 21st Century* (Praeger Security International, 2016), 223.

o combate à cibercriminalidade é um fenômeno mundial, surge a discussão sobre a necessidade de se estabelecer uma regulação internacional sobre a temática.

Entretanto, apesar de haver um consenso de que o cibercrime representa um problema importante para todas as nações, a busca por uma solução conjunta tem sido dificultada pelo fato de que cada país desenvolve sua própria legislação sobre a matéria, muitas vezes apresentando diversas inconsistências entre elas¹⁹.

No intuito de enfrentar essa dificuldade no contexto europeu, em 1983, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) organizou um grupo de especialistas na matéria que começaram a discutir os problemas jurídicos representados pela criminalidade transnacional e, com base nos resultados dessa discussão, recomendaram um processo de harmonização e internacionalização das legislações nacionais sobre cibercrime, definindo um conjunto de ofensas que todos os países deveriam tipificar em seus ordenamentos jurídicos²⁰.

Em 1985, o Conselho da Europa também reuniu um painel de especialistas para estudar os problemas resultantes da cibercriminalidade, expedindo uma recomendação que enfatizava a necessidade de tipificar um conjunto de condutas similar às propostas pela OCDE. Já em 1995, o Conselho da Europa emitiu uma recomendação com princípios a serem seguidos no que respeita aos procedimentos criminais relacionados com a investigação de cibercrimes, em especial no que refere a buscas em sistemas informáticos, apreensão de dados, vigilância eletrônica e cooperação com as autoridades²¹. E, por fim, em 1997, o Conselho da Europa convocou outro grupo de especialistas, com o objetivo de redigir um esboço de tratado sobre o cibercrime que harmonizasse as legislações nacionais dos Estados-Membros sobre crimes informáticos e seus procedimentos de investigação²².

Desse esforço resultou a elaboração da Convenção do Cibercrime do Conselho da Europa (CETS n.º 185)²³, também conhecida como Convenção de Budapeste sobre o Cibercrime, de 23.11.2001, e que é considerada como o primeiro tratado internacional a abordar a temática do cibercrime e a tentar harmo-

¹⁹ *Idem, ibidem.*

²⁰ S. W. Brenner, *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes* (Northeastern University Press, 2012), 185.

²¹ J. B. Hill e N. E. Marion, *supra* n. 18, 231.

²² S. W. Brenner, *supra* n. 20, 185.

²³ Conselho da Europa, "Convention on Cybercrime", disponível em: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561>, consultado em 20 de dezembro de 2020.

nizar as legislações nacionais dos países signatários no tocante a essas ofensas²⁴. A Convenção consiste em uma política internacional que visa facilitar a coleta de evidências, o julgamento e a punição daqueles agentes que cometam ciber-crimes²⁵.

Como consta do preâmbulo da Convenção, o seu objetivo é suprir as lacunas e resolver os conflitos existentes nas legislações nacionais que restringem a capacidade das autoridades de combater o cibercrime, buscando uma política criminal comum que proteja a sociedade contra o cibercrime, por meio da adoção de uma legislação apropriada e pelo fomento de uma maior cooperação internacional, que seja rápida e que funcione bem em questões criminais²⁶. Ainda, visa facilitar a investigação e o processamento de crimes relacionados a sistemas e dados informáticos de maneira mais eficiente e permitir a coleta de provas de um crime em formato eletrônico. No entanto, cabe destacar que a Convenção busca um equilíbrio entre o interesse na aplicação da lei e o respeito aos direitos humanos, em especial a liberdade de expressão e a privacidade.

A Convenção do Cibercrime é o único acordo internacional elaborado para enfrentar os danos causados pelo cibercrime e atualmente é o único documento global orientado a impedir cibercrimes internacionais, além de ser o único diploma internacional a fornecer um arcabouço jurídico para a cooperação internacional em matéria de cibersegurança²⁷.

A adesão de um país à Convenção de Budapeste acarreta na aceitação de criar um conjunto mínimo de normas legais voltadas para crimes informáticos específicos (por exemplo, acesso ilegítimo e intercepção ilegítima de sistemas e dados informáticos e falsificação e fraude cometidos por meio de sistemas informáticos), bem como participar com outros países na investigação de ataques e crimes cometidos por meio de sistemas digitais.

3. Benefícios da adesão brasileira à Convenção do Cibercrime

Atualmente, o Brasil é o quarto país com mais utilizadores de Internet no mundo, com uma presença *online* em 2018 na ordem de 70% da população²⁸. Entretanto, o arcabouço jurídico brasileiro não se encontra preparado para responder de maneira adequada às demandas de uma população virtual dessa

²⁴ T. J. Holt, A. M. Bossler e K. C. Seigfried-Spellar, *supra* n. 1, 66.

²⁵ J. B. Hill e N. E. Marion, *supra* n. 18, 232.

²⁶ Conselho da Europa, “Convention on Cybercrime”, *supra* n. 23.

²⁷ J. B. Hill e N. E. Marion, *supra* n. 18, 232.

²⁸ International Telecommunication Union (ITU), “Percentage of individuals using the Internet”, disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Individuals_Internet_2000-2018_Dec2019.xls, consultado em 24 de dezembro de 2020.

dimensão, e que permanece em constante crescimento, em especial na seara do direito penal, sendo que o Código Penal data de 1940, não regulando, portanto, determinados comportamentos inerentes à sociedade moderna e tendo sofrido apenas modificações pontuais nos últimos anos, com o intuito de albergar alguns crimes cometidos em ambientes digitais.

No aspeto processual penal, cuja legislação remonta a 1941, igualmente verificam-se diversas lacunas no que concerne à investigação, ao processamento e ao julgamento de causas que envolvem delitos cometidos em ambientes cibernéticos.

Com relação ao direito penal material, nos últimos anos, foram editadas leis no intuito de tipificar condutas que envolvessem, de alguma maneira, sistemas informáticos, tendo como foco principal o potencial de disseminação pela Internet dos danos causados por essas condutas. Nesse sentido, importante destacar a Lei n.º 11.829, de 25 de novembro de 2008, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na Internet, e a Lei n.º 12.737, de 30 de novembro de 2012, que tipificou criminalmente alguns delitos informáticos, atualizando o Código Penal brasileiro. No entanto, nenhuma dessas normas abordou questões relacionadas com a investigação criminal de cibercrimes.

O contexto do direito penal processual só mereceu atenção em 2014, com a edição da Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, e que foi popularmente denominada de “Marco Civil da Internet (MCI)”, onde houve a preocupação com as regras sobre a preservação de dados, mas que, na prática, têm-se mostrado ainda insuficientes perante a complexidade dos casos concretos.

Dessa maneira, cotidianamente, tem-se observado a dificuldade das autoridades policiais e judiciárias na investigação, processamento, julgamento e condenação de agentes que cometem delitos por meio de sistemas informáticos, em especial quando é necessária a coleta de provas digitais armazenadas em computadores situados em outros países.

Em decorrência da conjuntura apresentada, a adesão brasileira à Convenção de Budapeste sobre o Cibercrime pode apresentar diversos benefícios para a sociedade brasileira, em geral, e para o ordenamento jurídico nacional, em particular.

Assim, sem qualquer pretensão de elencar de maneira exaustiva os potenciais proveitos que a Convenção do Cibercrime pode oferecer ao Brasil, a seguir são referidos alguns pontos que merecem destaque positivo:

a) *Aprimoramento da legislação penal* – A adesão do Brasil à Convenção do Cibercrime acarreta uma obrigação ao Poder Legislativo de editar normas de direito penal material que tipifiquem, no ordenamento jurídico nacional, os crimes previstos nos artigos 2.º a 11.º da Convenção, dessa maneira suprimindo lacunas na legislação brasileira vigente, que prejudicam a adequada persecução de crimes cometidos por meios digitais ou com recurso a sistemas informáticos.

Atualmente, podemos referir que os crimes de acesso ilegítimo²⁹, intercepção ilegítima³⁰, interferência em dados³¹, interferência em sistemas³², uso abusivo de dispositivos³³, além de infrações relacionadas com pornografia infantil³⁴, encontram alguma previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, algumas condutas tipificadas pela Convenção do Cibercrime ainda não foram tipificadas no direito penal brasileiro.

Ainda, a adesão à Convenção estabelece um comprometimento em adotar medidas legislativas de caráter processual que instituem poderes e procedimentos para fins de investigação e persecução penal, em especial no tocante à obtenção de provas em formato eletrônico, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, alínea c), da Convenção.

Exemplo da dificuldade atual de persecução de crimes cometidos por meios eletrônicos no Brasil pode ser observado no julgamento de casos que envolvem o delito de estelionato (em Portugal, esse tipo penal corresponde ao crime de burla previsto nos artigos 217.º e 218.º do Código Penal), em que o começo da execução do crime ocorre em território brasileiro, mas o resultado se manifesta apenas em território estrangeiro. Nestes casos, por ausência de adesão do Brasil a tratado ou convenção internacional que traga disposição acerca do crime de estelionato, há uma dificuldade de fixação do juízo competente para processar e julgar esses casos entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, o que resulta em tumulto na tramitação do processo³⁵.

²⁹ Previsto no artigo 2.º da Convenção e no artigo 154-A, *caput*, do Código Penal brasileiro.

³⁰ Previsto no artigo 3.º da Convenção e no artigo 154-A, §3.º, do Código Penal brasileiro.

³¹ Previsto no artigo 4.º da Convenção e, em parte, no artigo 313-A do Código Penal brasileiro.

³² Previsto no artigo 5.º da Convenção e no artigo 266 do Código Penal brasileiro.

³³ Previsto no artigo 6.º da Convenção e, em parte, no artigo 154-A, § 1.º, do Código Penal brasileiro.

³⁴ Previstas no artigo 9.º da Convenção e nos artigos 240, 240-A e 240-B da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

³⁵ Ver a respeito as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n.º 145.839-SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJE 12/05/2016, e nos autos do Conflito de Competência n.º 126.768-MG, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira, DJE 10/05/2013.

b) Obtenção de provas digitais – O Marco Civil da Internet, nos seus artigos 10 a 23, prevê disposições acerca da preservação de dados de registro, conexão e comunicação de utilizadores de Internet, bem como condições e requisitos para que as autoridades públicas possam aceder esses dados e utilizá-los em investigações criminais. Essas disposições, apesar de servirem para complementar a legislação processual penal brasileira, no entanto, ainda apresentam algumas lacunas que podem ser completadas pelas normas previstas na Convenção do Cibercrime.

A Convenção traz, em sua Secção 2 (artigos 14.º a 21.º), regras abrangentes para a conservação expedita de dados informáticos, a conservação e a divulgação parcial de dados de tráfego, regras de injunção, busca e apreensão de dados informáticos, a recolha em tempo real de dados relativos ao tráfego e a interceção de dados relativos ao conteúdo de comunicações ocorridas no território de um país signatário da Convenção, por meio de um sistema informático.

Desta maneira, a adoção pelo Brasil da Convenção do Cibercrime pode servir não apenas para a persecução de crimes cibernéticos, mas especialmente para a obtenção de provas em meios digitais e que estão presentes em quase todos os delitos atualmente, desde fraudes financeiras até ao tráfico internacional de drogas, visto que a obtenção destas provas depende da existência de acordos de cooperação internacional, quando não forem atendidos os requisitos determinados pelo Marco Civil da Internet.

c) Acesso direto a provas eletrônicas em consonância com a legislação brasileira – O artigo 32.º da Convenção do Cibercrime regula o acesso transfronteiriço a dados informáticos armazenados, com consentimento ou quando são acessíveis ao público. Por meio deste dispositivo, uma parte signatária da Convenção prescinde de autorização de outra parte para aceder a dados informáticos armazenados acessíveis ao público (fonte aberta), bem como aceder ou receber, por meio de um sistema informático situado no seu território, dados informáticos armazenados situados no território de outra parte, bastando para isso o consentimento legal e voluntário da pessoa legalmente autorizada a divulgar esses dados.

Apesar de o artigo 11 do Marco Civil da Internet determinar a aplicação da jurisdição brasileira aos dados coletados, armazenados, guardados ou tratados por provedores de conexão e de aplicações de Internet, quando pelo menos um desses atos ocorra em território brasileiro, ou que o serviço seja disponibilizado ao público brasileiro, o texto da Convenção pode respaldar a aplicação da legislação nacional, em especial em casos que envolvam países com os quais o Brasil não possua tratado bilateral sobre acesso a dados digitais.

d) Reconhecimento da soberania nacional referente ao acesso direto a provas digitais – Ainda que o já referido artigo 11 do Marco Civil da Internet deter-

mine que os dados coletados, armazenados, guardados ou tratados em território brasileiro por empresa sediada no exterior, mas que mantenha filial em território nacional ou que pertença a um grupo econômico com estabelecimento em território nacional, devam ser fornecidos às autoridades judiciais brasileiras, mesmo que mantidos armazenados fora do país, tal dispositivo é alvo constante de tentativas de lhe negar vigência.

Ao estabelecer que os dados coletados no Brasil devem ser acessíveis a autoridades brasileiras diretamente, desde que respeitados os ditames do devido processo legal, o artigo 11 da Lei n.º 12.965/14 apenas reflete questões básicas de soberania. Por outro lado, o artigo 18.º da Convenção do Cibercrime apresenta conteúdo semelhante ao do Marco Civil da Internet, de maneira que a adesão do Brasil à Convenção proporcionará à legislação nacional um respaldo de direito internacional público, tornando mais difícil às corporações estrangeiras não cumprirem a legislação brasileira.

e) Harmonização legislativa – A Convenção do Cibercrime foi elaborada com o objetivo de harmonizar os elementos relativos a infrações no contexto do direito penal substantivo na área da cibercriminalidade, definindo os poderes necessários para investigar e intentar ações penais relativas a tais infrações, assim como a outras infrações cometidas por meio de um sistema informático ou às provas com elas relacionadas e existentes sob a forma eletrônica, além de implantar um regime rápido e eficaz de cooperação internacional³⁶.

Isso significa que todos os países signatários da Convenção devem adotar regras de combate ao cibercrime semelhantes, tendo as normas da própria Convenção como modelo, de maneira a facilitar a cooperação internacional em investigações, a obtenção de provas digitais e a eventual extradição dos envolvidos no cometimento desses crimes.

f) Adoção por vários países – Atualmente, a Convenção do Cibercrime é adotada por 65 países, sendo 44 membros do Conselho da Europa e 21 não-membros. Desses últimos, cabe destacar que 8 são países latino-americanos: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguai e Peru³⁷.

Isso ressalta a importância da adesão brasileira à Convenção de Budapeste, permitindo assim a harmonização das legislações e, consequentemente, proporcionar uma maior facilidade no combate ao crime na região.

³⁶ Conselho da Europa, “Minuta do Relatório Explicativo”, disponível em: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa429>, consultado em 27 de dezembro de 2020.

³⁷ Conselho da Europa, “Chart of signatures and ratifications of Treaty 185”, disponível em: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=XOPFsmcb, consultado em 20 de dezembro de 2020.

g) *Ampliação das hipóteses de cooperação* – A Convenção de Budapeste prevê, em seu artigo 27.º, procedimentos relativos aos pedidos de auxílio mútuo na ausência de acordos internacionais aplicáveis entre as partes requerente e requerida. Esse dispositivo permite a cooperação entre todos os países signatários, mesmo que não exista um acordo bilateral de cooperação em matéria penal entre eles, o que aprimora e agiliza a obtenção de provas digitais que dependem da cooperação desses países.

h) *Ampliação da rede 24/7 de pontos de contato* – A eficácia da luta contra as infrações cometidas por meio de sistemas informáticos e a eficácia da recolha de provas sob a forma eletrônica está diretamente relacionada com a rapidez de intervenção das autoridades responsáveis.

Por essa razão, o artigo 35.º da Convenção de Budapeste prevê a obrigação de cada parte signatária designar um ponto de contato disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que será o responsável por atender de maneira imediata pedidos de assistência a investigações ou procedimentos referentes a infrações penais relacionadas com dados ou sistemas informáticos, ou a fim de recolher provas, sob a forma eletrônica, de uma infração penal.

Esse ponto de contato visa facilitar e agilizar a prestação de aconselhamento técnico, a conservação de dados e a recolha de provas, informações de caráter jurídico e localização de suspeitos.

i) *Capacitação e aprimoramento* – Ao aderir à Convenção do Cibercrime, o Brasil passa a ter direito a receber assessoria oferecida pelo *Cybercrime Programme Office* (C-PROC)³⁸, órgão do Conselho da Europa responsável por prestar assistência aos países signatários da Convenção no fortalecimento de seus sistemas judiciais para responder aos desafios impostos pela cibercriminalidade e pela coleta de evidências eletrônicas. Dentre as atividades de assessoria oferecidas, destacam-se a possibilidade de treinamento de juízes, promotores e agentes da lei, o auxílio no estabelecimento de unidades forenses especializadas em cibercrime e suporte no fortalecimento da legislação sobre crimes cibernéticos e evidências eletrônicas, em conformidade com o estado de direito e os padrões de direitos humanos (incluindo a proteção de dados pessoais).

j) *Proteção de Direitos Autorais* – O artigo 10.º da Convenção de Budapeste determina que os países signatários devem adotar medidas legislativas para estabelecer como infrações penais no seu ordenamento jurídico interno a violação do direito de autor e do direito conexo, em conformidade com as obrigações estabelecidas pela Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, pela Convenção Universal sobre o Direito de Autor, pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao

³⁸ Conselho da Europa, “Cybercrime Programme Office (C-PROC)”, disponível em <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/cybercrime-office-c-proc->, consultado em 20 de dezembro de 2020.

Comércio (Acordo TRIPS), pelo Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre o Direito de Autor e pelo Tratado da OMPI sobre Interpretações, Execuções e Fonogramas.

Entretanto, até o momento, o Brasil não aderiu aos dois últimos Tratados da OMPI, de 1996, que tratam especificamente da proteção de medidas tecnológicas adotadas para a proteção de obras intelectuais em formato digital, não estando, portanto, obrigado a legislar sobre as proteções estabelecidas por estes acordos internacionais.

Dessa maneira, a adesão brasileira à Convenção do Cibercrime pode permitir um aperfeiçoamento da legislação nacional de proteção de direitos do autor e direitos conexos, mesmo sem a adesão formal aos referidos Tratados da OMPI.

1) *Proteção de Dados* – Com a promulgação recente da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, que instituiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) do Brasil, em grande medida um reflexo do Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia, a adesão brasileira à Convenção do Cibercrime representará a introdução completa do país no cenário mundial da era digital, garantindo assim que as transações comerciais e financeiras sejam realizadas em conformidade com o padrão internacional de segurança estabelecido pela Convenção e permitindo, assim, um melhor combate aos delitos cometidos por meio de sistemas informáticos.

4. Conclusão

Assim como o desenvolvimento de novas tecnologias avança de maneira colaborativa, a melhor abordagem para enfrentar a criminalidade informática transfronteiriça é por meio da elaboração de regras jurídicas que forneçam um ambiente de cooperação internacional entre os países, tanto para a investigação quanto para o processamento, o julgamento e a imposição de sanções aos ciber-criminosos.

Enquanto cada nação focar seus esforços em legislações com aplicação apenas dentro de suas fronteiras, haverá um ambiente propício para o aumento dos crimes cometidos por meio de sistemas informáticos, em especial daqueles em que a execução do crime ocorre em um país e o resultado se manifesta em outro, ou em que sequer é possível identificar, de maneira apropriada, a localização do agente criminoso.

Ainda, em razão da complexidade da temática, que envolve conhecimentos específicos de áreas tecnológicas que avançam em velocidade crescente, faz-se necessária a colaboração de todas as partes interessadas para que se desenvolva um arcabouço normativo capaz de oferecer as respostas desejadas

pela sociedade, no intuito de garantir a segurança – tanto jurídica quanto fática – esperada por todos.

A Convenção de Budapeste sobre o Cibercrime foi elaborada em um contexto de aumento exponencial dos crimes informáticos e buscou oferecer condições para que todos os países signatários pudessem enfrentar os criminosos virtuais de maneira rápida e eficaz, incentivando a colaboração de todos os países no processo de investigação e o compartilhamento de evidências digitais que possam levar os agentes criminosos a responder adequadamente pelos danos causados por suas condutas, independentemente do local onde se encontrem fisicamente.

Ao juntar-se ao grupo de países que já aderiram à Convenção do Cibercrime, o Brasil pode se beneficiar das diversas previsões normativas constantes desse documento, buscando assim suprir as lacunas da sua legislação interna que, apesar dos avanços recentes, ainda não oferece plenas condições às autoridades para combater da melhor maneira possível os crimes cometidos no ambiente cibernético, em especial no que refere à obtenção de provas eletrônicas armazenadas em sistemas informáticos estrangeiros.

A adesão à Convenção não resolverá todos os problemas do ordenamento jurídico brasileiro, que ainda demandará dos seus legisladores um considerável esforço na edição e aprovação de leis que internalizem as previsões da Convenção, mas pode servir de incentivo para levar o Brasil a um nível mais elevado de segurança digital.

Referências bibliográficas

Brenner, S. W., *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes* (Northeastern University Press, 2012).

Buil-Gil, D., Miró-Llinares, F., Moneva, A., Kemp, S. e Díaz-Castaño, N., “Cybercrime and shifts in opportunities during COVID-19: a preliminary analysis in the UK” (2021), *European Societies* 23.

Comissão Europeia, “Towards a general policy on the fight against cybercrime” (2007), *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Committee of the Regions* COM(2007) 267 final.

Conselho da Europa, “Chart of signatures and ratifications of Treaty 185”, disponível em https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=XOPFsmcb, consultado em 20 de dezembro de 2020.

_____, “Convention on Cybercrime”, disponível em: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561>, consultado em 20 de dezembro de 2020.

_____, “Cybercrime Programme Office (C-PROC)”, disponível em: <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/cybercrime-office-c-proc->, consultado em 20 de dezembro de 2020.

_____, “Minuta do Relatório Explicativo”, disponível em: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=-09000016802fa429>, consultado em 27 de dezembro de 2020.

Costa, J. F. e Moniz, H., “Algumas reflexões sobre a criminalidade informática em Portugal” (1997), *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* LXXIII: 73, 297-345.

Hill, J. B. e Marion, N. E., *Introduction to Cybercrime: Computer Crimes, Laws, and Policing in the 21st Century* (Praeger Security International, 2016).

Holt, T. J., Bossler, A. M., Seigfried-Spellar, K. C., *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction* (Routledge, 2015).

International Telecommunication Union (ITU), “Percentage of individuals using the Internet”, disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Individuals_Internet_2000-2018_Dec2019.xls, consultado em 24 de dezembro de 2020.

Neto, A. S., *Cibercrime e Cooperação Penal Internacional: Um Enfoque à Luz da Convenção de Budapeste* (Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas – Universidade Federal da Paraíba, Faculdade de Direito, João Pessoa, Paraíba, 2009).

Nunes, D. R., *Os Meios de Obtenção de Prova Previstos na Lei do Cibercrime* (Gestlegal, 2018).

Oerlemans, J. J., *Investigating Cybercrime* (Tese de doutoramento – Universiteit Leiden, 2017).

Silva, A. V., “Criminalidade por computador, na R.F.A” (1985), *Scientia Iuridica* XXXIV: 197/198.

Veloza, J. A. e Rocha, M. A., “Criminalidade informática: modos de execução” (1986), *Scientia Iuridica* XXXV: 199/204, 173-209.

Venâncio, P. D., *Lei do Cibercrime: Anotada e Comentada* (Coimbra Editora, 2011).

Wall, D. S., *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, Crime and Society Series* (Polity Press, 2007).

Zavrsnik, A., “Cybercrime definitional challenges and criminological particularities” (2008), *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 2(2).

REENTRY, HUMAN RIGHTS, AND SUBJECTIVITIES: DESCRIPTIVE APPROACH TO THE APAC METHOD

Marco Ribeiro Henriques

NOVA School of Law

marcoribeirohenriques@gmail.com

Abstract: The chapter focuses on the importance of guaranteeing human rights and maintaining family contexts in people's resocialization deprived of their liberty. In this context, the analysis considers the legal significance of the effectiveness of rules aimed at protecting prisoners and, as social relevance, the guarantee of constitutional principles and the maintenance of family contexts as a means of resocialization. The overall objective of the research is to uncover the human rights violations in the prison system and their impacts on inmates in the light of the literature and from a human rights perspective, as well as to describe the methodology of the Association for the Protection and Assistance of Convicted Persons (APAC). The methodological framework is exploratory research, through a bibliographic survey, of a qualitative nature. In the theoretical framework, the foundations and purpose of custodial sentences were addressed, the challenges for the maintenance of human rights and family contexts in the resocialization of prisoners, the prison system's inefficiency, and a possible alternative to the current model. The results of the investigation were mainly axiomatic, with constant violations of human rights. The suffering of families who end up being hit by the sentence of their family member who was arrested was also noted. There was also the difficulty of resocialization after the conviction. Finally, it is concluded that the APAC method, through the restorative bias, can be an alternative for the prison system.

Keywords: Punishment – Resocialization – Human Rights – APAC – Crime.

Introduction

This chapter seeks to make an analysis of the resocialization model proposed by the Association for Protection and Assistance to the Convicted (APAC) as a possible alternative to the prison system in the light of human rights, maintenance of family contexts, and socialization of those who have had their freedom curtailed.

In the context of the demographic increase in the prison system, denunciations of violations of rights, and inefficient projects of resocialization and socialization, this chapter's focus is to show the importance of guaranteeing human rights within the prison system, explaining the consequences of their non-respect. It sought to address the influence of the family's presence in the resocialization of the person deprived of his/her liberty and how it contributes to the reduction of stigma towards the person who has been deprived of his/her freedom. It also sought to show the reverse effect of sentencing, which, instead of socializing, marginalizes the condemned and how this can influence their lives after the prison experience. However, it did not seek to address the functioning of APAC, limiting the analysis of intervention method in the process of resocialization of the agent who is proposed.

The particular legal, social, and human rights importance of this issue, based precisely on the effectiveness of standards aimed at minimum fundamental guarantees for persons deprived of their liberty, is stressed. In most countries, the prison model in force has nature whose borders often diverge from the framework of warranties of what is considered the minimum for maintaining the human person's dignity. In the face of this hypothetical unconstitutionality, there is nevertheless a model of imprisonment that seeks to precisely implement those norms that guarantee the minimum existential necessary for maintaining the human condition.

Conventional prisons create unfavorable environments and confirm the idea that "the good bandit, it is the dead bandit" and not integrated who commits crimes and has even less chance of coming out of vulnerabilities and criminalities¹. Thus, a prison model capable of offering all the minimum guarantees is essential for any democratic state of law that values the human being's dignity.

This analysis's relevance is to guarantee constitutional principles before citizens so that marginalized people can be reintegrated into society.

¹ M. Soares, *Cidadania e Direitos Humanos* (GOV, 1994).

Furthermore, as social relevance, APAC is analyzed as a paradigm capable of fulfilling this purpose, of guaranteeing human rights, as well as (re)establishing family ties to recover the person who has been marginalized to reintegrate him/her into society, that is, resocialize him/her.

This chapter's general objective is to analyze and identify the primary means of guaranteeing human rights that can involve prisoners' resocialization, providing them with intense family participation and a consequent reduction in their return to prison. As the APAC method suggests to us as a paradigm that can virtually guarantee the applicability of legislation, particularly the Constitution and international treaties, and, above all, ensure that Human Beings are treated as Human Beings, whether they are in a situation of freedom or imprisonment.

This method is not applied in Portugal, nor is there legislation that can regulate a similar situation. APAC has existed only in Brazil since 1972 and brings results mainly to reduce recidivism, resocialization, and the maintenance of family ties. Providing integration, developing work, and encouraging a differentiated methodology, preserving principles and disciplinary routines, APAC has demonstrated, since the 1970s, a potential socio-educational and decision-making project for "reclaimers". In this sense, to make possible means of education, promotion of rights, and guarantees to inmates, this chapter aims to demonstrate and deepen some possible means of resocialization and integration.

The choice of the methodology used was based on the bibliographic and exploratory survey through Scielo platforms, etc., as well as the use, analysis, and study of legislation, decrees, international pacts, jurisprudence, among others, in addition to searching for materials already published such as articles, dissertations, internet sites, and indexers such as IBICT, Google Academic and BDTD.

The methodological approach used is qualitative, seeking to analyze the social phenomenon studied describing the basis of this social dynamic and what should be done about it, developed through interpretations of aspects of reality such as, for example, human rights violations, the breakdown of family contexts, among other subjective issues that will be concluded at the end of the chapter.

1. Prison sentence, rights and guarantees under the Rule of Law

The origin of punishments and the right to punish came from the constant fear of finding enemies anywhere. This uncertainty made people decide to sacrifice some of their freedom to enjoy the rest in safety. From this comes the

right to punish legitimized by the gathering of all the small parcels of freedom, bringing the sentences as the deposit of public salvation².

In this context, according to Franz Von Liszt, the sentence can be divided into three moments, the moment of the sentence in the abstract, the actual sentence, and the sentence in execution. The purpose of the sentence at each of these moments is different. According to this author, the first moment is the abstract sentence, which is general prevention aimed at society since it seeks to act before the crime is committed. The second moment is the substantial penalty, and its application has two purposes: the first is the special negative prevention aimed at the offender trying to prevent him from committing crimes again (recidivism), and the second is the retribution of the evil with the evil caused³.

Finally, the third is criminal execution. Von Liszt explains that the sentence's execution has two purposes: that of making the provisions of the sentence effective and the special positive prevention, which is the resocialization of the individual so that the (re)educational character is of the utmost importance.

In short, it is possible to conclude that the sentence in execution is aimed at the offender, to resocialize him. On the other hand, according to Figueiredo Dias, the penalty is justified "as a mechanism [...] of intervention in social conflicts, with a view to the solution presented by the State, the sole and exclusive holder of the right to punish (*ius puniendi*)"⁴. Therefore, the penalty is only a form of resolving social conflicts, which is to repress and prevent it from happening again, so and can achieve this purpose through the effective reintegration of the person into society.

Thus, it is concluded that the prison sentence is a punitive instrument of the State which aims at the resocialization of the offender. This social reintegration is ensured by special laws for the enforcement of penalties so that in the enforcement phase, the sentence must fulfill its role of resocializing the individual.

Nevertheless, Aury Lopes explains that the entitlement to a State penalty arises when private revenge is suppressed. Criteria of justice are established, stressing that respect for fundamental guarantees should not be confused with impunity since the offense's repression⁵. The concern for guarantees is simultaneous and coexistent in a State of law.

Mário Monte concludes that the dependence between the harmonious coexistence of the members of a society and the punitive power of the State has

² C. Beccaria, *Dos Delitos e das Penas* (Martin Claret, 2017).

³ F. Von Liszt, *Tratado de Direito Penal* (Russell, 2003).

⁴ J. Dias, *Direito Penal Parte Geral – Questões Fundamentais da Doutrina Geral do Crime* (Gestlegal, 2019).

⁵ A. Lopes, *Direito Processual Penal* (Saraiva, 2017).

already been proven and that this is a necessary form of social control; however, such authority cannot be unmeasured, in a way that directly compromises the fundamental rights of the human person⁶.

On the other hand, Beccaria argued that society has always called for justice, and the fear of violence has led the community to sacrifice freedom in the name of security and thus legitimized the State's power to punish⁷. This legitimacy has become so consistent that Sanches already claims to be an unwavering social control⁸.

However, the *ius puniendi* of the State arises precisely from the suppression of private vengeance in the search for justice. Hence, there must be active participation by society so as not to let this impetus for punishment be placed above fundamental guarantees, since they are umbilically interconnected, functioning as "counterweights," insofar as one relativizes the other in the name of legal and social security to ensure the harmonious coexistence of the members of a society and the punitive power of the State.

It should be remembered that international instruments such as the United Nations Standard Minimum Rules of Penitentiary Treatment or the Pact of San José of Costa Rica provide for a set of provisions on the right to personal integrity of prisoners, *in litteris*, "no one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Every person deprived of his liberty must be treated with the respect due to the inherent dignity of the human being" to which the signatory States are subject to comply with their internal regulations.

The assertion of human rights in covenants, treaties, conventions, among others, aims precisely to guarantee the minimum dignity of people who have their rights violated. However, it is possible to ask whether the normalization of such rights is useful or whether they end up hindering their guarantee because there is an enormous stigma surrounding the defense of human rights, which has become associated with the "defense of criminals defense"⁹. The spread of this idea eventually alienated society in general from the struggle for human rights.

⁶ M. Monte, *O Direito Penal Europeu – De "Roma" a "Lisboa" – Subsídios para a sua Legitimação* (Quid Juris, 2009).

⁷ C. Beccaria, *supra* n. 2.

⁸ R. Sanches, *Manual de Direito Penal* (JusPODIVM, 2014).

⁹ B. Santos, "Human Rights: A Fragile Hegemony", in *Human Rights and Diverse Societies: Challenges and Possibilities* (Cambridge, 2013) 17-25, available on: <https://www.cambridgescholars.com/download/sample/59089>.

The dignity of the human person is a moral value that has been incorporated into the theory of fundamental rights and is now even recognized as a legal principle. This principle has three minimum contents: the intrinsic value of the human person (fundamental rights such as the right to life, physical and psychological integrity), the autonomy of the will (ethical element associated with the self-determination of the individual), and the community value (the social part that identifies the relationship between the individual and the group). Above the provisions observed, it is possible to see that constitutional principles are not absolute since they can be relativized in favor of maintaining another constitutional principle, such as imprisonment. A person who commits a crime has his freedom curtailed by the *ius puniendi* of the State depending on society's security.

Still, Beccaria stated that there is a limit to punitive power. There are minimum guarantees that must be respected. It is not in the State's willingness to punish unlimitedly because the penalty must always respect existential limits, precisely the principle of human dignity¹⁰.

On the other side of Retributive Justice is Restorative Justice. Restorative justice is an ordered and systemic set of principles, methods, techniques, and activities of its own, aimed at raising awareness about the relational, institutional and social factors that motivate conflicts and violence, and through which disputes that generate harm, concrete or abstract, are resolved in a structured manner.

This instrument's central object is not guilt but the correction of errors, involving the victim, the offender, and the community in a search for solutions to promote reparation, reconciliation, and security. Thus, in the words of Marcos Rolim, what matters for Restorative Justice is precisely to repair the social relationship that was broken, returning to the status quo, which denotes the idea of community participation for the "cure" of the criminal¹¹. The restorative system is better adapted to the general principles of criminal law, including the principle of minimum intervention. Criminal justice should act in a subsidiary way, when strictly necessary, i.e., the criminal sphere should be the other spheres' last *ratio*.

Therefore, after understanding that Retributive Justice ends up excluding the person and, even worse, stigmatizing him or her, it is essential to emphasize the importance of reflecting on the implementation of a model of Restorative Justice, since this system has as its central value the participation of the people involved in the conflict, to show "offenders" that their actions have a direct impact on society, seeking to bring a sense of responsibility for their acts, as well

¹⁰ C. Beccaria, *supra* n. 2.

¹¹ M. Rolim, "Justiça Restaurativa: para além da punição", in *A Síndrome da Rainha Vermelha: Policiamento e Segurança Pública no Século XXI* (Zahar, 2006).

as to involve the victim, the offender, and the community to restore the status quo because, as Howard Zehr states, the central objective of restorative justice is precisely the correction of errors¹².

Now, if in the current model of retributive justice, where guilt is more important than the correction of errors, crime is on the increase and, as a consequence, the rates of resocialization are lower and lower, this means that the current prison system is not functioning, that is, it is not fulfilling its purpose of resocialization. Thus, it is clear that there is a need to change this current model, leaving aside the bias of returning the evil as the evil caused and beginning to correct the mistakes of those who committed illegal acts through a refreshing look at the penalty.

2. (Re)socialization of incarcerated persons: challenges to the maintenance of human rights for convicted persons and their families

The core and *raison d'être* of the word resocialization is the human person's dignity whose goal is the person's social reinsertion, with the active participation of society being of extreme importance for this goal to be achieved in this diapason, if penitentiaries do not respect the fundamental principle of human dignity, they are destined to be ineffective. Without embargos, what is observed in today's penal system is the submission of the sentenced person to a process of depersonalization, dehumanization, and de-socialization¹³.

When a person is arrested, he or she enters an alienating universe, or rather, is inserted into a reality in which all relationships are deformed, in which apart from the deprivation of his or her freedom, he or she is removed from affective and family bonds.

Sociability can be understood as a pure form of human interactions so that only through it is it possible to make society viable, since human relations, the exchange between people, is their form of sustenance¹⁴.

According to Hannah Arendt, "men have conditioned beings because everything they come into contact with immediately becomes a condition of

¹² H. Zehr, *Trocando as Lentes – Um Novo Foco sobre o Crime e a Justiça* (trad. Tônia VanAcker. Palas Athena, 2008).

¹³ A. Prado & M. Silva, "A adoção de ações afirmativas para a população prisional e egressos: Uma via para contenção dos efeitos negativos do encarceramento" (2016), *Revista de Criminologias e Políticas Criminais* v. 2, n. 2, 56-76.

¹⁴ J. F. McDonough, "Prática Política: A face Negligenciada da Intervenção em Serviço Social", in J. F. Mc Donough, M. A. Negreiros, A. Martins & A. Henriquez (dirs.), *Serviço Social, Profissão e Identidade, Que trajetória* (Vozes, 2011), 99-123.

their existence”¹⁵. This means that a person exposed to a violent environment will be more conducive to aggression, just as a peaceful context, beneficial to human relations (socialization), will facilitate social reintegration. With this, one realizes that it is essential to analyze how the individual is inserted because several factors can shape him/her. Thus, the need for the community’s active participation in the process of resocialization of the one who has been withdrawn from society becomes evident to condition them to the return of social relations.

Howard Zehr already said that “the whole prison environment is structured with the aim of dehumanizing. Prisoners are given a number, sometimes a uniform, little or no space”¹⁶. Those who are deprived of their freedom are frequently discriminated against by society and are subject to punishment by its components and are also treated as an abstraction through stereotypes. Therefore, the dehumanization that occurs within the prison system constitutes indirect violence to the imprisoned person because, because it is a dynamic process, the one who has been violated ends up becoming violent, mainly because of the interiorized vulnerability. Thus, it can be said that dehumanization fosters violence, and therefore the rates of recidivism are increasingly high.

In the light of the above, it can be concluded that there is little or no interest on the part of the State and society to change the current prison situation, and this is due to the whole process of stigmatization, marginalization, and dehumanization concerning the imprisoned person. This is why maintaining human rights, especially the physical and moral integrity of prisoners, in a hazardous environment with overcrowded, dirty, and unhealthy cells, without drinking water and primary hygienic products, as well as various types of violence, both by inmates and by state agents, among other situations becomes so difficult. From this reality, in line with the thinking of Ferrajoli, the maintenance of human rights becomes a challenge since it is always relativized in the name of security¹⁷.

However, a summary should be made, making it clear that this relativization could never happen, because human rights are universal and natural, that is, they must be guaranteed everywhere in the world as well, since they derive from the human person, from the dignity of his nature, and therefore they do not need laws for their promotion and even less recognition.

Given this, according to Ferrajoli, human rights are fundamental rights because they correspond universally to all human beings and do not need to be asserted to be guaranteed¹⁸.

¹⁵ H. Arendt, *A Condição Humana* (Forense Universitária, 2014).

¹⁶ H. Zehr, *supra* n. 12.

¹⁷ L. Ferrajoli, *Derechos y Garantías. La Ley del Más Débil* (Trotta, 2004).

¹⁸ *Idem, ibidem*.

According to Boaventura de Sousa Santos¹⁹, the vast majority of the world's population is not subject to human rights, but only to human rights. In this sense, is critical reflection necessary if these rights are effective for people who are excluded or discriminated against and who are in prison environments? Would a hegemony of human rights discourses be based on a hypothetical and unsecured human dignity language that legitimizes and consolidates prisoners' oppression?

In addition to the precarious conditions in which prisoners are subjected to being deprived of their liberty, there are the violations that are carried out directly on the individual, among them cruel, inhuman or degrading treatment and torture, because, as Eric Hilgendorf & Brian Valerius rightly said, "in many places, prisoners are tortured as a form of 'informal' state vengeance," as well as preventive prisoners are often tortured into confessing crimes they have never committed²⁰. The consequence of all these violations is precisely revolt.

The whole social environment is geared towards treating people trapped as beings apart from society, forgetting that they are more than numbers. They are human beings who possess, like any other, all the rights inherent to a citizen/an, because what is deprived is only freedom and not the other privileges.

In the words of Eric Hilgendorf & Brian Valerius, "if the crime is sickness, punishment, a cure, and imprisonment, the hospital, one must take care of the place where the patients are admitted so that their sickness does not get worse, and even if they die." In line with this idea, it is clear that care, or rather, the guarantee of human rights, both for prisoners and for the prison environment itself, is paramount, so that the individual deprived of his or her liberty does not return to delinquency, and that an analogy should be made with the purpose for which the sentence should be served, concerning the resocialized role of serving the custodial sentence,

Family contexts are as difficult to sustain in the prison environment as human rights, and both are of paramount importance for the resocialization of the individual deprived of liberty.

According to Von Liszt the fundamental foundation for the prisoner's return to social life is the family²¹. In short, it is possible to say that this is the relationship of persons linked by inbred, affective or affinity ties having relevance in the life of any citizen, especially one who has restricted freedom, because it is an opportunity for socialization among individuals, and can even function as a "link between the subject and society".

¹⁹ B. Santos, *supra* n. 9.

²⁰ E. Hilgendorf & B. Valerius, *Direito Penal – Parte Geral* (Marcial Pons, 2019).

²¹ F. Von Liszt, *supra* n. 3.

When the subject-society link is broken, it becomes more challenging to return to social coexistence, since socialization, in the words of Maria Dias can be understood as the preparation of individuals to become or return to be an integral part of social systems²².

As a result, imprisonment in addition to depriving the individual of his or her freedom ends up contributing to the disruption of family contexts, caused by the tension of the prison environment because of the embarrassing magazines, as well as social difficulties due to prejudice.

In this way, the prison system, instead of correcting the conditions of exclusion of the prisoner concerning family and society, a factor that has the consequence of containing criminal recidivism, secondary marginalization, and the return to prison ends up taking him further away from social coexistence.

Moreover, this prejudice and stigma imposed on the individual deprived of their liberty even come about when there is resocialization, which shows society's disbelief towards the recovery of those imprisoned. It is already known that conventional prisons are "schools of crime," that the prison system does not fulfill its purpose, so society's view is that those who leave are supposed to be not yet fit for social coexistence, thus creating a stigma around the convicted person, reaching even their family. Then, those who manage to overthrow the traditional prison system by resocializing end up also being affected by prejudice, which, as a consequence, may lead to their withdrawal from social coexistence and return to the world of crime.

Therefore, it is possible to see that the prison system does not guarantee the fundamental rights inherent in the human person. However, for there to be effective resocialization, the family's presence is necessary since this is the link that links the subject to society. It will also be essential to guarantee all the minimum existential rights of those who have already been deprived of one of their greatest legal assets, which is freedom.

3. The Association of Protection and Assistance to the Condemned (APAC): Emergence, applicability, and effectiveness of the APAC method

Once the failure of the prison system has been analyzed, which has been brought about by various factors that have already been explained at length, in particular constant violations of human rights, overcrowding in prisons, and the breakdown of family ties, it is crucial to focus on alternative means that can reduce or even solve some of the problems already identified in the current pris-

²² M. Dias, *Manual de Direito das Famílias* (Revista dos Tribunais, 2017).

on system. One possible alternative methods of intervention in the prison system are the Association for the Protection and Assistance of Convicted Persons (APAC).

It should be noted that, as it is a paradigmatic alternative, it is a new view of the object under study, not requiring a solution to all the problems, but at least to remedy those considered most urgent and to indicate new guidelines to be followed.

This association is a civil, non-profit organization whose purpose is to recover and reintegrate the condemned into society by serving custodial sentences, in addition to supporting the victim and protecting the community. It works basically as an auxiliary entity of the Judiciary to act in prisons, using the fundamental principles of human rights to achieve its objective of humanization and guarantee of the most basic fundamental rights of prisons.

The first APAC was born in São José dos Campos (SP) in 1972 by Mário Ottoboni, a pioneering pioneer. In 1972, in São José dos Campos (SP), something entirely new, unusual, and revolutionary began in the prison system. In 1974 a leap was made by the group that, under the guidance of the Judge of Criminal Execution of the District, decided for the creation of a civil association destined to the service of an auxiliary organ of justice, acting specifically in tasks of criminal execution, being born, then, the Association of Protection and Assistance to the Convict – APAC.

It is currently considered a model of efficiency in the face of a custodial sentence since it is based on the principles of restorative justice and the objective of returning it to society. In 1974, an experiment was started at APAC in São José dos Campos with the prisoners of Presídio Humaitá that involved three fronts: “the volunteers of the Association, the families of the prisoners and the direction composed of technical organs”, so that the volunteers were divided into groups of sponsors for the accompaniment of each inmate, the families with the stimulus to maintain contact to avoid the rupture of the family units and the direction with the role of seeking to understand the reasons that led to the practice of the crimes to prevent them. The group of sponsors has an essential part since it aims to recompose family members who are often blurred and negative.

According to Maria Peres for the condemned to be reintegrated into the different contexts (family and social sphere), and for criminal recidivism, stigmatization as a subject and secondary marginalization to be avoided, there must be a correction of conditions that end up socially excluding the individual²³. These conditions are precisely the guarantees of human rights, fundamental

²³ M. Peres, “O anacronismo penitenciário”, in M. Coelho & M. Filho (orgs.), *Prisões Numa Abordagem Interdisciplinar* (Edufba, 2015).

rights that all citizens must possess regardless of whether they are in prison or full enjoyment of their freedom.

According to Francisco Sobrinho some of the APAC method's central elements are work, community participation, human valorization, and the family. They all have legal backing as rights that must be guaranteed within the prison system since each has its role in the process of resocialization. In this sense, it is essential to explain the objectives of each of these elements²⁴.

First of all, the work aims to improve the inmate's professional training so that they are prepared for the labor market. It is worth noting that society's participation as a means of the inclusion of the condemned is paramount, avoiding the orbiting of any stigmatization of "ex-convict." Another element is social valorization, awakened through values such as solidarity, compassion, and affection. This occurs by identifying each by his name, no numbers or nicknames, to restore his identity. Among the central elements cited for this text is the family as the basis for the possibility of recovery and social inclusion of the condemned. The method wants to prevent the penalty from exceeding the accused and reaching his family. The family bond stands out as one of the essential factors for resocialization, but it often breaks up during the prison term. The current prison system is considered a tense environment, with embarrassing magazines, and in addition to these factors that end up driving the family away, it is still affected by prejudice, which surpasses the convict's person. For this reason, APAC seeks to stimulate closeness between prisoners and their families, to avoid that the effects of the penalty also reach them, even if indirectly. This (re)approach takes place with families' participation in the activities developed by the institution.

The central objective is to place the family as a co-responsible process of resocialization of the recovering, clarify some issues, and help and encourage the relatives to prepare themselves to deal with the problems of the inmate. One of the requirements for a prisoner to be transferred to an APAC is precise that he or his family have a residence in the institution's vicinity.

The family and the recovering family view the activities positively provided by APAC, contributing both to understanding the situation the imprisoned relative is going through and the increase of dialogue and patience with it. The participation of the family in the process of socialization is of significant importance, especially for prisoners. At APAC Viçosa, when asked about the advantages of being part of this institution, the trainees talked about the opportunity to work, to be able to see their family and to feel more supported. By making a brief comparison with maintaining family contexts in the institutions and the Prison System, it is apparent that the people there excluded from APAC have identified

²⁴ F. Sobrinho, *APAC, Redenção (ou Alternativa) para a Execução Penal* (2010) available on: <https://jus.com.br/artigos/59712/apac-redencao-ou-alternativa-para-a-execucao-penal-1>.

more positive changes about the relationship with their family members than negative ones.

Already in prison, most of the changes identified were negative. All respondents reported that there were procedures during the review of their relatives that were embarrassing, which contributed to removing the family.

In the closed regime, the work is called labor occupation, and since it is manual work for fabric making, carpentry, and assembly of parts; however, foreign trade is not allowed. This manual work aims to show when recovering that the same hands used to commit a crime can be used to produce something.

In the semi-open regime, which is subdivided into two phases, there is remuneration for the work, being that in the first phase is made in the own existing APAC workshops, while in the second phase recovering it can ask for an authorization to work outside, only returned at night and on weekends to sleep.

Finally, in the open regime, everyone has to work outside the institution, depending essentially on the local community's relationship with APAC.

It is worth mentioning that the rescuers, who were fulfilling an open regime at APAC Viçosa when questioned about the effectiveness of the resocialization activities, responded positively both to their return and the opportunity to become professional while serving their sentences.

The APAC has as one of its core values the valorization of the human being. All its method is built in this sense, to recover the human being behind the criminal stigma.

The method aims to awaken individual values that have been lost over time, among them solidarity, compassion, and affection, showing that its basis is in love with others and with oneself. Furthermore, identifying each one by their name is an essential factor in building trust and self-esteem.

Human valorization is essential for the inmates because, according to Francisco Sobrinho recovering from APAC, which served time in the closed regime, the self-esteem in the standard prison system is zero²⁵. Still, in the institutions, with the classes of human valorization, which are obligatory, they end up stimulating their self-esteem and the love for their neighbor and how they should behave when they return to society.

Moreover, the method guarantees social inclusion through access to education, cultural activities, health, among others. It should be noted that the APAC method is based on discipline, which is very rigid because, for the system to work, students must have the responsibility that comes from obedience to the rules.

²⁵ *Idem, ibidem.*

However, even with all rigidity, “benefits” are granted to those who deserve it. It is not the only discipline that is a priority but also trusts revealed that it is the retrievers themselves who take care of the keys that give access to the cells, the access and exit gates, or any other space in the institution.

Another pillar is community participation, which contributes to reducing stigma towards the inmate and the restructuring of social ties, as these are factors that provide for the recovery and consequent resocialization of the convict. Volunteer groups are fundamental in helping to bring the condemned back into society because they are people in the community who are willing to help them or often also the very ones who volunteer to help after their sentences have been served, which is what is called “recovering by helping by recovering” to teach them how-to live-in society.

Therefore, it is clear that this model aims to humanize the prison environment, ensuring the dignity of the prisoner, as well as facilitating access to families and to the community itself, favoring social relations and, consequently, resocialization.

Conclusion

This chapter aims to highlight the results that have been achieved during this research. First, it is essential to emphasize three essential aspects to possible resocialization: guaranteeing human rights, (re)structuring family ties, and work. These three factors have positive results when put into practice. The principle of the human person’s dignity within the prison system was initially pushed into the background. Erroneously, this principle, which is a fundamental right inherent to the human being, has come to be treated as a benefit as the effectiveness of the clamor for justice, in such a way that society cannot accept the idea of seeing a person arrested at work or even visiting their family, since they have come to see these rights as synonymous with impunity and not with serving a sentence.

Consequently, the bias of reintegrating a condemned person into society becomes more and more distant because of punitive thinking and an insatiable search for justice, no matter the means, only the end to reach it. In this way, it can be seen that the feeling of impunity always prevails when there is treatment worthy of those who have had their freedom curtailed. Human rights must be guaranteed to those who are imprisoned, both in the broadest sense and in the strictest sense, because there is no way to cage a human being and treat him like an irrational animal for years, violating all his rights and dignity, and to expect that when he comes out of prison, without any foundation, including the family, he will return as a citizen better suited to social coexistence. Only through the humanization of prisons and the observance of the basic principles of rights

are possible to achieve effective resocialization results. At present, the prison sentence is passed over the person of the convict, as far as the relatives of the prisoners are concerned, thus violating the “principle of the personality of the sentence,” since to visit them they end up going through various embarrassing situations, in addition to the prejudice they suffer in the social sphere. This being a reality perceived by the condemned themselves. Often these constraints and prejudices end up taking the family away from the one who is in prison, and as a consequence, the break-up of family ties. However, it should be noted that the family also plays a crucial role in resocialization, so it is necessary to maintain family ties so that the recovered can have a safe harbor as a source of support and encourage them to change their lives. This is because the family is one of society’s foundations and is the first link that the subject has with the community of which he or she is a part. As far as work is concerned, it is noticeable that post-prison life becomes difficult because of all the stigma surrounding the prisoner. This prejudice affects mainly the search for a job since nobody wants to hire an “ex-convict,” and even if someone is willing, in the current prison model, the inmates are idle while serving their sentence, remaining without work experience. The difficulty prisoners have in getting to work is a harmful factor for resocialization, since in most cases, the “ex-convicts” have a family to support, and the lack of employment ends up taking them back to the world of crime.

For this reason, too, social reintegration becomes unviable. The participation of society in the process of resocialization of persons deprived of their liberty is of significant importance, as it not only breaks with the stigmatization of prisoners and increases the fight to guarantee their rights. However, as is well known, the feeling of vengeance that hangs over society prevents it from seeing that those sentenced have rights that must be respected since the custodial sentence is limited to freedom alone. Thus, the guarantee of human rights becomes difficult in societies that are not based on solidarity since these are universal rights that concern everyone and not just “bandits,” as common-sense dictates. Given the factors mentioned, which are considered essential for resocialization to be possible, the APAC’s propose a practice in which the guarantees provided for international laws and treaties are affected. Through the low rates of recidivism, the APAC model can prove that resocialization is not a utopia but a reality. The differential in the APAC method is precisely the observance of the principle of law and that the secret of its philosophy follows the noble element of love, from which it stands out in solidarity, all in favor of the dignity of the human person, the primary foundation of a just and democratic society.

It is concluded that the APAC method has proved to be a worthy and possible alternative to be implemented since what is required for its functioning is the guarantee of Human Rights, regardless of the crime committed. Thus,

the APAC methodology demonstrates that the prison system is not doomed to failure.

The sanction that deprives the individual of his liberty is justified from the moment that society – out of a desire for justice and fear of violence – legitimizes the State to restrict one of its most valuable assets – liberty. This is because the common sense of justice says that this can only be achieved by limiting all the rights of those who have committed crimes, but they forget that the penalty of deprivation of liberty aims only at the lack of freedom and is unconstitutional, being the proviso of any other legal good.

Over the years, it is observed that violence in the country has been growing and that the “sense of security” so longed for by society is becoming more and more distant.

In this context, the APAC method, created by Mario Ottoboni in 1972, succeeds in resocializing “bandits” only through the application of the laws sanctioned in the legal system, in the case of Brazilians, showing that it is possible to reintegrate people through the application of fundamental values such as human rights, family ties, and work.

In the words of Arendt people are conditioned to the environment they are in so that the response to punishment will be equivalent to the treatment received²⁶.

That said, one cannot treat a human being as an object and expect him to return “civilized” to the society that condemned him. Like any other approach, the APAC method is not and will be perfect, but it has positive practical results through the guarantee of Human Rights and the maintenance of family contexts.

Bibliography

Arendt, H., *A Condição Humana* (Forense Universitária, 2014).

Beccaria, C., *Dos Delitos e das Penas* (Martin Claret, 2017).

Dias, J., *Direito Penal Parte Geral – Questões Fundamentais da Doutrina Geral do Crime* (Gestlegal, 2019).

Dias, M., *Manual de Direito das Famílias* (Revista dos Tribunais, 2017).

Ferrajoli, L., *Derechos y Garantías. La Ley del Más Débil* (Trotta, 2004).

²⁶ H. Arendt, *supra* n. 15.

Hilgendorf, E. & Valerius, B., *Direito Penal – Parte Geral* (Marcial Pons, 2019).

Lopes, A., *Direito Processual Penal* (Saraiva, 2017).

McDonough, J. F., “Prática Política: A face Negligenciada da Intervenção em Serviço Social”, in J. F. Mc Donough, M. A. Negreiros, A. Martins & A. Henriquez (dirs.), *Serviço Social, Profissão e Identidade, Que trajetória* (Vozes, 2011), 99-123.

Monte, M., *O Direito Penal Europeu – De “Roma” a “Lisboa” – Subsídios para a sua Legitimação* (Quid Juris, 2009).

Peres, M., “O anacronismo penitenciário”, in M. Coelho & M. Filho (orgs.), *Prisões Numa Abordagem Interdisciplinar* (Edufba, 2015).

Prado, A. & Silva, M., “A adoção de ações afirmativas para a população prisional e egressos: Uma via para contenção dos efeitos negativos do encarceramento” (2016), *Revista de Criminologias e Políticas Criminais* v. 2, n. 2, 56-76.

Rolim, M., “Justiça Restaurativa: para além da punição”, in *A Síndrome da Rainha Vermelha: Policiamento e Segurança Pública no Século XXI* (Zahar, 2006).

Sanches, R., *Manual de Direito Penal* (JusPODIVM, 2014).

Santos, B., “Human Rights: A Fragile Hegemony”, in *Human Rights and Diverse Societies: Challenges and Possibilities* (Cambridge, 2013) 17-25, available on: <https://www.cambridgescholars.com/download/sample/59089>.

Soares, M., *Cidadania e Direitos Humanos* (GOV, 1994).

Sobrinho, F., *APAC, Redenção (ou Alternativa) para a Execução Penal* (2010) available on: <https://jus.com.br/artigos/59712/apac-redencao-ou-alternativa-para-a-execucao-penal-1>.

Von Liszt, F., *Tratado de Direito Penal* (Russell, 2003).

Zerh, H., *Trocando as Lentes – Um Novo Foco sobre o Crime e a Justiça* (trad. Tônia VanAcker. Palas Athena, 2008).

ESTADO, NÃO-ESTADO E CONTRA-ESTADO.

A(S) ARQUITECTURA(S) DA EXCLUSÃO

Pedro Jacob Morais

*Docente convidado equiparado a Professor Auxiliar na Escola de Direito da Universidade do Minho
Investigador do JusGov
pmorais@direito.uminho.pt*

O artigo segue as regras anteriores ao novo acordo ortográfico.

Resumo: O presente artigo versa sobre o ténue equilíbrio entre a violência e o *ius puniendi*, pretendendo reflectir sobre a concordância prática entre o direito/poder de punir e as liberdades individuais, concordância que imbrica no esteio ontológico de matriz antropológica dos Estados de direito em sentido material. Mais especificamente, debruça-se sobre os diversos fenómenos, compreendidos sob a designação “não-Estado” e “contra-Estado”, que ameaçam a ontologia estatal.

Palavras-chave: *Ius puniendi* – Liberdade – Direito penal – Integração – Ressocialização.

1. Vestidos de noiva

Para a jornada que agora se inicia escolhemos um funesto *locus* como ponto de partida. Um *locus* que surge simultaneamente metamorfoseado em tálamo

nupcial e em pira sacrificial, sob o pano de fundo das guerras civis da Libéria. Nestes conflitos fratricidas que opuseram diversos grupos rebeldes (nos quais se incluíam ou, melhor, eram incluídas compulsivamente crianças-soldado), surgiram com certa frequência relatos de combatentes que envergavam estranhos trajes. Guerrilheiros que usavam vestidos de noiva, longas perucas, asas de anjo, entre outros adereços cénicos¹. Semelhantes elementos de uma cenografia belicosa não foram utilizados apenas na Libéria e, enquanto mitologias², certamente se apresentam passíveis de diversas interpretações, ou não florescessem no solo fértil da polissemia.

Ainda que a questão se encontre aberta à investigação semiológica, o vestido de noiva parece conter inelutavelmente (a escolha de palavras não surge inocente) o signo da invisibilidade e, como corolário necessário, da invencibilidade. O vestido nupcial, mais propriamente o seu véu, possui o atributo de velar e de desvelar, de revelar e de ocultar, de trazer-ao-mundo e de afastar-do-mundo. O soldado que o enverga vela-se, torna-se invisível – reveste-se indignamente do horizonte, numa paráfrase de Apollinaire³ – e, nesse “não-ser-ai”, desfere os seus golpes abrigado do olhar do adversário. Indetectável pelo oponente, o soldado-noiva serve-se da invisibilidade como técnica de agressão – atinge o adversário desprevenido – e de defesa (o adversário não se afigura capaz de executar a sua estratégia por inexistência do objecto), tornando-se invisível⁴.

O presente texto não tratará da crua temática das crianças-soldado da Libéria ou de uma qualquer semiótica dos vestidos de noiva. Todavia, não deixará de versar sobre a invisibilidade, mais propriamente na sua declinação estatal. Uma invisibilidade política com claros reflexos ou metástases no direito penal. Referimo-nos ao crescente velamento ou à ausência de inscrição⁵ que surge no seio dos grandes núcleos urbanos e periurbanos que se erguem à revelia da *longa manus* do Estado.

Por toda a Europa (enquanto espaço geográfico e civilizacional, mormente na Europa continental, onde surge discernível uma certa sobreposição entre os planos geográfico e cultural [*forma mentis*]) encontramos cidades e respectivos

¹ Cfr. M. H. Moran, “Warriors or Soldiers? Masculinity and Ritual Transvestism in the Liberian Civil War”, in L. Lamphere et al., *Situated Lives: Gender and Culture in Everyday Life* (Routledge, 1997), 445; e *Liberia: The Violence of Democracy* (University of Pennsylvania Press, 2006), 24 e 41.

² Para nos servirmos do conceito semiológico de R. Barthes, *Mitologias* (Círculo de Leitores, 1987), 209 e ss.

³ Ver G. Apollinaire, *O Século das Nuvens* (Assírio & Alvim, 2007), 50 e 51.

⁴ Claro está que, no reverso da medalha, o vestido firma o pacto nupcial/matrimonial do soldado com a Morte, *fatum* que escapa ao nosso objecto de estudo.

⁵ Sobre a importância da inscrição no espaço público, ver J. Gil, *Portugal, Hoje: O Medo de Existir* (Relógio D'Água, 2004), 24 e ss.

arredores dotados de uma clara dimensão “para-estatal” ou, até mesmo, “contra-estatal”. Configuram “zonas de comunicação zero”, onde o Estado não entra, isto é, onde o *ius puniendi* se perspectiva distante e avesso ao concreto “ser” e “estar-aí”. Zonas que subsistem à revelia da unitariedade estatal, abrigando franjas populacionais urbanas e periurbanas profundamente fragmentadas, tribalizadas ou, dito de modo diverso, refractárias à *communitas*, à comunidade (*cum munus*) que garante a coesão normativa (“eu-norma-outro”) do ordenamento jurídico (*societas*).

Mais tarde voltaremos à “desobrigação” (*immunitas*) que parece pontuar a topografia urbana, explicitando os conceitos aflorados no parágrafo anterior. Todavia, para encetarmos o movimento de abaixamento do olhar correspondente à análise dos problemas locais colocados aqui e agora, apresenta-se fundamental elevar o olhar na certeza de existir uma ligação umbilical entre a dimensão local e a dimensão global da exclusão política. Destarte, centremo-nos por momentos na ingente questão da globalização enquanto conceito capaz de aclarar o problema do controlo (ou da sua perda) da violência urbana.

2. Globalização

A globalização surge frequentemente associada aos seguintes *topoi*. A saber:

- i A globalização convoca uma redução exponencial de distâncias passível de ser explicada através da gradual aproximação dos termos que compõem o binómio espaço-tempo. Assim sendo, o tempo foi perdendo paulatinamente a sua capacidade de resistência perante a extensão espacial, esbatendo, em certa medida, a relação de proporcionalidade directa entre as grandes distâncias e o tempo necessário para as percorrer. Dito por outras palavras, a globalização (principalmente no que respeita à potencialidade de locomoção humana) converteu a oposição originária que dividia o espaço e o tempo numa unidade sintética final⁶. Pelo exposto, o movimento globalizante compreende a gradual abolição das barreiras que se erguiam à circulação de pessoas, bens e serviços, contribuindo, mais do que para a criação de um *ius cosmopoliticum*⁷, para a criação de um *ius ambulandi* global. Bem observado, a mencionada “abolição de barreiras” melhor seria designada como uma “abolição de fronteiras” perante o fluxo constante de pessoas, bens e serviços;

⁶ Sobre o tempo sincrónico da globalização, ver P. Sloterdijk, *Palácio de Cristal: Para uma Teoria Filosófica da Globalização* (Relógio D'Água, 2008), 152 e ss.

⁷ Cfr. I. Kant, “Zum ewigen Frieden : Ein philosophischer Entwurf”, in W. Weischedel, *Immanuel Kant: Werke in zwölf Bänden* (Suhrkamp, 1977), 204, nota 3.

- ii Por outro lado, a toponímia globalizante evoca, não raras vezes, o “leitmotiv” do risco. Mais propriamente, coloca em evidência a sua conformação ubíqua, global e naturalmente alheia a qualquer fronteira, seja geográfica ou humana. Porém, mais do que diagnosticar a onnipresença do risco⁸ (num certo sentido, o terreno de aluvião [liquidez]⁹ da pós-modernidade), a globalização tem influenciado a doutrina, *maxime* a jurídico-penal, a reconhecer a premência da protecção de bens jurídicos colectivos como o ambiente e a segurança pública (tanto nacional como internacional), entre outros. Reconhecimento que constitui o primeiro passo de uma abordagem holística das questões que a globalização vem convocando no plano jurídico (para o que nos interessa, nas suas dimensões penal, filosófica e sociológica). Reconhecimento que deve constituir a primeira aproximação à resolução dos problemas que a mundividência globalizante tem colocado, para que o actual *status quo* não se revele trágico e para que no futuro a tragédia não se converta em farsa¹⁰.

O duplo movimento ou, para recorrermos a uma imagem retirada da biologia, a estrutura de dupla hélice da globalização (abolição de barreiras/fronteiras e a ubiquidade do risco) compreende um (difícilmente reversível) processo de integração global. Um processo de integração vertido na normatização cinética¹¹ (movimento de pessoas, bens e serviços) e na normatização do risco. Em bom rigor, as duas variáveis em análise reconduzem-se ao mesmo problema tardo-moderno, passível de ser designado como cinética jurídico-política. Certamente não pecaremos por excesso ao configurarmos a globalização como uma questão de movimento, possuindo graus variáveis de atrito e de inércia. Dito com maior clareza, a globalização tende, como referimos anteriormente, à eliminação dos entraves que se erguem à livre circulação. Tais entraves mais não representam do que a entropia, do que o atrito que impede ou dificulta a uniformidade do movimento. Ora, se as manifestações globalistas ou globalizantes tendem à eliminação dos óbices ao movimento livre e, neste sentido, propendem à diminuição das forças de atrito que lhes prestam oposição, não menos verda-

⁸ Para uma compreensão mais aturada da “sociedade do risco”, ver U. Beck, *Sociedade de Risco Mundial: Em Busca da Segurança Perdida* (Edições 70, 2015), 26 e ss.

⁹ A descrever a transição da modernidade sólida para a modernidade líquida, ver Z. Bauman, *Confiança e Medo na Cidade* (Relógio D’Água, 2006), 24. Para uma análise mais aprofundada deste tópico, consultar Z. Bauman, *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty* (Polity, 2007).

¹⁰ Numa paráfrase de famosa afirmação de K. Marx, *O 18 de Brumário de Louis Bonaparte* (Avante, 2018), Cap. I.

¹¹ Para uma compreensão aprofundada da cinética política, ver P. Sloterdijk, *A Mobilidade Infinita: Para uma Crítica da Cinética Política* (Relógio D’Água, 2002), 30 e ss. e 43 e ss.

deira será a constatação de que a ausência de atrito aumenta substancialmente a inércia.

Em jeito de síntese, a globalização assume-se como um movimento que tende naturalmente à diminuição do atrito e à exponenciação da inércia. Não abandonando ainda a metáfora retirada da física, o aumento da inércia como corolário necessário da redução do atrito contém um dos traços estruturais mais importantes e simultaneamente preocupantes da globalização. A saber, a globalização possui uma estrutura marcadamente expansiva. Mais, uma estrutura expansiva que, na voragem e vertigem do movimento, tende a ultrapassar em velocidade a normação jurídica. Nunca como hoje se sentiu com tamanha agudeza (embora este seja um lugar-comum que, em maior ou menor medida, vem acompanhando o pensamento jurídico desde os seus alvares) a dificuldade do direito em acompanhar a realidade dos factos. *A contrario*, não resultará exagerado afirmar que a dinâmica globalizante no seu estágio não reflexivo e, portanto, liberal, ameaça promover espaços de desregulação jurídica.

Ainda que estejamos longe de afirmar a comunidade internacional como a arena do *bellum omnium contra omnes* hobbesiano¹², parece inegável que o mundo tantas vezes soerguido a aldeia global possui, além da face soalheira da mobilização ambulatória humana, uma segunda face mais obscura ou austera. Debrucemo-nos então sobre essa face.

3. Da “zona fronteira global” à “zona fronteira local”

Em bom rigor, a globalização, além de evidenciar as possibilidades de locomoção ou de deslocação e de sublinhar a potencialidade de diversas trocas inter-subjectivas, revela à contraluz aquilo que Zygmunt Bauman definiu como “zona fronteira global”¹³. Terreno da exclusão humana, a zona fronteira global perfila-se como o *locus* da espera (uma espera menos esperançosa do que a *expectatio* agostiniana)¹⁴, da suspensão política e, como corolário necessário, do olvido. Aqueles que a habitam esperam, limitam-se a esperar num limbo que, como todos os lugares raianos, se encontra numa zona de não inscrição, negando-lhes a pertença à *polis* e, neste concreto sentido, a um ser-comum.

O conceito de Bauman em apreço compreende a cartografia daquelas zonas (Estados falhados, teatros de guerra, campos de refugiados, etc.) que, à revelia do processo globalizante em curso, aprisionam os seus habitantes entre o “já não” e o “ainda não”, entre um passado de cidadania em risco de ser esquecido

¹² T. Hobbes, *Leviatã: Ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil* (INCM, 2010), 111.

¹³ Cfr. Z. Bauman, *Sociedade Sitiada* (Instituto Piaget, 2010), 112 e ss.

¹⁴ Cfr. Santo Agostinho, *Confissões* (INCM, 2001), Livro XI [XX.26].

e uma promessa de inscrição política futura sempre adiada. A zona fronteira global quadra os espaços de sombra no mundo globalizado (*lux mundi*), manchas despigmentadas que, ao esbaterem determinadas parcelas de território do espaço de discussão jurídico-político, condenam os danados que nelas habitam ao esquecimento, à incerteza e à desprotecção pessoal, tal as promessas de bestas mitológicas nos mapas antigos (*hic sunt dracones/hic sunt leones*).

Pelo exposto, a zona fronteira global firma o *locus* da exclusão jurídico-política, apresentando uma íntima conexão com o conceito e campo (“Lager”)¹⁵ despersonalizante. “Lager” que pode ser declinado como: i) campo de concentração; ii) campo de trabalhos forçados; iii) campo de detenção de migrantes; iv) campo de refugiados; v) campo de cultivo (papoila, coca, canábis, entre outros substratos ou percutores psicotrópicos). Como é bom de ver, todos os locais mencionados pressupõem a ausência ou a exiguidade do Estado e, neste concreto sentido, reduzem os seus habitantes à condição apátrida. Por condição apátrida consideramos a ausência ou a quebra do vínculo que une o sujeito à comunidade. Nos campos de concentração, de trabalhos forçados e, até, nos campos de cultivo, deparamo-nos com a erosão das atribuições estatais (quebra do vínculo) operada pela sujeição das pessoas à condição de objecto. Por sua vez, os campos de detenção de migrantes e os campos de refugiados colocam-nos perante o problema da ausência de Estado ou, dito com maior acerto, da impossibilidade de acesso dos seus habitantes ao *status civitatis*. Note-se, todavia, que qualquer das situações mencionadas se encontra cingida pelo signo do não-Estado, pelo vazio normativo passível de ser descrito pela fórmula “eu-anomia-outro” enquanto repriminação da fragilidade e, até, da insustentabilidade inter-subjectiva do *status naturalis*. Adiante voltaremos a este ponto.

Por ora, sublinhemos que, ao colocarmos em evidência as vantagens da globalização, nomeadamente por via de expressões como “aldeia global”, além de aproximarmos os “aldeões globais”, também aumentamos, em jeito de externalidade, a visibilidade e a dificuldade de legitimação das zonas de exclusão, qualquer que seja a forma que assumam. E não pecaremos por excesso se afirmarmos que hoje já não devemos apelar ao conceito de “aldeia global”. Em bom rigor, a “aldeia global” foi rendida pela “cidade global”, uma vez que as grandes áreas metropolitanas do mundo, *maxime* as ocidentais, parecem surgir como o espelho do lado soalheiro e, principalmente, da face sombria da globalização. Centremo-nos nesse lado sombrio, visto que arrisca ameaçar as vantagens conquistadas pelo refundação espaço-temporal globalizante.

Hodiernamente tendemos a dedicar maior atenção aos supramencionados campos de exclusão jurídico-política, remetendo para segundo plano a ques-

¹⁵ Para uma explicitação detalhada do conceito de “Lager”, ver G. Agamben, *O Poder Soberano e a Vida Nua: Homo Sacer* (Editorial Presença, 1998), 159 e ss.

tão das cidades, com as suas periferias e respectivas arquitecturas¹⁶. Ainda que aqueles campos convoquem problemas e questões da maior importância para a compreensão do actual *status quo* juspólitico, mormente da sustentabilidade da comunidade internacional ou inter-estatal, a exclusão política não surge como exclusiva desses concretos *loci*. Mais, não surge como exclusiva dos estados de excepção constitucional. Em bom rigor, a exclusão do *status civitatis* e, como consequência necessária, do *status personæ*, pode ocorrer, de modo igualmente pungente, no seio da normatividade não excepcional dos Estados de direito. A ser assim, a “zona fronteira global” converte-se em “zona fronteira local” (e também legal, diga-se) glocalizando¹⁷, deste modo, os problemas anteriormente atribuídos aos campos não-estatais.

Sublinhe-se que a dimensão não-estatal dos “Läger” não se prende com sua a desinserção do território de um determinado Estado, mas com a desobrigação estatal (imunização) perante os sujeitos que os habitam. Numa palavra, prende-se com a impossibilidade de acesso ao *munus* que congrega a *polis* e que a converte numa verdadeira sociedade (*societas*).

4. Ontologia do poder

O objecto que nos ocupa não se apresenta alheio ao grande problema ontológico que não apenas perpassa, mas precede toda a normação. A actividade normativa pressupõe a eleição de um esteio ontológico em que possa repousar e suster-se. Um esteio ontológico passível de apresentar uma conformação monista, dualista ou pluralista, ontologicamente centrado ou contrário ao antropocentrismo. Contudo, a eleição do referente ontológico influenciará não só toda a actividade normante, mas também as escolhas jurídico-políticas que tenham lugar num determinado tempo e espaço. Para o que nos ocupa, a escolha do fundamento ontológico do ordenamento jurídico desempenha um papel essencial na compreensão do binómio violência-poder. Dito de modo diverso, tanto a zona fronteira global como a zona fronteira local imbricam na temática da exclusão e da inclusão política, senão vejamos.

As diversas tentativas de explicar o surgimento da necessidade de ordenação jurídica radicam na superação ou na contenção da violência fratricida (reduzida ou não ao mitologema do *status naturalis*, na declinação pessimista

¹⁶ Sobre a relevância sociológica da arquitectura urbana, ver Z. Bauman, *Confiança e Medo na Cidade*, *supra* n. 9.

¹⁷ A propósito da glocalização, ver R. Robertson, “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in M. Featherstone *et al.*, *Global Modernities* (Sage, 1995), 25 a 42.

hobbesiana¹⁸ ou na concepção antropológicamente optimista em Rousseau¹⁹), na redução da violência inter-subjectiva que inquina a construção de um projecto social comum (*communitas*). De facto, desde os diversos mitologemas contractualistas, alicerçados no pessimismo hobbesiano ou no optimismo antropológico de Rousseau, até ao construtivismo pós-moderno que encontramos nas propostas funcionalistas sistémicas de Luhmann e nas suas múltiplas variações²⁰, a tónica da função estatal tem sido colocada na conversão da violência em poder.

A função do ordenamento jurídico tem passado facticamente pela substituição da instabilidade da ausência de normas pelo poder normante. Sem nos querermos alongar em demasia no presente ponto, o Estado, por via do seu *ius puniendi*, permite que a insegurança do *liberum arbitrium indifferentiae* capitule perante a segurança jurídica que se manifesta na punição dos agentes que ofendem bens jurídicos essenciais à comunidade. Tão-só a mencionada substituição da violência originária ou originante pelo poder permite a verdadeira alteridade, a inter-subjectividade que se manifesta no trinómio “eu-norma-outro”. Destarte, o trinómio “eu-norma-outro” sana a relação de violência inter-subjectiva firmada anteriormente pela relação “eu-anomia-outro”, ou seja, pelo contacto imediato e avesso à comunicação entre os oponentes. Contudo, se a anomia propicia a violência irrestrita e avessa ao porvir comunitário, a normação excessiva conduz a um poder autopoietico e auto-referente²¹ capaz de inquirir a alteridade ou, dito de modo diverso, impossibilitar a mediação entre o “eu” e o “outro”. Numa palavra, a anomia encontra-se inscrita sob o signo da violência inter-subjectiva e o poder excessivo compreende o risco de uma nova violência, a violência estatal. Tanto a exponenciação da violência como a acumulação de poder impossibilitam a construção comunitária.

Perante o ingente problema da acumulação autopoietica e auto-referente do poder, consideramos que apenas uma ontologia de matriz onto-antropológica se afigura capaz de proteger a comunidade dos excessos do grande monopolista do poder. Uma concepção ontológica que não deixa de se perspectivar contingente por dois motivos. Em primeiro lugar, surge como uma verdade de adesão, na medida em que radica na personalidade humana inata ou, se preferirmos, na dignidade da pessoa humana, elemento ontológico dificilmente comprovável. Em segundo lugar, na medida em que surge como uma opção normativa pragmática, no sentido em que permite a criação de critérios eficazes na contenção do poder estatal ou, pelo menos, para que os operadores jurídicos compreendam

¹⁸ Cfr. T. Hobbes, *supra* n. 12, 110.

¹⁹ Cfr. J. J. Rousseau, *O Contrato Social (Manuscrito de Genebra)* (Círculo de Leitores, 2012), 57.

²⁰ Para um resumo do pensamento luhmanniano, ver P. J. Morais, *Em Torno do Direito Penal do Inimigo: Uma Análise Crítica a Partir de Günther Jakobs* (Gestlegal, 2020), 249 e ss.

²¹ Em nova deriva luhmanniana.

que o poder deve encontrar-se funcionalizado à pessoa e não o contrário. Dito de forma clara, a função do poder consiste na manutenção da alteridade, de uma inter-subjectividade livre de coacção a permitir que o “eu” e o “outro” se descubram como pessoas e possam *personare* livremente. Como é bom de ver, a contenção do poder punitivo passa pela sua concepção enquanto desimplicação de uma concreta axiologia (dignidade da pessoa humana) que não se afigura como mero *ens in alio*, mas que surge orientada por critérios pragmáticos traduzíveis em concretos programas políticos e, mais especificamente, político-criminais.

5. Poder, personalidade e liberdade

Aqui chegados, entendemos que, funcionalizado à pessoa, o *ius puniendi* de um Estado de direito em sentido material e a personalidade encontram-se cingidos por uma relação de interdependência. Explicitemos semelhante ligação umbilical. Por um lado, o Estado, querendo afirmar o primado do direito, não pode prescindir da pessoa como *prius* axiomático, simultaneamente axiológico e pragmático. Se não assumisse o axioma antropológico como principal linha de fuga, o Estado rápida ou paulatinamente, mas sempre em curso fatídico, resvalaria para um enleio autoritário. Numa palavra, o poder não antropológicamente orientado ou pessoalmente sustentado capitularia perante a violência, seja meramente fáctica ou escorada num normativismo puro. De onde resulta que o modelo do Estado de direito em sentido material não pode prescindir de um transfundo antropológicamente centrado. Por outro lado, o sujeito, desprovido de dimensão política, excluído do palco estatal não logra *personare*, não se manifesta livremente enquanto pessoa. Sem o Estado, *rectius*, sem o Estado de direito em sentido material, os sujeitos vêm-se profundamente desprotegidos e, neste sentido, impossibilitados de extrinsecar a sua personalidade. No campo pré-estatal, tantas vezes descrito como *status naturalis*, a liberdade que permite a inter-subjectividade apresenta-se rarefeita, arredada que se encontra pelo *liberum arbitrium indifferentiae*.

Em rigor, o *ius puniendi*, tal como tem sido perspectivado, e a personalidade apresentam a liberdade como elemento comum e naturalmente agregador. Dito com clareza, para que não caia no movimento centrípeto da violência, o direito ou poder de punir deve configurar-se enquanto mecanismo de exponenciação das esferas de liberdade pessoais. Do mesmo modo, a pessoa, ou seja, o sujeito que não é mero objecto, reconduz-se ontologicamente a diversas esferas de liberdade. Claro está que nos referimos a uma liberdade normativizada, mediada pela norma. Uma mediação que representa ao mesmo tempo limitação e garantia. Limitação contra a vertigem da violência pré ou para-estatal e garantia (permanentemente vigilante) contra os excessos do *ius puniendi*.

Soerguida a elemento agregador do poder estatal e da personalidade, a liberdade não surge como um conceito naturalístico, mas como uma construção da *polis*, no exacto sentido de constituir uma estrutura estatal capaz de ser desimplicada em diversas normas funcionalmente orientadas à manutenção e, até, à exponenciação das esferas de liberdade pessoal. O *ius puniendi* deve perspectivar-se como um garante da liberdade individual que, por sua vez, surge como substrato da personalidade. Em jeito de síntese, a liberdade apenas surge possível na *polis*.

6. Estado, não-Estado e contra-Estado

No nosso entorno civilizacional, a dignidade humana perfila-se como o *prius* axiomático ou o substrato axiológico do Estado. Tomemos como exemplo o nosso ordenamento jurídico, mais concretamente o artigo 1.º da Constituição da República Portuguesa, a definir Portugal como uma República soberana, alicerçada sob o signo da dignidade humana. Mais do que uma coordenada meramente contingente, a dignidade humana apresenta-se como dístico da *forma mentis* jurídica ocidental. Dístico profundamente enraizado na consciência axiológica comunitária e, assim sendo, elemento incontornável e inalienável de toda a norma,ção, *maxime* da norma,ção jurídico-penal. De onde resulta que a defesa de uma ontologia antropológicamente centrada não se confunde com um qualquer pragmatismo construtivista. Pelo contrário, constitui uma escolha valorativa de fundo, contra os diversos relativismos – muitos deles de derivação populista – que assediam o direito penal. Contra os bárbaros que se aproximam do umbral²².

Colocando a tónica na dignidade humana como *prius* axiomático, a manutenção da personalidade surgirá conaturalmente associada à manutenção da estabilidade estatal. Retomando a exposição anteriormente encetada, da profunda imbricação entre a personalidade e o Estado resulta que a personalidade ficaria seriamente inquinada quando inserida num Estado de mera legalidade e, por sua vez, o Estado de direito avesso à personalidade revelaria rapidamente o seu jaez formalista. Como corolário necessário, a manutenção das esferas de liberdade individuais mais não representa do que a manutenção do *status quo* estatal. Sublinhemos que esta manutenção do *status quo* não quadra um construtivismo normativista avesso ao valor e ao sentido. Ao invés, o *status quo* proposto radica necessariamente numa essência ontológica fundada numa concepção não transaccionável da personalidade humana.

²² Como no interessante estudo de X. Bastida Freixedo, “Los Bárbaros en el Umbral: Fundamentos Filosóficos del Derecho Penal del Enemigo”, in C. Meliá, G.-J. Díez, *Derecho Penal del Enemigo: El Discurso Penal de la Exclusión* (Edisofer, 2006), vol. I, 277 a 305.

Como é bom de ver, a erosão do Estado, mais especificamente do seu *ius puniendi*, surge como uma ameaça à personalidade, fazendo perigar a protecção das esferas de liberdade individuais. Dito por outras palavras, a erosão do Estado mais não representa do que a erosão da personalidade e, como consequência necessária, o abandono da dignidade humana como esteio da punição. O *ius puniendi* marca indelevelmente a tensão dialéctica entre a liberdade e segurança, tensão que deve ser casuisticamente ponderada e ultrapassada. Contudo, uma vez efetivada a concordância prática entre os termos do binómio, veremos que o direito de punir se apresenta como um garante normativo da personalidade não desprezável. E não nos referimos apenas aos planos que ocorrem a jusante do crime, como veremos em seguida.

Certo é que um poder punitivo deficitário recua perante a violência fáctica do *status naturalis*, enquanto um poder hipertrófico reinterpreta e reintroduz normativamente essa violência originária e originante. A resposta à ingente questão do equilíbrio entre o poder e a liberdade deve ser dada pela função do direito penal e pelas finalidades das penas. Passa por uma função que se ocupe da protecção de bens jurídicos, não num sentido meramente nominalista e, consequentemente, formalista, mas de uma protecção indissociável da ressocialização do agente. Uma protecção de bens jurídicos que não possa ser afirmada à revelia da tarefa estatal da promoção dos instrumentos necessários para que o agente viva a sua vida afastado do crime. E passa igualmente pela afectação das consequências jurídicas do fenómeno criminal (penas e medidas de segurança) à estabilização normativa e, uma vez mais, à ressocialização do agente. Neste concreto sentido, a correcta composição entre o *ius puniendi* e a liberdade vivifica-se na afirmação do direito penal como direito de *ultima ratio*, subsidiário, fragmentário e, principalmente, não semântico.

O risco de derivas político-criminais meramente semânticas apresenta-se hoje significativo. Um risco que enquista sobremaneira o sistema jurídico-penal ao acelerar, por um lado, a erosão ou a desestabilização das expectativas comunitárias na vigência da norma violada²³ e, por outro, dos programas político-criminais orientados em função da ressocialização do agente. Uma erosão que não se perfila meramente normativa, mas igualmente ontológica e que poderá originar espaços em que o poder punitivo não é exercido. Ora, semelhantes *loci* compreendem a abertura, *rectius*, o deslaçamento da malha normativa rumo ao não-direito ou, dito de modo diverso, ao não-Estado. Enquanto não-direito, o não-Estado apresenta-se axiologicamente neutro. Trata-se tão-só de uma situação fáctica ausente de fins que, como todas os estádios meramente fácticos, se apresenta livremente preenchível. Destarte, a ausência de Estado poderá dar lugar ao surgimento do contra-Estado, ameaça à estabilidade do *ius puniendi* e,

²³ Servindo-nos de uma expressão cara a Jakobs.

como corolário necessário, da sua configuração ontológica antropológicamente centrada. A degenerescência estatal no não-Estado e no contra-Estado não abre apenas uma brecha no direito de punir. Encerra uma verdadeira antinomia que coloca em causa o Estado de direito em sentido material.

Voltando à ideia da “zona fronteira local”, o surgimento e a proliferação de zonas urbanas e periurbanas de exclusão passíveis de serem declinadas como não-Estado ou contra-Estado coloca em perigo a função do direito penal e as finalidades das penas. Em bom rigor, as zonas de exclusão que nos ocupam surgem motivadas por dois factores. Em primeiro lugar, perfilam-se como o resultado da ausência de eficácia normativa ou, melhor, da fragilização das expectativas normativas da comunidade. Fragilização esta que gora qualquer programa geral-preventivo e, nessa medida, a consecução da paz jurídica. Em segundo lugar, as zonas de exclusão convertem a prevenção especial positiva num enunciado meramente semântico, despidas que se encontram dos mecanismos essenciais à ressocialização do agente. Ademais, o não-Estado e o contra-Estado surgem como “zonas de comunicação zero”, escondedouros não apenas dos agentes, mas também das vítimas.

7. Abandono

Uma das chaves para a compreensão do monopólio estatal da violência/poder, mais propriamente dos limites do *ius puniendi*, passa pela resolução do binómio comunidade-bando²⁴. A legitimidade do poder punitivo reside na harmonização entre a sociabilidade inerente ao agir humano e a *communitas* entendida como o vínculo (obrigação comum) que une os sujeitos que constituem a *societas*. O monopólio da violência/poder declinado como a manutenção da estabilidade normativa essencial para que os administrados vivam dignamente ou, melhor, possam desimplicar a dignidade originária e originante que lhes permite *personare* apenas se verifica se a sociedade não ignorar as necessidades de agregação (*cum munus*) comunitária. Para que se mantenha estável, a *communitas* – principalmente a que se perfila como substrato de um Estado de direito em sentido material – não pode abandonar parcelas populacionais. Porém, os Estados europeus têm permitido o surgimento, no interior das suas *societas*, de bandos ou de micro-comunidades não integradas, de tal modo que o lugar-comum “we the people” surge cada vez mais difuso ou difícil de configurar. Tome-mos como exemplo deste fenómeno de abandono o surgimento de aglomerados habitacionais à revelia das regras jurídico-administrativas; a ausência dos mais elementares bens e serviços sociais a cujo fornecimento o Estado se encontra obrigado; ou o crescimento e recrudescimento da “guetificação”, conaturalmente

²⁴ Sobre o conceito de bando, ver G. Agamben, *supra* n. 15, 36, 37, 77 e 108.

caracterizada pela ausência de um consenso social mínimo em relação aos bens jurídicos essenciais à convivência comunitária.

A manutenção antinómica da *societas* (que entendida numa relação de identidade com a *communitas* agregadora se perfila como tese) em simultâneo com diversas micro-comunidades (bandos) que lhe são refractárias (antítese) despe o Estado de defesas perante diversos fenómenos contra-estatais que surgem num crescendo centrípeto e naturalmente erosivo. Nas últimas décadas, as grandes ameaças à segurança pública, as mais agudas questões jurídico-penais têm-se desenhado ou desenvolvido na “zona fronteiriça local” dos subúrbios. Os Estados têm preferido ignorar ou não admitir que o espaço urbano e periurbano se tem paulatina e pacientemente apoderado de parcelas do poder tradicionalmente pertencentes aos ordenamentos jurídicos. A impassividade estatal perante os desafios contingentes poderá constituir, numa análise semiológica, uma técnica de imunização perante a complexidade aparentemente irresolúvel dos problemas que hoje se colocam ao direito de punir. Contudo, não devemos esquecer que a imunização excessiva mais não é do que auto-imunidade²⁵, redundando num curto-circuito jurídico perigoso e evitável.

Quando a *societas* (a grande *communitas*) perde o controlo ou abandona as micro-comunidades que a compõem, o recurso ao direito penal surge desaiado. Perante semelhante circunstancialismo, o recurso ao *ius puniendi* afigura-se fatidicamente condenado ao fracasso. Condenação que surge agudizada quando se pede ao Estado que (re)estabilize o que nunca foi estável, nomeadamente normas que nunca foram exigidas ou compreendidas em determinados *loci*. Mais se pede que (re)socialize agentes que nunca tiveram a oportunidade prévia de serem socializados. Em suma, exige-se ao direito penal que seja *prima ratio*, sem que tenha havido um sério esforço comunitário prévio tendente à manutenção do carácter unitário (mas sempre pluralista e aberto) do Estado.

Não queremos de modo algum significar que os fenómenos ou os influxos criminais periurbanos não devem ser sancionados em termos jurídico-penais. No plano circunstancial em que nos encontramos, dificilmente se descortinarão respostas normativas que não se apresentem repressivas. Porém, a médio e longo prazo, sublinhamos incansavelmente que a resposta deve ser, *rectius*, deve voltar a ser integrativa e ressocializadora. Uma resposta integrativa e ressocializadora que permita ao direito penal: *i*) cumprir de modo mais efectivo a sua função e as finalidades das penas que contém; *ii*) não incorrer num curto-circuito hipertrófico, seja punitivo ou garantístico (duas das declinações do populismo penal); *iii*) intervir apenas quando é necessário, possibilitando o surgimento de soluções mais eficazes a montante do fenómeno criminal. Numa palavra, para que não

²⁵ Sobre a auto-imunidade política, ver R. Esposito, *Immunitas: Protección y Negación de la Vida* (Aморrtu, 2009), 29.

tenhamos de escrever sobre a “estranha morte do direito penal”, como hoje se escrevem livros alegando a “estranha morte da Europa”²⁶.

De volta ao vestido que serviu de mote à presente reflexão, hoje encontramos muitas noivas nas periferias urbanas. Noivas que, à semelhança dos soldados da Libéria, são invisíveis. Contudo, não é o traje que as reveste de invisibilidade, somos nós. Nós a cidade, nós a comunidade, “we the people”.

Bibliografia citada

Agamben, G., *O Poder Soberano e a Vida Nua: Homo Sacer* (Editorial Presença, 1998).

Apollinaire, G., *O Século das Nuvens* (Assírio & Alvim, 2007).

Barthes, R., *Mitologias* (Círculo de Leitores, 1987).

Bastida Freixedo, X., “Los Bárbaros en el Umbral: Fundamentos Filosóficos del Derecho Penal del Enemigo”, in C. Meliá, G.-J. Díez, *Derecho Penal del Enemigo: El Discurso Penal de la Exclusión* (Edisofer, 2006), vol. I.

Bauman, Z., *Confiança e Medo na Cidade* (Relógio D’Água, 2006).

_____, *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty* (Polity, 2007).

_____, *Sociedade Sitiada* (Instituto Piaget, 2010).

Beck, U., *Sociedade de Risco Mundial: Em Busca da Segurança Perdida* (Edições 70, 2015).

Esposito, R., *Immunitas: Protección y Negación de la Vida* (Amarrortu, 2009).

Gil, J., *Portugal, Hoje: O Medo de Existir* (Relógio D’Água, 2004).

Hobbes, T., *Leviatã: Ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil* (INCM, 2010).

Kant, I., “Zum ewigen Frieden : Ein philosophischer Entwurf”, in W. Weischedel, *Immanuel Kant: Werke in zwölf Bänden* (Suhrkamp, 1977).

Marx, K., *O 18 de Brumário de Louis Bonaparte* (Avante, 2018).

Morais, P. J., *Em Torno do Direito Penal do Inimigo: Uma Análise Crítica a Partir de Günther Jakobs* (Gestlegal, 2020).

²⁶ Cfr. D. Murray, *A Estranha Morte da Europa* (Desassossego, 2018).

Moran, M. H., *Liberia: The Violence of Democracy* (University of Pennsylvania Press, 2006).

_____, “Warriors or Soldiers? Masculinity and Ritual Transvestism in the Liberian Civil War”, in L. Lamphere *et al.*, *Situated Lives: Gender and Culture in Everyday Life* (Routledge, 1997).

Murray, D., *A Estranha Morte da Europa* (Desassossego, 2018).

Robertson, R., “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in M. Featherstone *et al.*, *Global Modernities* (Sage, 1995).

Rousseau, J. J., *O Contrato Social (Manuscrito de Genebra)* (Círculo de Leitores, 2012).

Santo Agostinho, *Confissões* (INCM, 2001).

Sloterdijk, P., *A Mobilidade Infinita: Para uma Crítica da Cinética Política* (Relógio D'Água, 2002).

_____, *Palácio de Cristal: Para uma Teoria Filosófica da Globalização* (Relógio D'Água, 2008).



Universidade do Minho
Escola de Direito

Título: **Anuário de Direitos Humanos - Nº3**

Edição: **Centro de Investigação em Justiça e Governação**
Escola de Direito da Universidade do Minho

Diretora: **Anabela Susana de Sousa Gonçalves**

Data: **Dezembro 2021**

ISSN: **2184-1853**